

제4장 추심명령

제4장 추심명령

제1절 서설

채권집행에 있어서 금전채권의 압류만으로써는 압류채권자의 집행채권에 만족을 줄 수 없으므로 압류채권자는 자기채권의 만족을 얻기 위해서는 압류한 금전채권을 현금화할 필요가 있게 된다.

이를 위하여 민사집행법 제229조는 금전채권의 현금화방법으로서 추심명령(Überweisungsbeschuß zur Einziehung)과 전부명령(Überweisungsbeschuß an Zahlungs Statt)을 규정하고 있다.¹⁾ 금전채권의 현금화방법으로는 그 밖에도 민사집행법 제241조에 정해진 특별현금화방법으로서의 양도명령, 매각명령, 관리명령 및 그 밖의 상당한 방법에 의한 현금화방법 등이 있으나, 이들은 특별한 경우에만 인정되는 예외적인 현금화방법에 해당하고, 원칙적인 현금화방법은 위와 같은 추심명령과 전부명령이라 할 수 있다.

추심명령은 전부명령처럼 채권자가 독점적인 만족을 얻을 수 없지만, 다른 한편 제3채무자가 무자력인 경우의 위험을 채권자가 부담하는 것은 아니므로 전부명령을 할 수 없는 경우 또는 제3채무자의 자력이 불안한 경우에는 추심명령이 많이 이용된다. 추심명령은 그 허용되는 범위가 전부명령보다 넓으므로 채권에 대한 강제집행에 있어서 기본적인 현금화방법이라고 할 수 있다.²⁾ 금전채권의 현금화방법으로서 전부명령과 추심명령 중 어느 것을 선택할 것인가는 원칙적으로 압류채권자의 의사에 달려있다고 볼 수 있다.

그리고 압류채권자는 추심명령을 얻은 후 제3채무자가 추심절차에 대하여 의무를 이행하지 아니하는 때에는 소로써 그 이행을 청구할 수 있다(민집 제238조, 제249조 제1항).

1) 강학상 추심명령과 전부명령을 합하여 이부명령(移付命令)이라 하고, 이러한 채권자에 대한 수권을 이부(移付)라고 한다.

2) 일본 민사집행법은 금전채권의 경우에 별도의 추심명령 제도를 폐지하고 그 대신 채무자에게 압류명령이 송달된 때로부터 1주일이 경과하면 압류채권자가 당연히 추심권능을 취득하는 것으로 하였다(일본 민사집행법 제155조 제1항).

제2절 추심명령

I. 추심명령의 의의

1. 서

채권에 대한 압류는 제3채무자에 대해서는 채무자에 대한 지급을 금하고 채무자에 대해서는 채권의 처분과 영수를 못하게 하지만 압류채권자에게 압류한 채권을 직접 추심할 권한까지 부여하는 것은 아니므로 압류채권자가 채권의 만족을 얻기 위해서는 따로 현금화를 하지 않으면 안 된다.

이러한 현금화의 방법에는 추심명령, 전부명령(민집 제229조)과 특별한 현금화방법(민집 제241조)이 있는데 그 중 추심명령과 전부명령이 원칙적인 현금화방법이다.³⁾

추심명령은 압류한 채권의 목적인 급부를 제3채무자로부터 추심할 권능을 집행채권자에게 수여하는 집행법원의 결정이다. 채권 자체는 채무자에게 남아 있다는 점에서 채권의 귀속 자체가 변경되는 전부명령과 구별된다. 또한 제3채무자의 무자력으로 피압류채권을 추심하지 못할 때에는 채권자는 동일한 집행권원에 기하여 채무자의 다른 재산에 대하여 강제집행을 할 수 있다.

추심명령이 있으면 피압류채권은 채무자에게 귀속된 채 채권자는 민법상의 대위절차 없이 채무자의 권한을 행사하여 피압류채권의 이행을 구할 수 있다. 추심명령은 피압류채권이 금전채권이든 비금전채권(민집 제242조 참조)이든 묻지 않고, 권면액이 없는 채권이건, 압류가 경합하고 있는 경우이건, 양도금지의 특약이 있는 채권이건 상관하지 않지만 다만 피압류채권이 조건부 또는 기한부라든가 반대채권과 동시이행의 관계에 있다든가 기타의 사정으로 추심하기 곤란한 경우에는 특별한 현금화방법을 이용할 수 있다(민집 제241조).

3) 일본은 민사집행법을 제정하면서 금전채권은 반드시 현금화의 절차를 거쳐야 하기 때문에 실무상으로도 압류 및 추심명령이 함께 신청되는 것이 통례이고 또한 추심명령이 금전채권현금화의 대표적인 방식(압류가 경합된 경우 등 모든 경우에 가능하다)이라는 이유로 추심명령을 폐지하고 압류명령을 받은 者は 다시 추심명령을 얻지 않더라도 채무자에 대하여 압류명령이 송달된 날로부터 1주일을 경과한 때에는 당연히 압류한 채권을 추심할 수 있는 것으로 하고 있다(일본 민사집행법 제155조 제1항).

2. 전부명령과의 관계

금전채권의 이부명령(移付命令)에는 추심명령 외에 전부명령이 있는데, 전부명령은 압류한 금전채권을 권면액으로 집행채권의 변제에 같음하여 압류채권자에게 이전하는 집행법원의 결정이다.

추심명령과 전부명령 모두를 발할 수 있는 경우라면 압류채권자는 자유로이 그 중의 하나를 선택하여 신청할 수 있고, 피압류채권의 일부에 대하여는 추심명령을, 나머지에 대하여는 전부명령을 신청하거나 또는 전부명령을 신청하면서 그것이 허용되지 않는 경우에 대비하여 예비적으로 추심명령을 신청할 수도 있다.⁴⁾

다만 전부명령은 피압류채권을 변제에 같음하여 채권자에게 이전하는 효력을 가지고 있으므로 양자를 동시에 신청하거나 전부명령을 받은 후에 다시 추심명령을 신청할 수 없다.⁵⁾ 그러나 추심명령을 받은 후에 다시 전부명령을 신청하는 것은 무방하며 이 경우 전부명령이 발하여져서 그 효력이 발생하게 되면 선행의 추심명령은 그 효력을 상실하게 되므로 추심명령을 받은 채권자가 미리 추심권을 포기해야 하는 것도 아니고 법원이 추심명령을 취소할 필요도 없다.⁶⁾

추심명령과 전부명령 중 어느 것이 채권자에게 유리한가는 한 마디로 단정할 수 없지만 전부명령에 의하면 채권자는 독점적 이익을 얻게 되나 제3채무자의 무자력으로 인한 위험을 부담하게 되고, 추심명령은 현실적 만족을 얻기 전에 집행채권이 소멸할 위험은 없으나 다른 채권자의 배당가입 때문에 채권자의 몫이 줄어들 우려가 있는 장단점이 있다. 채권자가 추심명령과 전부명령 중 어떤 것을 신청하는 것 인지가 분명하지 않은 경우에는 그에게 불이익이 적은 추심명령의 신청으로 볼 것이다.⁷⁾

4) 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 법원행정처(2014), 361.; 兼子一, 増補強制執行法, 酒井書店(1979), 203.

5) 이영섭 편집대표, 주식 강제집행법(中), 한국사법행정학회(1984), 61.; 다만 전부명령이 전부를 위한 요건을 흠결하여 무효일 때를 고려한다면 추심명령도 함께 발할 실익이 있다는 주장이 있다 [鈴木忠一 = 三ヶ月章 責任編集, 注解民事執行法(2), 第一法規出版株式會社(昭和 60), 324.]; 그리고 압류는 유효하고 전부명령만이 무효인 경우(예컨대 압류가 경합된 상태에서 전부명령이 발부된 때)에는 다시 추심명령을 발할 수 있다(대법원 1978. 9. 28. 선고 76다1145, 1146 판결; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 337. 등).

6) 兼子一(주4), 207.; 宮脇幸彦, 強制執行法(各論), 法律學全集 36-II, 140.; 日大決 昭和 6(1931), 7, 11.

7) 兼子一(주4), 203.; 菊井維大, 民事訴訟法(二), 有斐閣(1964), 177.; 宮脇幸彦(주6), 183.

II. 추심명령의 신청

1. 신청방법

가. 추심명령의 신청은 서면으로 하되(민집 제4조), 그 신청서에는 당사자(채권자, 채무자, 제3채무자) 및 그 대리인, 추심할 채권의 종류와 수액, 집행권원, 채권자가 대위절차 없이 피압류채권의 지급을 받을 수 있음을 명하는 재판을 구하는 취지, 집행권원에 기한 청구권의 일부에 관해서만 추심명령을 신청하거나 목적채권의 일부에 대해서만 추심명령을 신청하는 때에는 그 범위, 신청 연월일, 집행법원을 명시하고 채권자 또는 그 대리인의 기명날인이 있어야 한다.⁸⁾

나. 추심명령의 신청은 압류명령의 신청과 동시에 또는 별도로 할 수 있는데, 실무상 병합신청의 예가 많다.

추심명령만을 별도로 신청하는 경우에는 추심명령의 대상인 채권은 압류한 채권이어야 하므로 선행의 채권압류명령사건(사건번호 등)을 표시하여야 한다. 양 채권의 동일성이 인정되고 경정의 필요성이 없는 한 그 표시는 실제의 채권과 완전히 일치할 필요는 없고 압류명령에서의 표시와 일치하지 않아도 좋다.⁹⁾

수개의 집행권원에 기하여 1개의 신청으로 채권압류 및 추심 또는 전부명령을 신청하는 경우에는 압류명령과 추심 또는 전부명령은 수개의 신청을 편의상 1건으로 신청한 것이므로 각 집행권원의 수에 상응하는 인지를 첨부해야 한다.¹⁰⁾

다. 민사집행법 제233조에 의한 지시채권의 경우에는 집행관이 증권을 점유하여야 압류의 효력이 발생하므로 압류명령과 동시에 추심명령을 신청할 수는 없고 집행관의 증권에 대한 점유가 있는 뒤에만 신청할 수 있다.^{11) 12)}

이 경우에는 집행관이 증권을 점유한 사실을 증명하여야 하는데 통상 집행관의

8) 별지서식 [4-2] 채권압류 및 추심명령 신청서(제4장 말미 수록)

9) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事制執行法(2), 325.

10) 대법원 재판예규 제1524호, “수개의 집행권원에 기하여 1건으로 채권압류 및 전부명령을 신청할 경우 첨부할 인지액(재민 87-9)”

11) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事制執行法(2), 325-326.; 집행관이 증권을 점유하지 않은 상태에서 발령된 추심명령이나 전부명령은 무효이다. 다만 추심명령이나 전부명령이 제3채무자에게 송달되기 전에 집행관이 증권을 점유한 때에는 그 현금화명령은 유효하게 된다.

12) 별지서식 [4-4] 지시채권의 추심명령신청 참조(제4장 말미 수록)

집행조서등본을 신청서에 첨부한다.

그러나 일반 압류에 있어서는 압류명령이 제3채무자에게 송달되지 않았어도(즉 압류명령의 효력이 아직 발생하지 않았어도) 추심명령을 발할 수 있다.

라. 피압류채권의 일부에 관하여 추심명령을 구하는 경우에는 그 취지를 명백히 하여야 함은 전술한 바이지만, 이때 나머지 부분에 대한 압류는 의연히 존속한다.¹³⁾ 신청서에 추심의 범위가 명시되지 아니한 경우에는 채권전액에 대하여 추심을 구하는 취지로 볼 것이다.¹⁴⁾

마. 압류명령 후 압류채권자로부터 채권의 승계(일반승계이든 특정승계이든 묻지 않는다)를 받은 채권자는 집행권원에 기해 승계집행문을 얻어 그 승계집행문과 송달 증명서를 첨부하여(민집 제31조, 제39조) 추심명령을 신청할 수 있다. 이 경우에 법원사무관등은 승계인의 주소 또는 주민등록번호를 소명하는 자료를 제출하게 할 수 있다(민집규 제19조 제3항).

압류 후에 채무자 또는 제3채무자의 사망에 의한 상속, 합병과 같은 일반승계가 있는 경우에는 추심명령의 신청서에 이를 표시하고 그것을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다(민집 제31조 제1항). 채권양도, 채무인수 등 특정승계에 있어서는 채권자에게 대항할 수 없으므로 이를 무시하고 전 당사자를 표시하면 된다.¹⁵⁾

2. 관할법원

추심명령을 신청하여야 할 관할법원은 압류명령의 집행법원과 동일한 지방법원이다.

추심명령이 압류명령과 별도로 신청되는 경우에 압류명령이 송달된 뒤 채무자나 제3채무자의 주소가 바뀌어 그 보통재판적이 달라지더라도 추심명령은 압류명령을 전제로 하여 내려지는 것이므로 추심명령은 압류명령을 발령한 법원이 관할법원이 된다.

채권질권의 설정자와 그것에 의하여 담보되는 채권의 채무자가 다른 경우에 강

13) 宮脇幸彦(주6), 140.; 日大判 明治 39(1906), 10, 25.(大審院民事判決錄 12, 1350); 대법원 1983. 8. 23. 선고 83다카450 판결【판결요지】[1] 압류채권에 대한 추심명령을 받아 추심금 청구 소송을 제기, 진행중 청구금액을 감축한 것은 소의 일부취하를 뜻하는 것이고 취하된 부분의 청구를 포기하였다고는 볼 수 없으며, 위 채권압류는 추심하고 남은 잔여채권에 대하여 그 효력을 지속하는 것이다. [2] 압류가 경합된 상태에서 발부된 전부명령은 효력이 없다 할 것이다.

14) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 362.

15) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 325.

제집행의 방법에 따른 질권의 실행에서 집행채무자로 되는 것은 압류의 목적인 채권의 채권자(담보제공자)이고, 피담보채권의 채무자는 아니다.

Ⅲ. 추심명령의 재판

1. 심리

추심명령의 신청이 있으면 집행법원은 관할권의 유무, 신청의 적식 여부, 강제집행의 요건 및 개시요건의 유무, 집행장애의 유무, 압류명령의 효력의 존부, 추심명령 발부요건의 유무(예를 들어, 민사집행법 제240조의 해당 여부) 등을 조사하여 신청의 허부를 결정한다.

압류금지채권의 경우에는 추심명령도 발령할 수 없다. 이전에 압류가 되어 있었다고 하더라도 그 후에 파산절차나 회생절차 등이 개시되거나 집행정지증서가 제출되는 등 집행장애 사유가 발생한 때에는 추심명령을 발령하여서는 안 된다.

압류명령과 병합하여 신청하는 경우에는 민사집행법 제226조에 의하여 제3채무자나 채무자를 심문하지 아니하고 신청서만으로 심리한다. 압류의 효력발생 후 추심명령만을 신청한 때에는 필요하다고 인정할 경우 채무자 또는 제3채무자를 심문할 수 있으나(민집 제23조 제1항, 민소 제134조), 집행채권이나 피압류채권의 존부에 대하여 실체적 심사를 할 수는 없다.¹⁶⁾ 그러나 피압류채권이 존재하고 있지 아니한 것이 명백한 경우에는 추심명령을 내리지 못한다.¹⁷⁾

심리한 결과 신청이 부적법하고 보정할 수 없는 등 추심명령을 발할 수 없는 것으로 인정되면 신청을 각하 또는 기각하여야 한다.

2. 추심명령의 내용

추심명령에는 사건번호, 당사자의 표시, 추심의 대상인 채권, 추심권능을 부여하는 선언,¹⁸⁾ 결정일자, 집행법원의 표시 및 판사의 기명날인(민소 제224조)이 있어야 한다.¹⁹⁾

16) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 62.; 菊井維大(주7), 177.; 中務, “取立命令と轉付命令”, 民事訴訟法講座 第4卷, 1183.

17) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 327.

18) 그 문구는 「채권자는 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 압류된 채권을 추심할 수 있다.」라고 표시한다.

19) 별지서식 [4-1] 추심명령 및 [4-3] 채권압류 및 추심명령 참조(제4장 말미 수록)

압류명령과 별도로 추심명령을 하는 때에는 압류명령사건의 번호를 적어야 한다.

집행채권은 압류명령의 기재와 동일하므로 원칙적으로 적지 않고, 다만 집행채권의 수액에 변경이 있는 등의 경우에만 예외적으로 적는다. 구 민사소송법에서는 가집행면제의 선고 있는 판결(민소 제213조)에 기초한 강제집행의 경우에는 추심권이 제한되고 전 부명령이 허용되지 않았지만(구 민소 제568조), 부동산집행과 동산집행에 이러한 제약이 없는 것과 균형을 맞추기 위해서 민사집행법에서는 그러한 특칙을 두지 않았다.

3. 추심명령의 송달

가. 추심명령의 송달에 관하여는 압류명령의 송달에 관한 민사집행법 제227조 제2항이 준용되므로(민집 제229조 제4항), 제3채무자와 채무자에게 송달하여야 한다. 이에 반해, 채권자에게는 적당한 방법으로 고지하면 된다. 채권이 이미 변제 등으로 소멸한 경우에는 그 후에 그 채권에 관한 채권압류 및 추심명령이 송달되더라도 그 채권압류 및 추심명령은 존재하지 아니하는 채권에 대한 것으로서 무효이고, 지명채권양도의 제3자에 대한 대항요건의 문제는 발생될 여지가 없다.²⁰⁾

연대채무 등 채무자가 수인인 경우에는 각각 별도로 송달하며, 신청서에 보증인이 표시되어 있으면 보증인에게도 송달한다. 저당권 있는 채권의 추심에 있어서는 물상보증인에게도 송달한다. 권리능력 없는 사단·재단에 대한 송달은 대표자에게 하면 충분하고, 제3채무자나 채무자가 제한능력자인 경우에는 법정대리인에게 송달하여야 한다.

국가가 제3채무자인 경우에는 추심명령을 발한 법원에 대응하는 검찰청(지청인 경우에는 지방검찰청)의 장에게 하여야 한다는 견해와 국가를 대표하는 법무부장관에게 송달하여야 한다는 견해가 있으나, 실무는 전자의 견해를 취하는 것으로 보인다.²¹⁾

나. 제3채무자의 소재불명으로 송달불능이 된 경우에 공시송달을 할 수 있는가에 대하여는 견해의 대립이 있다.

추심명령은 제3채무자에 대한 송달에 의하여 그 효력이 생기기 때문에 추심명령이 제3채무자에게 실제로 도달하지 않으면 안 된다는 이유를 들어 보충송달 및 유치송달은 인정되나 우편송달이나 공시송달은 허용되지 아니한다는 설이 있다.²²⁾ 실제상

20) 대법원 2003. 10. 24. 선고 2003다37426 판결

21) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 321-322, 참조

22) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 48.; 宮脇幸彦(주6), 141-142.; 菊井維大=村松俊夫, 民事訴訟法[I], 日本評論社(1993), 562.은 제3채무자는 당사자가 아니라는 이유로 공시송달이 허용되지 않는다고 한다.

제3채무자의 소재가 불명한 경우에는 채권의 추심도 불능인 것이 통례이기 때문에 신청할 실익도 없어 취하로 종료되는 경우도 많다. 다만 담보부채권의 경우에는 담보권의 실행에 의하여 만족을 얻을 수 있는 등 추심명령의 효력을 발생시킬 실익이 있기 때문에 공시송달을 허용해야 할 것이다.²³⁾

그러나 이 경우에 제3채무자가 이 사실을 모르고 선의·무과실로 채무자에게 변제하면 유효한 변제로 보호받을 수 있을 것이다.²⁴⁾

다. 채무자에 대한 송달은 채무자가 집행채무자인 만큼 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 공시송달을 할 수 있다.²⁵⁾ 압류채권자가 동시에 제3채무자인 때에도 추심명령의 효력발생을 위하여 송달하여야 한다.²⁶⁾

라. 추심명령은 제3채무자에 대한 송달이 있음으로써 그 효력이 생긴다(민집 제229조 제4항, 제227조 제2항).

따라서 채무자에 대한 송달이나 채권자에 대한 고지의 유무는 추심명령의 효력발생에 영향이 없다.²⁷⁾ 추심명령을 각하 또는 기각할 때에는 그 결정을 신청채권자에게만 고지하면 족하다(민집규 제7조 제2항).

4. 추심명령의 경정

추심명령에 위산(違算), 오기 기타 유사한 오류가 있는 것이 명백한 때에는 집행법원은 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 추심명령의 동일성이 침해되지 않는 범위 내에서 경정결정을 할 수 있다(민집 제23조, 민소 제211조).

통상 추심명령상의 당사자나 집행채권, 피압류채권의 표시가 집행정본이나 신청서의 기재와 다를 경우 또는 이자, 지연손해금의 위산(違算)이 있는 경우 혹은 신청서의 기재 자체가 추심명령 전에 제출된 다른 소송자료에 비추어 명백한 오류가 있었고 이로 인하여 추심명령에도 잘못 기재된 경우 등이 경정의 대상이 된다. 그러나 피추심채권의 표시를 경정하는 데에는 신중을 기하여야 할 것이다.

경정결정은 추심명령의 원본과 정본의 여백에 부기하여 행하는 것이 원칙이나, 추심명령정본이 송달된 후에는 따로 경정결정서를 작성하여 제3채무자 및 채무자에게

23)鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 294.

24)鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 294.

25)이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 48.

26)이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 48.

27)이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 63-64.;鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 329.

송달하여야 하며 이 결정결정이 제3채무자에게 송달되면 추심명령송달시에 소급하여 그 효력이 있다.

5. 추심명령에 대한 불복신청

추심명령의 신청에 관한 재판에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집 제229조 제6항).²⁸⁾

이 경우 항고권자는 채무자 및 제3채무자라고 할 수 있다. 신청채권자는 추심명령의 신청을 각하 또는 기각한 결정에 대하여 즉시항고를 할 수 있다.²⁹⁾

즉시항고의 사유로서는 대체로 압류명령의 경우와 마찬가지로 압류된 채권이 압류금지채권에 해당한다거나 압류된 채권이 특정되지 않았다는 것이 될 수 있다.

그러나 압류된 채권이 존재하지 않는다는 것을 즉시항고사유로 주장할 수는 없고, 이러한 사유는 추심금 청구소송에서 주장하여야 한다. 또한 집행채권의 부존재 등과 같은 집행의 불허에 관한 실체상의 이유는 청구이의의 소로써 주장하여야 하며, 즉시항고에 의하여 주장할 수는 없다.

추심명령이 발령되기 전에 강제집행정지사유가 있는 경우 이는 즉시항고의 사유가 될 수 있다(민집 제229조 제8항 참조). 그러나 가집행선고부 제1심판결을 집행권원으로 한 채권압류 및 추심명령이 있는 후에 그 집행권원인 제1심판결에 대하여 강제집행정지 결정이 있으면, 위 결정의 효력에 의하여 집행절차가 중지되어 압류채권자가 피압류채권을 추심하는 행위에 더 이상 나아갈 수 없을 뿐이고 집행법원이 채권압류 및 추심명령을 취소하여야 하는 것이 아니다.³⁰⁾ 따라서 채권압류 및 추심명령이 발령된 이후에 그 집행권원인 제1심판결에 대하여 강제집행정지 결정이 있었다는 사유는 채권압류 및 추심명령에 대한 적법한 즉시항고 사유가 될 수 없고,³¹⁾ 또 이와 같은 사정만으로 제3채무자의 추심금 지급에 관한 소송절차가 중단된다고 볼 수는 없을 뿐 아니라 이로 인해 제3채무자가 압류에 관련된 금전채권의 전액을 공탁함으로써 면책받을 수 있는 권리가 방해받는 것도 아니다(민집 제248조 제1항 참조).³²⁾ 또

28) 판결이 아닌 법원의 결정·명령에 대하여는 당사자가 그 결정·명령의 결과를 고지받기 전이라도 항고할 수 있다[대법원 2014. 10. 8.자 2014마667 전원합의체 결정].

29) 이영섭, 신민사소송법(하), 박영사(1960), 171.; 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 64.

30) 이 경우 이미 실시한 집행처분을 일시적으로 유지하게 하여야 한다(민집 제50조 제1항).

31) 대법원 2005. 11. 8.자 2005마992 결정

32) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2009다70067 판결. 따라서 법원은 그대로 판결을 선고할 수 있다. 이 경우 제3채무자(피고)는 임의변제할 수 없으므로 제3채무자로서는 압류를 이유로 권리로서의 집행공탁을 하거나 추심권자를 피공탁자로 하여 변제공탁하여 채무에서 벗어날 수 있을 것이다.

한 채무자회생 및 파산에 관한 법률에 의한 면책결정이 확정되어 채무자의 채무를 변제할 책임이 면제되었다고 하더라도 이는 면책된 채무에 관한 집행권원의 효력을 당연히 상실시키는 사유는 되지 아니하고 다만 청구이의의 소를 통하여 그 집행권원의 집행력을 배제시킬 수 있는 실체상의 사유에 불과하므로 적절한 즉시항고이유가 되지 아니한다.³³⁾

위에서 보았듯이 추심명령은 제3채무자에게 송달됨으로써 그 효력이 발생하고(민집 제229조 제4항, 제227조 제2항), 추심명령에 대하여 즉시항고가 제기되더라도 이는 추심명령의 효력발생에는 영향을 미치지 아니한다(민집 제15조 제6항).

한편 추심명령이 있는 후 집행정지결정의 정본(민집 제49조 제2호) 또는 변제증서 등(같은 조 제4호)의 서류가 제출된 때에는 법원사무관등은 압류채권자 및 제3채무자에 대하여 그 서류가 제출되었다는 사실과 서류의 요지 및 위 서류의 제출에 따른 집행정지의 효력이 상실되기 전에는 압류채권자는 채권의 추심을 하여서는 아니되고 제3채무자는 채권의 지급을 하여서는 아니된다는 취지를 통지하여야 한다(민집규 제161조 제1항).³⁴⁾ 최종적으로는 잠정적인 집행정지가 집행취소 또는 집행속행으로 결말이 날 것이므로 이에 따르게 될 것이다.

IV. 추심명령의 효력

1. 추심권의 범위와 제한

가. 추심명령의 효력과 추심권의 범위

1) 채권자는 추심명령에 의하여 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 채권을 직접 추심할 권능을 취득한다. 이러한 추심권은 채권자가 추심명령에 의하여 창설적으로 취득하며 채무자로부터 승계하는 것은 아니다.³⁵⁾

33) 대법원 2013. 9. 16.자 2013마1438 결정. 한편 면책결정의 확정은 면책된 채무에 관한 집행력 있는 집행권원 정본에 기하여 그 확정 후 비로소 개시된 강제집행의 집행장애사유가 되지 아니한다.

34) 대법원 2012. 10. 25. 선고 2010다47117 판결【판결요지】집행력이 있는 판결 정본에 기하여 압류·추심명령이 발령된 경우 채무자가 강제집행정지결정의 정본을 집행기관에 제출하면 이로써 집행정지의 효력이 발생하고 그 집행정지가 효력을 잃기 전까지 압류채권자에 의한 채권의 추심이 금지된다(민사집행법 제49조 제2호). 여기서 강제집행정지결정의 정본이 압류채권자에게 송달되었는지 여부나 민사집행규칙 제161조가 규정하는 집행정지 통보가 제3채무자에게 송달되었는지 여부는 집행정지의 효력 발생과 무관하다.

35) 방순원, 민사소송법(하), 보성문화사(1980), 200.

2) 추심권의 범위는 추심명령에 특별한 제한이 없는 한 압류된 채권의 전액에 미치며 집행채권의 범위에 한정되는 것은 아니다(민집 제232조 제1항 본문). 그러나 피압류채권의 일부에 대하여서만 추심명령을 얻을 수도 있다.

이와 같이 추심권의 범위를 집행채권액으로 한정하지 아니한 것은, 만일 이를 한정한다면 제3채무자로 하여금 채무의 분할변제를 강요하는 것으로 되어 전액을 한꺼번에 지급할 수 없는 불편이 생기고, 다른 채권자가 배당요구를 해 올 때 채권자의 지분이 줄어드는 것, 그리고 제3채무자가 파산한 경우와 같이 채권의 명목액대로 실가가 있는지 여부가 불확실한 사정 등을 배려한 것이다.³⁶⁾

3) 한편 채권자의 추심권의 범위와 관련하여, 채권자가 민사집행법 제248조 제3항에 따라 제3채무자에게 공탁청구를 한 경우 이와 같이 공탁청구한 채권자가 제3채무자를 상대로 추심할 수 있는 금액은, 제3채무자가 공탁청구에 따라 그 채권 전액에 해당하는 금액을 공탁하였더라면 공탁청구 채권자에게 배당될 수 있었던 금액 범위에 한정된다는 판례³⁷⁾가 있다. 그러나 이 판례는 문제가 있다.

우선 위 판례는 압류채권자가 추심명령을 받은 상태에서 민사집행법 제248조 제3항에 따라 공탁청구를 한 경우 제3채무자는 당해 조항에 의해 공탁의무를 부담하고 또 그와 같이 공탁에 의해서만 채무를 면하게 되는 것일 뿐이며, 그러한 공탁청구를 했다고 해서 추심채권자의 지위가 바뀌는 것이 아닌데도 아무 근거 없이 이를 달리 취급하고 있다.³⁸⁾ 둘째로, 위 판례는 배당의 범위와 추심의 범위가 다른 것인데, 이를 동일시하고 있는 오류를 범하고 있다. 위 판례의 사례에서 설사 추심채권자가 위 판례의 실시처럼 ‘제3채무자가 공탁청구에 따라 그 채권 전액에 해당하는 금액을 공탁하였더라면 공탁청구 채권자에게 배당될 수 있었던 금액’을 추심하였다고 하더라도 이는 배당절차에서 배당받은 금액이 아니고 단지 추심한 금액에 불과하다. 우리 집행법의 경우 추심채권자는 압류가 경합된 상태에서는 어떠한 경우에도 독점적 이익을 얻지 못하며, 설사 위 판례와 같이 공탁청구한 추심채권자의 추심권의 범위가 ‘제3채무자가 공탁청구에 따라 그 채권 전액에 해당하는 금액을 공탁하였더라면 공탁청구 채권자에게 배당될 수 있었던 금액 범위’로 제한된다고 하더라도 그 돈은 채권자의 추심 후 민사집행법 제236조 제1항에 따라 추심신고를 해야 하는 것이고 또한 압류

36) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 77.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 351-352.

37) 대법원 2012. 2. 9. 선고 2009다88129 판결

38) 즉 공탁청구를 한 추심채권자이든 공탁청구를 하지 않은 추심채권자이든, 추심채권자의 지위에 는 아무런 소장(消長)이 없는 것이며, 그 추심권의 범위에도 차이가 있지 아니하다.

가 경합되어 있으므로 다시 제236조 제2항에 따라 추심공탁 및 사유신고하여 결국 배당절차로 진행되어야 되는 것이며, 그 후 다른 채권자들과 함께 배당절차에서 안분 배당받게 될 뿐인 것이다. 따라서 위 판례는 이후 재고되어야 할 필요가 있다.

4) 추심명령의 효력은 종된 권리, 예컨대 보증인에 대한 채권이나 압류 후의 이자, 손해금에도 당연히 미친다. 그러나 보증인에 대하여는 별도로 추심명령을 발하는 것이 타당할 것이라는 견해도 있다.³⁹⁾

5) 채권의 일부가 압류된 후에 다른 채권자가 그 나머지 부분을 초과하여 다시 압류한 때에는 당해 채권의 전액에 대하여 압류의 효력이 미치게 되기 때문에(민집 제235조 제1항), 이 경우의 추심권의 범위가 문제된다. 원칙적으로 압류의 효력이 확장되어 추심명령에서 특히 한정하지 않는 한 추심권의 범위도 확장된다고 보아야 할 것이다.⁴⁰⁾ ⁴¹⁾ 다만 일부 압류의 부분에 대해서만 추심명령이 발하여진 후에 압류경합이 생긴 때에는 제3채무자가 그 사실을 말하지 않는 한 추심채권자로서는 압류경합의 사실을 판별할 수 없기 때문에 실제로 전의 추심명령에서 정한 범위 이상으로 추심권을 행사하기는 어렵다고 할 것이다. 이와 같은 경우에는 제3채무자가 채무액을 공탁하는 것이 가장 적당하다고 본다.

6) 채권에 대한 가압류 또는 압류명령을 신청하는 채권자는 신청서에 압류할 채권의 종류와 액수를 밝혀야 하고(민집 제225조, 제291조), 특히 압류할 채권 중 일부에 대하여만 압류명령을 신청하는 때에는 그 범위를 밝혀 적어야 한다(민집규 제159조 제1항 제3호, 제218조). 그럼에도 채권자가 가압류나 압류를 신청하면서 압류할 채권의 대상과 범위를 특정하지 않음으로 인해 가압류결정 및 압류명령에서도 피압류채권이 특정되지 않은 경우에는 그 압류 등 결정에 의해서는 압류 등의 효력이 발생하지 않는다. 이러한 법리는 채무자가 제3채무자에 대하여 여러 개의 채권을 가지고 있고, 채권자가 그 각 채권 전부를 대상으로 하여 압류 등의 신청을 할 때에도 마찬가지로 적용되므로, 그 경우 채권자는 여러 개의 채권 중 어느 채권에 대해 어느

39) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 351.

40) 민사집행법 제232조 제1항 본문; 대법원 2004. 7. 22. 선고 2002다22700 판결【판결요지】구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제581조 제1항에 기한 제3채무자의 집행공탁은 피압류채권에 대한 압류경합을 요건으로 하는 것으로서, 이 경우 제3채무자가 위 법 규정에 따라 공탁하여야 할 금액은 채무 전액이라고 할 것이고, 이러한 법리는 압류경합상태에 있는 피압류채권 중 일부에 관하여 일부 압류채권자가 추심명령을 얻은 후 추심금청구소송을 제기하여 승소확정된 경우 제3채무자가 그 추심금청구 사건의 확정판결에 기한 강제집행을 저지하기 위하여 위 법 규정에 따라 집행공탁하는 경우에도 달리 볼 것이 아니다.

41) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 353.

범위에서 압류 등을 신청하는지 신청취지 자체로 명확하게 인식할 수 있도록 특정하여야 한다. 채권의 추심명령은 압류한 금전채권을 대위절차 없이 추심할 수 있게 해주는 것으로서 유효한 압류명령이 있음을 전제하는 것이므로, 압류할 채권이 특정되지 않아 압류명령에 따른 압류의 효력이 발생하지 않는 경우에는 그에 따른 추심명령도 효력이 없다. 그와 같은 경우 채무자는 가압류이거나 즉시항고로써 가압류결정이나 압류 및 추심명령의 효력을 다룰 수 있지만, 제3채무자로서도 추심금 소송에서 추심명령의 무효를 주장하여 다룰 수 있다.⁴²⁾

7) 회사에 대하여 회생절차가 개시되어 회사사업의 경영과 재산의 관리 및 처분을 하는 권리가 관리인에게 전속하게 되어도 회사의 법인격 자체에는 변동이 없고, 특별한 다른 규정이나 사정이 없는 한 그 개시결정 전에 생긴 회사와 제3자 사이의 법률관계는 그대로 유지되는 것이다. 따라서 채무자 회사의 근로자들이 그 임금 등 채권에 기하여 그 회사의 제3채무자에 대한 채권에 대하여 압류 및 추심명령을 받고 적법한 통지까지 마친 후에 그 채무자 회사에 대하여 회생절차가 개시되었다고 하더라도, 종전의 그 회사를 채무자로 하여 이미 이루어진 압류 및 추심명령은 별도의 수계나 승계집행문 또는 경정 없이도 제3채무자나 채무자 회사에 대하여 효력을 가진다.⁴³⁾

나. 추심권의 제한

1) 채무자는 추심할 금액이 채권자의 요구액(집행채권액 + 집행비용)보다 많을 때에는 집행법원에 대하여 압류액을 위 청구액으로 제한하여 줄 것을 신청할 수 있다(민집 제232조 제1항 단서). 채무자를 필요 이상의 구속에서 해방시킴으로써 채무자를 보호하려는 규정이다.

2) 이 신청이 있으면 집행법원은 압류채권자를 심문하여 제3채무자로부터 채권액을 확실히 추심할 수 있는 전망이 있는지 여부를 살핀 다음 채권자의 요구액까지 압

42) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011다38394 판결(채권자인 甲 주식회사의 신청내용대로 가압류와 압류 및 추심할 채권을 '채무자인 乙 주식회사가 丙 주식회사에 대하여 가지는 丁 아파트, 戊 아파트, 己 아파트 신축공사대금채권 중 집행채권액에 해당하는 금액'으로 표시한 가압류결정과 압류 및 추심명령이 있었는데, 가압류결정과 압류 및 추심명령이 丙 회사에 송달될 당시 위 각 신축공사대금채권액의 합계가 집행채권액을 현저히 초과하고 있었던 사안에서, 위 가압류결정과 압류 및 추심명령은 압류의 효력이 위 각 신축공사대금채권 중 어느 신축공사대금채권에 대하여 어느 범위에서 미치는지를 알 수 없는 것으로 압류의 대상 또는 범위가 특정되지 않아 효력이 없다고 판시)

43) 대법원 1996. 9. 24. 선고 96다13781 판결 참조.

류액을 제한하고 나머지에 대한 압류를 풀어 채무자의 처분과 영수를 허용할 수 있다(민집 제232조 제1항 단서).

이 때 채권자가 압류제한신청에 대하여 스스로 동의한 때에는 법원은 당사자의 진술에 구속되어 압류제한을 허가하는 재판을 하여야 한다.⁴⁴⁾ 다른 채권자의 배당요구가 있을 때에는 이것도 채권자의 요구액에 포함시킬 것이지만 무명의(無名義, 집행권원을 가지지 않은) 배당요구채권자는 심문의 상대방이 되지 못한다.⁴⁵⁾

3) 이 제한액에 대하여는 다른 채권자가 배당요구를 할 수 없게 되며(민집 제232조 제2항), 그 한도에서 우선변제를 받는 셈이 된다.

제한의 신청은 압류 후 추심명령발부 전이라도 추심명령발부를 조건으로 할 수 있지만, 제한허가의 결정은 추심명령 후에만 할 수 있다. 채권자평등주의를 채택하고 있는 관계상 배당요구의 기회를 완전히 박탈하지 않으려는 배려이다.⁴⁶⁾

4) 제한허가의 결정⁴⁷⁾은 제3채무자와 채권자에게 통지하여야 하고(민집 제232조 제3항), 그때에 효력이 생긴다. 그 결정은 채무자에게도 고지하여야 한다(민집규 제7조 제2항). 허가가 있는 때에는 추심명령은 전부명령과 거의 같은 기능을 하게 되므로 허가발령 후 통지의 도달 전에 새로운 배당요구가 제3채무자에게 송달된 때에는 그 한도에서 허가의 재판은 효력을 상실한다고 보아야 할 것이다.⁴⁸⁾

2. 채권자의 지위

가. 추심권의 행사

추심명령을 받은 채권자는 압류채권의 추심에 필요한 채무자의 일체의 권리를 채무자에 갈음하여(채무자를 대리하거나 대위하지 않고) 자기 명의로 재판상 또는 재판 외에서 행사할 수 있다.

1) 재판 외의 행사

가) 채권자로서의 권리행사 : 채권자는 이행의 최고·선택권의 행사·보증인에 대한 청구·담보권의 실행·변제의 수령 등을 할 수 있지만, 추심의 목적을 넘는 행위 예

44) 대법원 1977. 2. 8. 자 76마497 결정; 이재성, “압류액 제한신청과 채권자의 동의”, 민사재판의 이론과 실제Ⅲ, 375, 이하 참조

45) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 352.

46) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 352.

47) 별지서식 [4-10] 추심액의 제한허가결정 참조(제4장 말미 수록)

48) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 352.

컨대 채무의 면제·포기·기한의 유예·화해·채권의 양도 등은 이를 할 수 없다.⁴⁹⁾

추심할 채권에 질권, 저당권 등 담보권이 있는 경우(민집 제228조)에는 직접 담보권을 실행할 권능을 취득하게 되므로 자기 이름으로 담보권실행을 위한 경매를 신청할 수 있다.

나) 추심할 채권이 반대급부에 걸려있는 때 : 이 경우에는 특별한 현금화방법(민집 제241조)에 의할 수 있지만 채권자가 채무자에 갈음하여 그 급부를 이행한 다음 추심할 수 있다.⁵⁰⁾ 이 경우 반대급부에 제공된 비용은 통상의 것이 아닌 한 집행비용으로 되지 아니한다.⁵¹⁾

다) 대물변제의 수령 : 이에 관하여는 상당한 가격일 것을 요건으로 하여 가능하다는 설⁵²⁾이 있으나, 상당한 가격인지의 여부를 판별하기가 어려워 다툼의 여지가 많고 평등주의에 기초한 추심권의 한계를 넘는 행위에 속한다고 보이므로 부정적으로 해석함이 타당하다고 본다.⁵³⁾

라) 상계의 문제 : 채권자가 압류한 채권을 자동채권으로 하여 제3채무자에 대한 자신의 채무와 상계할 수 있는가에 대하여는 부정설⁵⁴⁾도 있으나, 이것을 긍정하는 것이 일반적 견해이다.⁵⁵⁾

그러나 우선주의를 취하는 독일과 달리 평등주의를 취하고 있는 우리의 법제하에서는 추심채권자의 상계권 행사를 무조건으로 인정할 수는 없을 것이다. 즉 상계를 원인으로 한 추심의 신고가 있기까지 다른 채권자가 이중압류 또는 배당요구를 하였을 경우가 문제인데, 이 때는 상계가 무효로 된다는 설⁵⁶⁾과 이들이 받을 배당금액은 추심채권자가 자신의 돈으로 제공하여야 한다는 설⁵⁷⁾이 있으나, 전자가 다수의 견해이다.

마) 해제권·취소권의 행사 : 이에 대하여는 대부분의 학설⁵⁸⁾이 이를 긍정하면서,

49) 이영섭(주29), 172.; 방순원(주35), 201.; 이영섭 대표, 위 주식강제집행법(中), 78.; 兼子—(주4), 208.; 三ヶ月章, 民事執行法, 弘文堂(1981), 381.

50) 이영섭(주29), 172-173.; 宮脇幸彦(주6), 146.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 354.

51) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 354.

52) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 353.

53) 宮脇幸彦(주6), 146.

54) 中田淳一, 民事訴訟法概説, 有斐閣, 30.

55) 방순원(주35), 201.; 이영섭 대표, 위 주식강제집행법(中), 78.; 宮脇幸彦(주6), 146.; 菊井維大(주7), 179.; Stein-Jonas(19. Aufl.) §835, 2b 참조

56) 이영섭 대표, 위 주식강제집행법(中), 78.; 宮脇幸彦(주6), 151.

57) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 353.

58) 이영섭 대표, 위 주식강제집행법(中), 78.; 兼子—(주4), 208.; 菊井維大(주7), 179.; 中務(주16), 1184. 등

그 예로 정기예금을 압류하고 추심명령을 얻어 만기 전에 해약하는 경우를 들고 있다. 판례는 보험계약자의 해약환급금청구권에 대하여 압류 및 추심명령을 받은 채권자가 추심권에 기하여 자기 이름으로 보험계약을 해지할 수 있다고 보고 있다.⁵⁹⁾

그러나 취소권의 행사에 의하여 채권이 소멸하는 경우에는 그것이 허용되지 아니하고, 또 취소·해제에 의하여 발생하는 조건부권리를 압류한 때에는 그것으로 당연히 해제권·취소권을 행사할 수 있는 것으로는 되지 아니한다는 이유로 이를 부정하는 견해도 있다.⁶⁰⁾

바) 공탁금출급 또는 회수청구권에 대하여 추심명령을 받은 때 : 이 경우 채권자는 추심명령정보 및 그 송달증명서를 첨부하여 공탁관에게 공탁금의 출급 또는 회수를 청구하면 되고 별도로 공탁서나 공탁통지서를 첨부할 필요는 없다(공탁규칙 제32조, 제33조, 제34조).

재판상 담보로 제공된 공탁금의 회수청구권에 대하여 추심명령을 얻은 경우에는 채권자는 담보취소의 결정을 받아 이를 추심명령정보와 함께 공탁관에게 제출하여야 한다.

사) 제3채무자에 관하여 파산·회생절차 등이 개시된 때 : 이 경우에는 추심채권자가 그 절차에 참가하여 채권 신고를 하고 배당을 받을 수 있다.⁶¹⁾

의결권에 관하여는 채무자와 공동으로 행사하여야 한다는 견해⁶²⁾와 독일과 달리 채권자대위권제도가 있기 때문에 단독행사가 가능하다는 견해⁶³⁾로 나뉘어지고 있으나, 실무는 후자의 견해를 취하는 것으로 보인다.⁶⁴⁾

2) 재판상의 청구

가) 압류채권자는 추심명령을 얻은 후 제3채무자가 추심절차에 대하여 의무를 이행하지 아니하는 때에는 소로써 그 이행을 청구할 수 있다(민집 제238조, 제249조 제1항).⁶⁵⁾ 이와 같이 채권자가 추심명령에 의한 채무를 이행시키기 위하여 제3채무

59) 대법원 2009. 6. 23. 선고 2007다26165 판결(해약환급금청구권에 대한 추심명령을 얻은 채권자가 추심명령에 기하여 제3채무자를 상대로 추심금의 지급을 구하는 소를 제기한 경우 그 소장에는 추심권에 기초한 보험계약 해지의 의사가 담겨 있다고 할 것이므로 그 소장 부분이 상대방인 보험자에 송달됨에 따라 보험계약 해지의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 상당하다고 판시)

60)鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 353-354.

61) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 95.; 宮脇幸彦(주6), 147.;鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 355.

62) 독일의 통설적 견해로 보인다;鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 355.

63) 宮脇幸彦(주6), 147.

64) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 371.

65) 일부청구도 가능하다(대법원 1971. 11. 9. 선고 71다1941 판결).

자를 피고로 하여 제기하는 소송을 추심소송이라고 한다.

채권에 대한 압류 및 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만 제기할 수 있고 채무자는 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실한다.⁶⁶⁾ 다만 채권자가 추심명령을 취하하거나 현금화절차가 끝나기 전에 압류명령의 신청을 취하하면 채권자의 추심권도 당연히 소멸하게 되며, 추심금청구소송을 제기하여 확정판결을 받은 경우라도 그 집행에 의한 변제를 받기 전에 압류명령의 신청을 취하여 추심권이 소멸하면 추심권능과 소송수행권이 모두 채무자에게 복귀하며, 이는 국가가 국세징수법에 의한 채납처분으로 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 압류하였다가 압류를 해제한 경우에도 마찬가지이다.⁶⁷⁾

2인 이상의 불가분채무자 또는 연대채무자(이하 ‘불가분채무자 등’이라 한다)가 있는 금전채권의 경우에, 그 불가분채무자 등 중 1인을 제3채무자로 한 채권압류 및 추심명령이 이루어지면 그 채권압류 및 추심명령을 송달받은 불가분채무자 등에 대한 피압류채권에 관한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고 추심채무자는 그 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실하지만, 그 채권압류 및 추심명령의 제3채무자가 아닌 나머지 불가분채무자 등에 대하여는 추심채무자가 여전히 채권자로서 추심권한을 가지므로 나머지 불가분채무자 등을 상대로 이행을 청구할 수 있고, 이러한 법리는 위 금전채권 중 일부에 대하여만 채권압류 및 추심명령이 이루어진 경우에도 마찬가지이다.⁶⁸⁾

이와 같은 당사자적격에 관한 사항은 소송요건에 관한 것으로서 당사자가 주장하지 않더라도 법원이 이를 직권으로 조사하여 판단하여야 하고,⁶⁹⁾ 비록 당사자가 사실심 변론종결시까지 이에 관해 주장하지 아니하였다고 하더라도 상고심에서 새로이 이를 주장·입증할 수 있다.^{70) 71)}

66) 대법원 2000. 4. 11. 선고 99다23888 판결; 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007다60417 판결; 대법원 2010. 2. 25. 선고 2009다85717 판결; 대법원 2010. 11. 25. 선고 2010다64877 판결 등

67) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2009다48879 판결

68) 대법원 2013. 10. 31. 선고 2011다98426 판결

69) 대법원 2010. 11. 25. 선고 2010다64877 판결

70) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007다60417 판결; 대법원 2010. 11. 25. 선고 2010다64877 판결

71) 한편 가집행선고부 제1심판결을 집행권원으로 한 채권압류 및 추심명령을 받은 추심채권자가 제3채무자를 상대로 추심금의 지급을 구하는 소를 제기한 후 그 집행권원인 제1심판결에 대하여 강제집행정지 결정이 있을 경우, 위 결정의 효력에 의하여 집행절차가 중지되어 추심채권자는 피압류채권을 실제로 추심하는 행위에 더 이상 나아갈 수는 없으나(대법원 2005. 11. 8.자 2005마992 결정), 이와 같은 사정만으로 제3채무자의 추심금 지급에 관한 소송절차가 중단된다고 볼 수는 없을 뿐 아니라 이로 인해 제3채무자가 압류에 관련된 금전채권의 전액을 공탁함으로써 면책받을 수 있는 권리가 방해받는 것도 아니므로, 법원은 그대로 판결을 선고할 수 있다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2009다70067 판결).

나) 민법 제487조 후단에 따른 채권자의 상대적 불확지를 원인으로 하는 변제공탁의 경우 피공탁자 중의 1인은 다른 피공탁자의 승낙서나 그를 상대로 받은 공탁물 출급청구권확인 승소확정판결을 제출하여 공탁물출급청구를 할 수 있는바, 상대적 불확지 변제공탁의 피공탁자 중 1인을 채무자로 하여 그의 공탁물출급청구권에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받은 추심채권자는 공탁물을 출급하기 위하여 자기의 이름으로 다른 피공탁자를 상대로 공탁물출급청구권이 추심채권자의 채무자에게 있음을 확인한다는 확인의 소를 제기할 수 있다.⁷²⁾

다) 추심채권자는 민사집행법 제248조 제3항에 의하여 채무액의 공탁의무를 지는 제3채무자인 채무자를 상대로 추심명령을 받은 압류채권자의 지위에서 민사집행법 제249조 제1항에 따라 그 채무액의 공탁을 구하는 추심의 소를 제기하여 '피고(제3채무자)는 원고(채권자)에게 금 ○○○원을 지급하라. 위 금원의 지급은 공탁의 방법으로 하여야 한다'는 내용의 판결을 선고받을 수 있다. 이 경우 채권자가 제기한 위 추심의 소는 공탁의 방법에 의하여 채무액의 추심을 구하는 이행청구의 소이고 이를 인용한 판결은 공탁의 방법에 의한 추심금 지급을 명하는 이행판결이므로 채권자는 위 판결 정본을 집행권원으로 한 강제집행으로서 제3채무자가 가진 금전채권을 압류·추심할 수 있다.⁷³⁾

라) 제3채무자를 상대로 공탁의 방법에 의한 추심금의 지급을 구하는 소를 제기하여 승소한 채권자는, 그 판결을 집행권원으로 제3채무자가 가진 금전채권을 압류·추심할 수 있다.⁷⁴⁾

마) 이와 같은 추심소송에 관하여는 제3절 추심소송에서 자세히 살펴보기로 한다.

나. 추심의 의무

1) 추심 해태로 인한 손해배상책임

가) 추심명령을 얻은 채권자는 채무자에 대한 관계에서 그 채권을 적당한 시기에

72) 대법원 2011. 11. 10. 선고 2011다55405 판결

73) 대법원 2009. 5. 28.자 2007마767 결정

74) 대법원 2009. 5. 28.자 2007마767 결정. 이러한 법리는 추심명령을 얻어 추심을 마친 채권자가 민사집행법 제236조 제2항에 따라 공탁해야 함에도 불구하고 공탁을 하지 않는 경우, 다른 (가)압류채권자가 공탁의 이행을 구하는 소를 제기하여 승소한 경우에도 그대로 적용된다(이 경우 공탁해야 할 금액의 범위에 대하여는 대법원 2005. 7. 28. 선고 2004다8753 판결과 대법원 2007. 11. 15. 선고 2007다62963 판결 참조).

적당한 방법으로 추심할 의무를 지고, 채권자가 추심할 채권의 행사를 게을리 한 때에는 이로써 생긴 채무자의 손해를 부담한다(민집 제239조).

이를 인정하는 이유는, 압류 및 추심명령이 있으면 채무자는 압류된 채권의 행사에 제약을 받게 되는 반면 채권자는 추심권에 기초하여 압류한 채권을 행사할 수 있게 되는데, 이 경우 채권자는 채무자를 위하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 채권을 행사하여야 하며, 채권자가 그러한 채권행사의 의무를 게을리함으로써 채무자에게 손해를 끼쳤을 때에는 손해배상의 책임을 지도록 하는 것이 당사자 사이의 이익 균형상 적절하기 때문이다.⁷⁵⁾

나) 채권의 행사를 게을리한 경우란, 어음의 제시, 지급거절증서의 작성 등을 해태하여 소구권을 상실하는 것, 추심소송의 제기를 지체하여 소멸시효가 완성되는 것, 가압류 또는 본집행의 지체로 인하여 제3채무자가 자력이 없어지는 것,⁷⁶⁾ 추심소송을 졸렬하게 수행하여 패소하는 것⁷⁷⁾ 등을 들 수 있다.

채권자가 압류명령만 신청하고 장기간 추심명령이나 전부명령을 신청하지 아니하여 압류채권이 시효소멸하는 경우도 본조를 유추적용할 수 있을 것이다.⁷⁸⁾

그러나 추심권을 취득함에 불과한 압류채권자는 채무자를 대신하여 제3채무자의 채무를 면제할 수 없기 때문에, 가령 압류채권자가 제3채무자에 대하여 면제의 의사 표시를 하더라도 피압류채권이 소멸하는 것은 아니므로 채무자에게 손해는 생기지 않는다.

다) 압류채권자가 추심을 소홀히 하여 채무자에게 손해가 생긴 경우, 채무자는 압류채권자에 대하여 손해배상청구권을 취득한다.

이 청구권을 채권집행절차 내에서 실현하기에는 용이하지 않으므로 압류채권자가 임의로 손해배상청구에 응하지 않은 때에는 소를 제기하여 집행권원을 얻을 필요가 있다. 이때 입증책임의 분배는 채무불이행에 의한 손해배상청구소송에 있어서의 그것과 동일하다고 볼 것이다.

또한 채무자는 상계가 금지되는 일반적인 경우에 해당되지 않는 한, 이 손해배상청구권을 자동채권으로 하고 압류채권자의 채무자에 대한 집행채권을 수동채권으로 하여 상계할 수 있고, 상계를 한 때는 청구이익의 소에 의하여 집행권원의 집행력을

75) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 97.; 宮脇幸彦(주6), 148.

76) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 97.; 宮脇幸彦(주6), 148.

77) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 174.; 兼子一(주4), 209.

78) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 97-98.

배제할 수 있게 된다.⁷⁹⁾

2) 추심의 최고

집행력 있는 정본에 의한 배당요구채권자에 대하여 민사집행법 제250조는 능동적으로 강제집행절차의 일부인 추심절차를 수행할 수 있는 길을 열어 놓고 있다.

즉 압류채권자가 추심절차 다시 말하자면 추심명령의 취득, 제3채무자에 대한 추심소송의 제기, 강제집행 등 추심행위를 지체하고 있는 경우에 위와 같은 배당요구채권자는 압류채권자에 대하여 일정한 기간 내에 추심할 것을 최고할 수 있다.⁸⁰⁾

배당요구채권자는 압류채권자가 아니므로 추심명령을 구할 수 없기 때문에 이러한 최고권을 인정한 것이며 집행력 있는 정본에 의하지 아니한 배당요구채권자에게는 위 최고권이 없다. 그 밖의 압류채권자의 경우에는 스스로 추심명령을 얻어 추심할 수 있으므로 최고권을 인정할 필요가 없다.

여기서 일정한 기간이라고 하는 것은 압류채권자가 추심할 수 있는 상당한 기간을 말한다. 최고의 방식에 관하여는 특별한 규정이 없으나 최고의 유무는 집행법원의 추심허가를 얻을 때 증명할 필요가 있기 때문에 내용증명우편과 같은 확실한 방법으로 통지하는 것이 좋을 것이다.

3) 추심허가의 재판

채권자의 최고에도 불구하고 압류채권자가 이에 응하지 아니한 때에는 집행법원에 대해 추심허가의 재판을 구할 수 있다(민집 제250조).⁸¹⁾

이 허가의 재판은 압류채권자의 집행절차가 어느 단계에 있거나 신청할 수 있다. 다만 압류채권자가 이미 추심소송을 제기하고 있는 때에는 집행력 있는 정본을 가진 배당요구채권자는 그 소송에 공동소송참가를 하면 된다.

집행법원은 압류채권자를 심문하여 최고기간이 적당하고 압류채권자가 추심절차를 게을리하고 있는지를 조사하여 이유 있다고 인정되면 추심허가의 재판을 한다.⁸²⁾ 이 재판은 위 배당요구채권자에게 고지함으로써 추심권수여의 창설적 효력이 생긴다.

그리하여 압류채권자가 이미 추심명령을 얻고 있었다면 위 재판으로 인하여 압류채권자는 추심권을 상실하고 그 추심권은 허가받은 배당요구채권자에게 이전되며, 압류채권자가 추심명령을 얻지 아니한 상태에 있었다더라도 허가를 받은 배당요구채권

79) 松岡義正, 強制執行要論(中), 清水書店(1935), 1186.

80) 별지서식 [4-8] 채권추심신고서 참조(제4장 말미 수록)

81) 별지서식 [4-11] 압류채권추심의 허가신청(채권압류 및 추심명령) 참조(제4장 말미 수록)

82) 宮脇幸彦(주6), 228.

자는 위 재판에 의하여 별도의 추심명령 없이 추심권을 취득한다.

추심허가의 재판에 의하여 부여된 추심권은 압류채권자의 압류명령 또는 추심명령이 나중에 실효되더라도 영향을 받지 않는다.⁸³⁾ 따라서 위 배당요구채권자는 다시 추심명령을 얻지 않고도 추심절차를 개시하거나 속행할 수 있다.

추심허가를 받은 배당요구채권자가 추심할 채권의 행사를 게을리 한 때에는 이로 인한 채무자의 손해를 배상할 책임을 진다(민집 제239조).

다. 추심권의 포기과 효과

1) 추심권의 포기

가) 채권자는 추심명령에 의하여 취득한 추심권의 전부 또는 일부를 포기할 수 있다(민집 제240조 제1항 본문).⁸⁴⁾

이 경우에 추심명령은 당연히 실효되며 취소결정을 할 필요가 없다.⁸⁵⁾ 추심권의 포기로 인하여 기본채권(집행채권)에는 영향이 없다(민집 제240조 제1항 단서).

나) 추심권의 포기는 압류효력의 포기를 포함하여 그 범위에서 압류의 효력도 소멸한다는 설⁸⁶⁾이 있으나, 추심권을 포기하고 전부명령 그 밖에 다른 현금화방법을 취하거나 당사자간의 타협을 위하여 일시 추심을 중지할 의사로서 추심권을 포기하는 경우도 있으므로 추심권의 포기만으로서는 당연히 압류의 효력이 소멸된다고 보기 어렵다.⁸⁷⁾

따라서 추심권 뿐만 아니라 압류에 의한 권리 그 자체를 포기하기 위해서는 압류명령의 신청을 취하하면 된다. 이때에는 추심권도 당연히 소멸하게 된다.

다) 압류채권자는 추심명령을 얻은 뒤에도 다시 동일한 채권에 관하여 전부명령을 얻을 수 있는데⁸⁸⁾ 이 전부명령에 의하여 압류한 채권은 채권자에게 이전되므로 추심명령은 당연히 소멸되고 따라서 이 경우에는 추심권을 포기할 필요가 없다.

또한 민사집행법 제241조에 의한 특별현금화명령을 얻는 경우에도 추심권을 사

83) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 376.

84) 별지서식 [4-12] 압류취하 및 추심포기서 참조(제4장 말미 수록)

85) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 98.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 411.; 宮脇幸彦(주6), 149.(단, 宮脇은 추심권의 포기가 있는 경우 법률관계에 대하여 의문이 생기는 것을 피하기 위해 집행법원이 추심명령의 취소결정을 하여도 무방하다고 한다).

86) 兼子一(주4), 207.; 中務(주16), 1185.

87) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 98.; 宮脇幸彦(주6), 149.; 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 377.

88) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 98.; 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 376.

전에 포기할 필요가 없다.

압류채권자가 동일한 집행채권에 기초하여 과잉집행 금지의 제한(민집 제188조 제2항 참조)을 거스르지 않고 채무자의 다른 재산에 대하여 강제집행을 하기 위해서는 추심권의 포기만으로는 부족하고 압류명령신청의 취하가 필요하므로 압류명령이 존속하는 상태에서의 추심권의 포기는 그 필요가 적다. 따라서 집행법원은 추심권포기의 신고가 있는 때에는 그 취지를 확인하여 경우에 따라 압류명령신청의 취하를 권고하는 것이 바람직하다.⁸⁹⁾

2) 포기의 신고 및 효과

추심권의 포기는 채권자가 집행법원에 서면으로 신고하여야 한다(민집 제240조 제2항). 추심권포기 신고서에는 인지를 붙일 필요가 없고 이를 접수한 때에는 재판사무시스템의 문서건명부에 입력한 후 집행기록에 가철한다.⁹⁰⁾ 추심명령을 얻은 채권자가 추심금청구소송 중 그 청구액을 감축하였다 하여 추심권의 포기라고는 볼 수 없다.⁹¹⁾

이 경우 포기의 효력이 어느 때 생기느냐에 대하여는 견해의 대립이 있다. 즉 포기신고서가 집행법원에 제출된 때에 그 효력이 생기지만 제3채무자가 포기신고를 모르고 추심명령을 전제로 한 행위는 유효하다는 견해⁹²⁾와 민사집행법 제227조 제3항의 규정을 유추하여 제3채무자에 대한 송달로써 효력이 생긴다는 견해⁹³⁾가 있는데, 전자가 타당하다고 본다.

추심권의 포기신고가 있으면 법원사무관등은 그 포기신고서의 등본을 제3채무자와 채무자에게 송달하여야 한다(민집 제240조 제2항). 따라서 채권자는 포기신고서의 등본을 채무자와 제3채무자의 수만큼 제출하여야 한다. 제3채무자에 대한 송달은 공식송달도 가능하다.

추심소송을 제기한 후에 추심권의 포기가 있으면 추심권능과 소송수행권이 모두

89) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 98.

90) 재판예규 제873호, “민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규(재민 91-1)”

91) 대법원 1983. 8. 23. 선고 83다카450 판결【판결요지】[1] 압류채권에 대한 추심명령을 받아 추심금 청구소송을 제기, 진행중 청구금액을 감축한 것은 소의 일부취하를 뜻하는 것이고 취하된 부분의 청구를 포기하였다고는 볼 수 없으며, 위 채권압류는 추심하고 남은 잔여채권에 대하여 그 효력을 지속하는 것이다. [2] 압류가 경합된 상태에서 발부된 전부명령은 효력이 없다 할 것이다.

92) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 99.; 宮脇幸彦(주6), 149.; 압류의 포기에 관한 日大判 昭和 16(1941). 5. 31.(民集 20, 765)도 같은 취지이다.

93) 兼子一(주4), 200.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 411.

채무자에게 복귀한다. 추심권의 포기는 앞서 보았듯이 기본채권(집행채권)에 영향을 미치지 아니하므로(민집 제240조 제1항 단서), 추심권의 포기는 청구이의의 소(민집 제44조)의 사유가 되지 아니하고, 다만 집행에 관한 이의(민집 제16조)의 사유가 될 수 있을 뿐이다. 제3채무자는 추심권의 포기를 항변으로 주장할 수 있다.

추심권의 포기가 있더라도 민사집행법 제239조에 의하여 이미 발생한 채권자의 채무자에 대한 손해배상의무에는 영향을 미치지 아니한다. 추심권의 포기가 있는 경우 그때까지 발생한 추심에 소요된 비용은 불필요한 것이 되어 버리므로 이는 채무자에게 부담시킬 수 없고, 채권자가 부담하여야 한다.

3. 채무자의 지위

채무자는 추심명령 후에도 피압류채권의 주체임에는 변함이 없지만 압류에 의한 처분금지의 효력을 받는다.

따라서 추심명령이 있으면 피압류채권에 대한 이행소송은 물론 확인소송도 제기하거나 수행할 권한을 잃는다(당사자자격 상실).⁹⁴⁾ 그렇지 않으면 채권자와 채무자가 각별로 피압류채권에 관한 소송을 제기할 수 있기 때문에 후에 제기한 소송이 이중소송으로 되어 채권자의 추심소송이 방해될 수 있고 한편 채무자에게는 채권자의 추심소송에 보조참가할 기회가 부여되어 있기 때문에 채무자가 제기하고 수행하는 소송은 유해무익한 것이기 때문이다.⁹⁵⁾ 그러나 채무자가 소를 제기하여 판결을 받는 것은 변제의 수령이 아니므로 전면적으로 허용될 것이라는 견해⁹⁶⁾ 등도 있다[이에 대하여는 제3장 압류명령 제2절 V. 3. 가. 2) 나) 이하에서 자세히 살펴본 바 있다].

이와 관련하여 판례⁹⁷⁾는 국세채납처분에 의한 채권압류의 경우에 채납자는 압류

94) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007다60417 판결(위와 같은 당사자자격에 관한 사항은 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결시를 기준으로 법원이 이를 직권으로 조사하여 판단하여야 하고, 비록 당사자가 사실심 변론종결시까지 이에 관하여 주장하지 아니하였다고 하더라도 상고심에서 새로이 이를 주장, 입증할 수 있다); 이영섭 대표, 위 주식강제집행법(中), 79.; 兼子—(주4), 209.; 宮脇幸彦(주6), 149.; 따라서 추심명령 후에 채무자가 제기한 소송은 소송수행권이 없는 자의 제소를 이유로 각하되고 추심명령 전에 제기한 소송은 민소법 제81조, 제79조에 의해 채권자에 의한 소송승계의 대상이 된다.

95) 宮脇幸彦(주4), 150.

96) 방순원(주35), 197.

97) 대법원 1983. 3. 8. 선고 82다카889 판결【판결요지】국세채납으로 인하여 채권압류가 있는 경우에는 채무자는 채권자에게 채무를 지급할 수 없고 오직 소관 세무공무원에만 지급하여야 할 것이고 채납자인 채권자는 그 압류된 채권을 행사할 수 없다고 할 것이므로 그 채권의 지급조로 발행된 약속어음의 수취인인 채권자는 어음금의 지급청구권을 행사할 수 없다.

된 채권을 행사할 수 없으므로 제3채무자에 대한 이행의 소는 인용될 수 없다고 하고 있다. 또한 같은 이유로 채무자는 추심명령 후에 파산·회생절차에 대한 채권신고를 할 수 없다고 본다.⁹⁸⁾

다만 채권자는 이행소송의 계속 중 또는 현금화절차가 끝나기 전까지 압류명령의 신청을 취하할 수 있고, 이 경우 채권자의 추심권도 당연히 소멸하게 되며, 이러한 취하 등에 따라 추심권능을 상실하게 되면 채무자의 당사자적격이 회복된다.⁹⁹⁾ 또한 추심금 청구소송을 제기하여 확정판결을 받은 경우라도 그 집행에 의한 변제를 받기 전에 압류명령의 신청을 취하하여 추심권이 소멸하면 추심권능과 소송수행권이 모두 채무자에게 복귀하며, 이는 국가가 국세징수법에 의한 체납처분으로 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 압류하였다가 압류를 해제한 경우에도 마찬가지이다.¹⁰⁰⁾

채무자는 추심명령을 얻은 채권자의 추심을 용이하게 하기 위하여 그가 소지한 채권에 관한 증서를 채권자에게 인도하여야 한다(민집 제234조 제1항). 채권의 일부에 대하여 추심명령이 있는 경우도 같다. 만일 채무자가 이에 응하지 아니하면 채권자는 압류명령에 의하여 강제집행의 방법으로 그 증서의 인도를 받을 수 있다(민집 제234조 제2항).

채무자는 추심명령이 위법인 때에는 집행에 관한 이의(민집 제16조)를 신청하고 이 이의의 재판에 불복이 있으면 즉시항고를 할 수 있다. 또한 채무자는 압류제한신청을 할 수 있고 채권자가 추심할 채권의 행사를 해태한 때에는 이로 인한 손해의 배상을 청구할 수 있다.

4. 제3채무자의 지위

가. 추심채권자에 대한 채무 변제

제3채무자는 추심채권자에게 채무를 변제하여야 한다. 다만 배당에 참가한 채권

98) 宮脇幸彦(주6), 150.

99) 대법원 2010. 11. 25. 선고 2010다64877 판결. 이러한 사정은 직권조사사항으로서 당사자가 주장하지 않더라도 법원이 직권으로 조사하여 판단하여야 한다. 당사자적격을 그르친 판결은 원래의 당사자적격을 가지는 사람에게는 효력이 없다. 즉 무효이다(통설).

100) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2009다48879 판결. 한편 채권자가 금전채권의 가압류를 본압류로 이전하는 압류 및 추심명령을 받아 본집행절차로 이행한 후 본압류의 신청만을 취하함으로써 본집행절차가 종료한 경우, 특단의 사정이 없는 한 그 가압류집행에 의한 보전 목적이 달성된 것이라거나 그 목적 달성이 불가능하게 된 것이라고는 볼 수 없으므로 그 가압류집행의 효력이 본집행과 함께 당연히 소멸되는 것은 아니라고 할 것이니, 채권자는 제3채무자에 대하여 그 가압류집행의 효력을 주장할 수 있다(대법원 2000. 6. 9. 선고 97다34594 판결).

자의 청구가 있는 때(민집 제248조 제2항)나 압류가 경합된 경우에 다른 채권자의 청구가 있는 때(민집 제248조 제3항)에는 채무액을 공탁하지 않으면 안 된다. 이러한 경우에 직접 추심채권자에게 변제하면 이로 인한 손해를 배상할 의무를 부담한다.

배당에 참가한 다른 채권자가 있는 경우라도 그로부터 공탁청구가 없는 한 추심채권자에게 채무의 전액을 지불하면 면책되지만, 공탁하는 것이 그 외의 다른 채권자들에게 이익이 될 수 있을 것이다.

추심명령은 압류채권자에게 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 추심할 권능을 수여함에 그치고, 제3채무자로 하여금 압류채권자에게 압류된 채권액 상당을 지급할 것을 명하거나 그 지급 기한을 정하는 것이 아니므로, 제3채무자가 압류채권자에게 압류된 채권액 상당에 관하여 지체책임을 지는 것은 집행법원으로부터 추심명령을 송달받은 때부터가 아니라 추심명령이 발령된 후 압류채권자로부터 추심금 청구를 받은 다음날부터라고 하여야 한다.¹⁰¹⁾

나. 실체상 사유 및 절차상 하자의 주장

1) 추심명령이 발부된 후에도 제3채무자는 종래와 같이 채무자에 대하여 채무를 부담하고 있는 것이며, 직접 집행채권자의 채무자로 되는 것이 아니기 때문에 집행채무자에게 주장할 수 있는 실체상의 사유 및 압류·추심명령의 집행절차상의 하자로 집행채권자에게 대항할 수 있다.¹⁰²⁾

2) 그 중 실체상의 사유로는 피압류채권의 압류금지,¹⁰³⁾ 피압류채권의 부존재 또는 소멸, 압류 전 피압류채권의 양도, 변제기의 미도래 및 동시이행의 항변권 등이 있다.

상계의 경우에는 제3채무자의 자동채권이 압류 전에 취득한 것이어야 한다(민법 제498조). 다만 위 민법 제498조를 적용함에 있어서는, 수동채권(압류된 채권) 및 자동채권의 변제기와 압류의 시기와의 관계가 문제로 되는데, 즉 자동채권, 수동채권의 변제기와 관련하여 압류명령의 송달을 받기 이전에 상계적상에 있어야 하는가, 특히 자동채권의 변제기가 도래하고 있어야 하느냐에 대하여 견해가 나뉘어지는 것이다.

101) 대법원 2012. 10. 25. 선고 2010다47117 판결

102) 三ヶ月章(주49), 391.

103) 근로자퇴직급여 보장법상 퇴직연금제도의 급여를 받을 권리는 양도가 금지되고 그 금지규정은 강행법규에 해당하므로 이에 대한 압류명령은 실체법상 무효이고, 제3채무자는 그 압류채권의 추심금청구에 대하여 위 무효를 들어 지급을 거절할 수 있다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013다 71180 판결).

이에 관하여 다수설¹⁰⁴⁾은 압류 전에 취득한 채권이라면 압류할 때 상계적상에 있었든 없었든 묻지 아니하고 상계적상시에 상계할 수 있다는 입장이다.

그리고 종전의 판례¹⁰⁵⁾는 이에 대해 상계적상에 있어야 한다는 취지였으나, 현재에는 압류명령이 송달될 당시 제3채무자가 채무자에 대하여 가지는 채권(자동채권)과 압류된 채권(수동채권)이 모두 변제기에 도래하여 상계적상에 있었던 경우는 물론 상계적상에 있지 아니한 경우에도 자동채권만이 변제기가 지났거나, 또는 두 채권 모두 변제기가 지나지 않았더라도 자동채권이 먼저 또는 압류된 채권과 동시에 변제기에 도달할 경우에는 제3채무자의 상계를 허용하고 있다.¹⁰⁶⁾ 나아가 제3채무자의 압류채무자에 대한 자동채권이 수동채권인 피압류채권과 동시이행의 관계에 있는 경우에는, 압류명령이 제3채무자에게 송달되어 압류의 효력이 생긴 후에 자동채권이 발생하였다고 하더라도 제3채무자는 동시이행의 항변권을 주장할 수 있고, 따라서 그 채권에 의한 상계로 압류채권자에게 대항할 수 있다.^{107) 108)}

이 경우 상계의 의사표시는 추심채권자 또는 채무자의 어느 쪽에 해도 된다고

104) 이영섭 대표, 위 주식강제집행법(中), 79.; 兼子—(주4), 209.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 303.; 日最判 昭和 45(1970). 6. 24.(民集 24-6, 587)

105) 대법원 1980. 9. 9. 선고 80다939 판결【판결요지】① 채권압류 및 전부명령에 있어 제3채무자는 그 명령이 송달되기 이전에 채무자에 대하여 상계적상에 있었던 반대채권을 가지고 그 명령이 송달된 이후에 상계로서 전부채권자에게 대항할 수 있다. ② 이 경우의 상계적상이라 함은 양 채권이 모두 그 변제기가 도래한 경우와 그 수동채권의 변제기가 도해하지 아니하였다 하더라도 그 기한의 이익을 포기할 수 있는 경우를 포함하지만 자동채권의 변제기가 위 명령송달 이전에 도래하지 아니한 경우는 상계적상에 있는 것이라고 할 수 없다.

106) 대법원 1973. 11. 13. 선고 73다518 전원합의체 판결; 대법원 1982. 6. 22. 선고 82다카 200 판결【판결요지】가압류 명령을 받은 제3채무자가 가압류 채무자에 대한 반대채권을 가지고 있는 경우에 상계로써 가압류 채권자에게 대항하기 위하여는 가압류의 효력발생 당시에 양 채권이 상계적상에 있거나, 반대채권이 압류 당시 변제기에 이르지 않는 경우에는 피압류 채권인 수동채권의 변제기와 동시에 또는 보다 먼저 변제기에 도달하는 경우이어야 된다.; 대법원 1989. 9. 12. 선고 88다카25120 판결【판결요지】채권가압류명령을 받은 제3채무자는 그 후에 취득한 채권에 의한 상계로 그 가압류채권자에게 대항하지 못하지만 수동채권이 가압류될 당시 자동채권과 수동채권이 상계적상에 있거나 자동채권의 변제기가 수동채권의 그것과 동시 또는 그보다 먼저 거래하는 경우에는 제3채무자는 자동채권에 의한 상계로 가압류채권자에게 대항할 수 있다.; 대법원 2012. 2. 16. 선고 2011다45521 전원합의체 판결

107) 대법원 1993. 9. 28. 선고 92다55794 판결; 대법원 2001. 3. 27. 선고 2000다43819 판결; 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004다37676 판결; 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007다35152 판결

108) 이와 달리 동산양도담보권자가 물상대위권 행사로 양도담보 설정자의 화재보험금청구권에 대하여 압류 및 추심명령을 얻어 추심권을 행사하는 경우 제3채무자인 보험회사가 그 양도담보 설정 후 취득한 양도담보 설정자에 대한 별개의 채권을 가지고 상계로써 양도담보권자에게 대항할 수 없고, 이는 보험금청구권과 그 본질이 동일한 공제금청구권에 대하여 물상대위권을 행사하는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2014. 9. 25. 선고 2012다58609 판결).

본다.¹⁰⁹⁾

제3채무자의 집행채권자에 대한 반대채권으로 상계할 수 있는가에 대하여는, 부정설¹¹⁰⁾이 다수의 견해이지만, 추심명령 후에는 관계인의 이익균형을 위하여 허용하는 것이 타당하다는 설,¹¹¹⁾ 적어도 민사집행법 제232조 제1항 단서의 압류액 제한 허가가 있는 경우에는 다른 채권자의 권리를 침해할 우려가 없기 때문에 상계를 허용해도 좋다고 보는 설,¹¹²⁾ 달리 경합압류채권자나 배당요구채권자가 없는 때는 허용된다고 볼 것이라는 설¹¹³⁾ 등도 나타나고 있다.

임대차계약상의 차임채권에 관하여 압류 및 추심명령이 있더라도 임대차 종료 후 목적물의 반환시 그때까지 추심되지 않은 잔존 차임채권 상당액은 임대보증금에서 당연히 공제된다.¹¹⁴⁾

3) 한편, 집행채권의 부존재, 소멸, 귀속 등에 관한 사유는 집행채무자가 청구이의의 소 또는 집행문부여에 대한 이의의 소로서 주장하여야 하고 제3채무자가 그것을 주장하여 불복을 신청하거나 변제를 거부할 수 없다.¹¹⁵⁾

4) 다음으로, 집행채권자의 청구를 거부할 수 있는 절차상의 하자로는 강제집행의 정지 또는 취소사유의 존재, 압류명령 또는 추심명령의 무효[압류·추심명령의 중대한 형식적 하자 또는 송달 미료(未了)] 등이 있지만 압류명령, 추심명령 자체의 단순한 취소사유는 그 취소를 명하는 재판이 있을 때에 비로소 집행채권자의 청구를 거부할 수 있다.¹¹⁶⁾

그러나 제3채무자는 반드시 압류, 추심명령의 무효 여부를 조사하여 주장할 의무가 없기 때문에 무효의 사유가 있다고 하더라도 법원의 명령을 신뢰하고 지급한 경우에는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 집행채무자에 대한 관계에서도 유효할 수

109) 日最判 昭和 39(1964). 10. 27.(民集 18-8, 1801) 참조

110) 방순원(주35), 203.; 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 79.; 兼子—(주4), 209.; 菊井維大(주7), 183.; 中務(주16), 1185. 등

111) 松岡義正(주79), 1192.; 宮脇幸彦(주6), 150.(다만 宮脇은 반대채권의 취득시에 이미 압류가 행해졌거나 반대채권의 변제기가 피압류채권의 그것보다 늦을 때에는 상계가 허용되지 않는다고 보고 있다)

112) 조관형, “추심명령에 의한 추심에 관한 제문제”, 재판자료 제35집(1987), 520.

113) 東京地裁債權執行等手續研究會, 債權執行の諸問題, 判例タイムズ社, 15.

114) 대법원 2004. 12. 23. 선고 2004다56554 판결

115) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 79-80.; 兼子—(주4), 209.; 宮脇幸彦(주6), 150.; 三ヶ月章(주49), 392.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 359.; 日最判 昭和 45(1970). 6. 11.(民集 24-6, 509)

116) 兼子—(주4), 209.; 宮脇幸彦(주6), 151.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 359.

있다.¹¹⁷⁾

다. 압류가 경합하는 경우 등에 있어서 특칙

제3채무자는 금전채권에 관하여 배당요구서를 송달받은 때에 배당에 참가한 채권자의 청구가 있으면 압류된 부분에 해당하는 금액을 공탁하여야 하고(민집 제248조 제2항), 금전채권 중 압류되지 아니한 부분을 초과하여 거듭 압류명령 또는 가압류명령이 내려진 경우에 그 명령을 송달받은 때에는 압류 또는 가압류채권자의 청구가 있으면 그 채권의 전액에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다(민집 제248조 제3항).¹¹⁸⁾

이와 같이 민사집행법은 의무공탁의 범위를 명문으로 압류가 경합된 경우까지 확장함과 동시에, 또한 권리공탁의 요건을 완화하여 이를 위와 같이 채권자가 경합하는 경우에 한정하지 않고 압류채권자가 한 사람인 경우 또는 가압류가 집행된 경우에도 압류에 관련된 금전채권의 면책을 위하여 그 전액에 상당하는 금전을 공탁하는 것을 권리로서 인정하고 있다(민집 제248조 제1항, 제297조).

압류경합상태에 있는 피압류채권 중 일부에 관하여 일부 압류채권자가 추심명령에 기해 추심금 승소 확정판결을 받은 경우, 제3채무자가 위 확정판결에 기한 강제집행을 저지하기 위하여 집행공탁을 할 때 공탁하여야 할 금액은 채무 전액이라고 보아야 한다.¹¹⁹⁾

이러한 제3채무자의 공탁에 관하여는 제8장 집행공탁 제2절 이하에서 자세히 다시 보게 되므로 여기서는 더 나아가 살펴보지 아니한다.

라. 시효중단 등

채권자가 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 압류 또는 가압류하더라도 압류

117) 兼子一(주4), 209.; 宮脇幸彦(주6), 151.; 三ヶ月章(주49), 391-392.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 359.

118) 물론, 이와 같은 경우에 제3채무자는 의무로서가 아니라 민사집행법 제248조 제1항에 따라 권리로서 공탁을 할 수도 있다.

119) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2002다22700 판결【판결요지】구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제581조 제1항에 기한 제3채무자의 집행공탁은 피압류채권에 대한 압류경합을 요건으로 하는 것으로서, 이 경우 제3채무자가 위 법 규정에 따라 공탁하여야 할 금액은 채무 전액이라고 할 것이고, 이러한 법리는 압류경합상태에 있는 피압류채권 중 일부에 관하여 일부 압류채권자가 추심명령을 얻은 후 추심금청구소송을 제기하여 승소확정된 경우 제3채무자가 그 추심금청구 사건의 확정판결에 기한 강제집행을 저지하기 위하여 위 법 규정에 따라 집행공탁하는 경우에도 달리 볼 것이 아니다.

또는 가압류된 채무자의 제3채무자에 대한 채권에 대하여는 민법 제168조 제2호 소정의 소멸시효 중단사유에 준하는 확정적인 시효중단의 효력이 생기지는 않으나, 채권자가 확정판결에 기한 채권의 실현을 위하여 채무자의 제3채무자에 대한 채권에 관하여 압류 및 추심명령을 받아 그 결정이 제3채무자에게 송달이 되었다면 거기에 소멸시효 중단사유인 최고로서의 효력이 인정된다.¹²⁰⁾

V. 채권 추심 후의 절차

1. 추심의 효과

추심명령을 얻은 채권자가 일종의 추심기관으로서 제3채무자로부터 압류한 채권을 추심하고 이에 따라 제3채무자가 지급하면 그 범위 내에서 압류된 채권(피압류채권)은 소멸하며,¹²¹⁾ 이와 같이 제3채무자의 지급으로 인하여 피압류채권이 소멸한 이상 설령 다른 채권자가 그 변제 전에 동일한 피압류채권에 대하여 압류·가압류명령을 신청하고 나아가 압류·가압류명령을 얻었다고 하더라도 제3채무자가 추심권자에게 지급한 후에 그 압류·가압류명령이 제3채무자에게 송달된 경우에는 추심권자가 추심한 금원에 그 압류·가압류의 효력이 미친다고 볼 수 없다.¹²²⁾

따라서 제3채무자는 채무자에 대하여도 채권자에 대한 변제로서 대항할 수 있고, 이는 채권압류나 가압류가 정합된 경우에도 공탁청구가 없는 이상 마찬가지이다.

그러나 추심채권자의 집행채권 소멸 여부와 그 범위는 경우에 따라 다르다. 만

120) 대법원 2003. 5. 13. 선고 2003다16238 판결

121) 대법원 2005. 1. 13. 선고 2003다29937 판결【판결요지】[1] 추심명령을 얻어 채권을 추심하는 채권자는 집행법원의 수권에 따라 일종의 추심기관으로서 제3채무자로부터 추심을 하는 것이므로 제3채무자로서도 정당한 추심권자에게 지급하면 피압류채권은 소멸하는 것이다. [2] 채권압류명령은 그 명령이 제3채무자에게 송달됨으로써 효력이 생기는 것이므로 제3채무자의 지급으로 인하여 피압류채권이 소멸한 이상 설령 다른 채권자가 그 변제 전에 동일한 피압류채권에 대하여 채권압류명령을 신청하고 나아가 압류명령을 얻었다고 하더라도 제3채무자가 추심권자에게 지급한 후에 그 압류명령이 제3채무자에게 송달된 경우에는 추심권자가 추심한 금원에 그 압류의 효력이 미친다고 볼 수 없다.; 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008다59391 판결

122) 대법원 2005. 1. 13. 선고 2003다29937 판결; 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008다59391 판결; 대법원 2003. 10. 24. 선고 2003다37426 판결 참조(민법 제450조 제2항 소정의 지명채권양도의 제3자에 대한 대항요건은 양도된 채권이 존속하는 동안에 그 채권에 관하여 양수인의 지위와 양립할 수 없는 법률상의 지위를 취득한 제3자가 있는 경우에 적용되는 것이므로, 양도된 채권이 이미 변제 등으로 소멸한 경우에는 그 후에 그 채권에 관한 채권압류 및 추심명령이 송달되더라도 그 채권압류 및 추심명령은 존재하지 아니하는 채권에 대한 것으로서 무효이고, 위와 같은 대항요건의 문제는 발생될 여지가 없다고 판시)

일 다른 채권자와 경합이 없으면 추심에 의하여 집행채권이 소멸하게 되고, 이 경우 추심한 금액으로 집행채권의 변제에 충당하며 잔액이 있으면 채무자에게 반환하여야 한다. 반면 채권자가 집행법원에 추심신고를 할 때까지 다른 압류, 가압류 또는 배당 요구가 있는 경우에 배당을 받을 채권자의 공탁청구가 있는 때에는 제3채무자의 공탁(민집 제248조 제2항, 제3항) 또는 추심채권자의 공탁(민집 제236조 제2항)에 의하여 배당등 절차에 들어가게 되며(민집 제252조 제2호), 그 배당절차에서 실제로 배당 받은 금액의 범위 내에서만 집행채권이 소멸하게 되는 것이다.

2. 추심의 신고와 공탁

가. 추심채권자의 추심신고의무

1) 추심명령에 의한 채권의 추심은 집행채권자가 스스로 추심을 하기 때문에 집행법원으로서 추심이 제대로 되었는지 여부를 알 길이 없다.

따라서 추심명령에 의하여 제3채무자로부터 추심을 마친 때에는 추심한 채권액 등을 집행법원에 신고하도록 규정하였다(민집 제236조 제1항).^{123) 124)}

이 추심신고는 제3채무자가 임의로 변제한 경우이건 채권자가 추심소송 또는 강제집행 등 재판상의 권리를 행사하여 취득한 경우이건 이를 묻지 않는다.¹²⁵⁾ 또한 피압류채권의 일부만을 추심한 때에도 같으며, 계속적 수입채권이 압류된 경우에는 매 추심시마다 신고를 하여야 한다. 다만 일반 채권집행에 있어서 압류채권자가 민사집행법 제236조 제1항에 따라 집행법원에 대하여 하는 추심신고는 사건종료의 보고 성격을 가지는 것이지만, 계속적 급부의 압류사건에 있어서는 맨 마지막 1회분의 추심신고만이 일반의 경우와 같은 사건종료의 보고와 같은 성격을 가지고 그 때까지 행해진 중간의 다른 추심신고는 변제충당의 통지와 같은 성격을 가지고 있는 것이어서 양자의 성질이 약간 다르다고 볼 수 있다.

이러한 추심신고서가 제출될 때까지는 추심명령신청사건은 미제로 처리하여야 한다.

2) 추심신고가 있을 때까지 다른 채권자들의 배당요구가 없으면 추심채권자가 독점적 만족을 얻게 되고, 추심을 한 범위 내에서 집행권원의 집행력은 소멸하며 집행

123) 宮脇幸彦(주6), 148.

124) 별지서식 [4-7] 채권추심신고 참조(제4장 말미 수록)

125) 조관행(주112), 529.

절차가 종료하게 된다.¹²⁶⁾ ¹²⁷⁾

그러나 배당요구를 한 다른 채권자가 있는 때에는 배당절차가 종료한 때에 집행절차가 끝난다. 따라서 민사집행법 제247조의 배당요구는 이 신고가 있기까지 허용되며 그 후에는 할 수 없다. 만약 채권자가 추심을 하고서도 그 신고를 하지 않고 있으면 다른 채권자의 배당요구를 막을 길이 없다.¹²⁸⁾

제3채무자가 변제한 이상 목적채권은 소멸하므로 추심신고가 있기 전에도 다른 채권자의 압류는 허용되지 않는다.¹²⁹⁾ 다만 제3채무자의 변제 이후에 된 압류에 대하여 배당요구로서의 효력을 인정할 것인가에 대하여는 견해가 나뉘어지고 있으나, 판례¹³⁰⁾는 이에 대해 부정적으로 해석하고 있다(자세한 논의는 제6장 집행의 경합 제2절 V. 1. 다. 참조).

3) 채권자는 추심금에서 집행채권과 집행비용의 변제를 받고 나머지가 있으면 이를 채무자에게 반환한다.

다만 추심신고를 하지 아니한 때에는 채권자로서는 자기의 채권에 대한 변제에 충당할 수 없고,¹³¹⁾ 다른 채권자로부터의 배당요구가 허용되어 불이익을 받게 되나 추심신고를 강제하는 방법이 현행법상 없기 때문에 추심채권자의 추심신고가 드물어 그 미제사건의 처리가 문제로 되고 있다.¹³²⁾

126) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 90-91.;鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 392.

127) 대법원 2004. 12. 10. 선고 2004다54725 판결【판결요지】[1] 채권압류 및 추심명령을 받은 채권자가 제3채무자로부터 피압류채권을 추심한 다음 민사집행법 제236조 제1항에 따른 추심신고를 한 경우 그 때까지 다른 압류·가압류 또는 배당요구가 없으면 그 추심한 범위 내에서 피압류채권은 소멸하고, 집행법원은 추심금의 총당관계 등을 조사하여 집행채권 전액이 변제된 경우에는 집행력 있는 정보를 채무자에게 교부하며, 일부 변제가 된 경우에는 그 취지를 집행력 있는 정보 등에 적은 다음 채권자에게 돌려주는 등의 조치를 취함으로써 채권집행이 종료하게 된다. [2] 가압류가 본압류로 이행되어 강제집행이 이루어진 경우에는 가압류집행은 본집행에 포섭됨으로써 당초부터 본집행이 있었던 것과 같은 효력이 있게 되므로 본집행이 되어 있는 한 채무자는 가압류에 대한 이의신청이나 취소신청 또는 가압류집행 자체의 취소 등을 구할 실익이 없게 되고, 특히 강제집행조차 종료한 경우에는 그 강제집행의 근거가 된 가압류결정 자체의 취소나 가압류집행의 취소를 구할 이익은 더 이상 없다.

128) 日最判 昭和 38(1963). 6. 4.(民集 17-5, 660)

129) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 90-91.;宮脇幸彦(주6), 222.;鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 392.; 다만 兼子一(주4), 207.은 추심신고서가 제출될 때까지 다른 채권자가 압류할 수 있다고 하고,宮脇幸彦은 이중압류의 신청이 추심신고서의 제출 전에 있었다면 집행력 있는 정보에 의한 배당요구로 보아 구제할 것이라고 한다.

130) 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008다59391 판결

131) 兼子一(주4), 207.;日大判 明治 32(1899). 12. 6.(民錄 5-11, 22)

132) 추심채권자가 추심을 하고도 그 사유신고를 하지 않고 있는 경우 이를 형명죄로 의율할 수 있는지 여부에 관하여, 대법원 2003. 3. 28. 선고 2003도313 판결은 이를 긍정하는 취지이다.

4) 추심의 신고는 사건의 표시, 채권자, 채무자 및 제3채무자의 표시, 제3채무자로부터 지급받은 금액과 날짜를 기재한 서면을 제출하는 방식으로 한다(민집규 제162조 제1항). 사건의 표시란 당해 채권집행사건의 표시이며 법원명, 사건번호 및 사건명으로써 특정한다.

제3채무자가 복수(주채무자와 연대채무자)인 때에는 실제 추심에 응한 자만을 표시한다. 급료채권 등 계속적 채권을 추심한 때에는 어느 지급기(월)의 해당액인가도 특정하여야 할 것이다.

나. 추심채권자의 공탁의무

1) 채권자가 추심의 신고를 하기 전에 다른 압류, 가압류 또는 배당요구가 있을 때에는 채권자는 추심한 금액을 바로 공탁하고 그 사유를 신고하여야 한다(민집 제236조 제2항). 위 ‘다른 압류’에는 체납처분에 의한 압류도 포함된다.¹³³⁾

위 사유신고는 사건과 당사자의 표시, 제3채무자로부터 지급받은 금액과 날짜와 공탁사유 및 공탁한 금액을 적은 서면에 공탁서를 붙여서 하여야 한다(민집규 제162조 제2항).¹³⁴⁾

배당요구가 있으면 법원은 그 사실을 채권자에게 통지하여야 하는데(민집 제247조, 제219조), 이는 채권자에게 채권자의 경합이 있음을 알려주는 역할도 하는 것이다.

또 추심신고가 있는 경우에 그 전에 채권자가 경합되어 공탁하여야 하는 경우이면 집행법원은 적당한 방법으로 그 사실을 추심채권자에게 알려 주어 공탁 및 사유신고를 하도록 함이 상당하다.

2) 압류 등의 경합이 있음에도 불구하고 추심을 완료한 채권자가 공탁의무를 이행하지 않을 경우에 다른 경합채권자는 추심채권자를 상대로 추심한 금원을 법원에 공탁하고, 그 사유를 신고할 것을 구하는 소를 제기할 수 있다.

이를 인용하는 때의 주문의 방식 등에 관하여는 견해가 나뉘고 있는데, 그 중 제1설은 이때 주문방식은 「피고는 원고에게 ○○지방법원 20 타채○○○ 채권압류 및 추심명령에 따른 추심금 ○○○원을 공탁의 방법으로 지급하고, 그 사유를 신고하라.」는 형식으로 함이 상당하고, 이 공탁판결에 기초하여 강제집행을 한 후 집행기관으로부터 배당등을 받아 그것을 공탁하여야 한다는 견해이고, 제2설은 이 경우 주문

133) 대법원 2015. 8. 27. 선고 2013다203833 판결

134) 별지서식 [4-9] 채권추심사유신고서 참조(제4장 말미 수록)

방식은 「피고는 ○○지방법원 20 타채○○○ 채권압류 및 추심명령에 따른 추심금 ○○○원을 위 법원에 공탁하고 그 사유를 신고하라.」는 형식이 되어야 하고, 이는 간접강제(민집 제261조)의 방법으로 집행해야 한다는 견해이다. 생각건대 이 경우 공탁청구의 소는 다른 모든 채권자들을 위한 대표소송의 성격을 가지고 있고, 배당재단의 형성에 그 주된 목적이 있으므로 제2설에 따른 주문 및 집행방식이 더 바람직하다고 보이지만 그 집행이 용이하지 않는 면이 있다. 이에 관하여 실무는 대체로 제1설에 따르고 있어 보인다.¹³⁵⁾

3) 추심채권자는 피압류채권의 행사에 제약을 받게 되는 채무자를 위하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 채권을 행사하고, 나아가 압류가 경합된 상태에서 제3채무자로부터 추심금을 지급받으면 지체 없이 공탁 및 사유신고를 함으로써 압류 또는 배당에 참가한 모든 채권자들이 배당절차에 의한 채권의 만족을 얻도록 하여야 할 의무를 부담한다(민집 제236조 제2항). 이는 제3채무자가 추심명령에 기한 추심에 임의로 응하지 아니하여 추심채권자가 제3채무자를 상대로 추심의 소를 제기한 후 얻어낸 집행권원에 기하여 제3채무자의 재산에 대하여 강제집행을 한 결과 취득한 추심금의 경우에도 마찬가지이다.¹³⁶⁾ 추심채권자의 이와 같은 의무는 민사집행법 제236조 제2항이 채권을 추심한 추심채권자가 그 사유를 법원에 신고하기 전에 다른 압류·가압류 또는 배당요구가 있었을 때에는 추심한 금액을 ‘바로’ 공탁하고 그 사유를 신고하여야 한다고 규정하고 있는 점에 비추어 당연하다고 할 것이다. 따라서 만일 추심채권자가 추심을 마쳤음에도 지체 없이 공탁 및 사유신고를 하지 아니한 경우에는 그로 인한 손해배상으로서, 제3채무자로부터 추심금을 지급받은 후 공탁 및 사유신고에 필요한 상당한 기간을 경과한 때부터 실제 추심금을 공탁할 때까지의 기간 동안 금전

135) 법원행정처, 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 380.

136) 대법원 2007. 11. 15. 선고 2007다62963 판결【판결요지】추심명령을 얻은 추심채권자는 집행법원의 수권에 기하여 일종의 추심기관으로서 채무자를 대신하여 추심의 목적에 맞도록 채권을 행사하여야 하고, 특히 압류 등의 경합이 있는 경우에는 압류 또는 배당에 참가한 모든 채권자를 위하여 제3채무자로부터 채권을 추심하여야 하므로, 추심채권자는 피압류채권의 행사에 제약을 받게 되는 채무자를 위하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 채권을 행사하고, 나아가 제3채무자로부터 추심금을 지급받으면 지체없이 공탁 및 사유신고를 함으로써 압류 또는 배당에 참가한 모든 채권자들이 배당절차에 의한 채권의 만족을 얻도록 하여야 할 의무를 부담한다. 이러한 법리는 제3채무자가 추심명령에 기한 추심에 임의로 응하지 아니하여 추심채권자가 제3채무자를 상대로 추심의 소를 제기한 후 얻어낸 집행권원에 기하여 제3채무자의 재산에 대하여 강제집행을 한 결과 취득한 추심금의 경우에도 마찬가지이다. 따라서 압류가 경합된 상태에서 발령된 압류 및 추심명령의 추심채권자가 제3채무자의 금전채권에 대하여 다시 압류 및 추심명령을 받아 추심금을 지급받은 경우에는 지체 없이 압류가 경합된 상태에서의 압류 및 추심명령의 발령법원에 추심금을 공탁하고 그 사유를 신고하여야 한다.

채무의 이행을 지체한 경우에 관한 법정지연손해금 상당의 금원도 공탁하여야 할 의무가 있다.¹³⁷⁾

4) 현행법상 채납처분절차와 민사집행절차는 별개의 절차이고 두 절차 상호 간의 관계를 조정하는 법률의 규정이 없으므로, 한쪽의 절차가 다른 쪽의 절차에 간섭할 수 없는 반면, 쌍방 절차에서 각 채권자는 서로 다른 절차에 정한 방법으로 다른 절차에 참여하게 된다.

따라서 채납처분에 따라 압류된 채권에 대하여도 민사집행법에 따라 압류 및 추심명령을 할 수 있고, 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자는 제3채무자를 상대로 추심의 소를 제기할 수 있다. 제3채무자는 압류 및 추심명령에 선행하는 채납처분에 의한 압류가 있어 서로 경합된다는 사정만을 내세워 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자의 추심청구를 거절할 수 없고, 또한 민사집행절차에 따른 압류가 근로기준법에 따라 우선변제권을 가지는 임금 등 채권에 기한 것이라는 등의 사정을 내세워 채납처분에 의한 압류채권자의 추심청구를 거절할 수도 없다.

이 경우 제3채무자는 채납처분에 따른 압류채권자와 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자 중 어느 한쪽의 청구에 응하여 그에게 채무를 변제하고 변제 부분에 대한 채무의 소멸을 주장할 수 있으며, 또한 민사집행법 제248조 제1항에 따른 집행공탁을 하여 면책될 수도 있다. 그리고 채납처분에 의한 압류채권자가 제3채무자에게서 압류채권을 추심하면 국제징수법에 따른 배분절차를 진행하는 것과 마찬가지로, 민사집행절차에서 압류 및 추심명령을 받은 채권자가 제3채무자에게서 압류채권을 추심한 경우에는 민사집행법 제236조 제2항에 따라 추심한 금액을 바로 공탁

137) 대법원 2005. 7. 28. 선고 2004다8753 판결【판결요지】[1] 추심명령을 얻은 추심채권자는 집행법원의 수권에 기하여 일종의 추심기관으로서 채무자를 대신하여 추심의 목적에 맞도록 채권을 행사하여야 하고, 특히 압류 등의 경합이 있는 경우에는 압류 또는 배당에 참가한 모든 채권자를 위하여 제3채무자로부터 채권을 추심하여야 한다. [2] 추심채권자는 피압류채권의 행사에 제약을 받게 되는 채무자를 위하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 채권을 행사하고, 나아가 제3채무자로부터 추심금을 지급받으면 지체 없이 공탁 및 사유신고를 함으로써 압류 또는 배당에 참가한 모든 채권자들이 배당절차에 의한 채권의 만족을 얻도록 하여야 할 의무를 부담한다 할 것인바, 이는 구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제569조 제2항이 채권을 추심한 추심채권자가 그 사유를 법원에 신고하기 전에 다른 압류, 가압류 또는 배당요구가 있는 때에는 추심한 금액을 '지체 없이' 공탁하고 그 사유를 신고하여야 한다고 규정하고 있는 점에 비추어 당연하다고 할 것이므로 만일 추심채권자가 추심을 마쳤음에도 지체 없이 공탁 및 사유신고를 하지 아니한 경우에는 그로 인한 손해배상으로서, 제3채무자로부터 추심금을 지급 받은 후 공탁 및 사유신고에 필요한 상당한 기간을 경과한 때부터 실제 추심금을 공탁할 때까지의 기간 동안 금전채무의 이행을 지체한 경우에 관한 법정지연손해금 상당의 금원도 공탁하여야 할 의무가 있다.

하고 사유를 신고하여야 한다.¹³⁸⁾

다. 배당등의 절차

추심의 신고가 있는 때에는 집행법원은 추심금의 충당관계를 조사하여 보고 민사집행법 제159조 제2항, 제3항에 준하여 집행채권 전액이 변제된 경우에는 집행력 있는 정본을 채무자에게 교부하고, 일부 변제가 된 경우에는 그 취지를 집행력 있는 정본 등에 적은 다음 채권자에게 돌려주는 등의 조치를 취해야 한다.

그리고 추심한 금액 가운데 변제되고 남은 나머지가 있으면 집행채권자로 하여금 채무자에게 반환하도록 지시하여야 한다. 채권자가 그 반환지시에 따르지 않을 때에는 채무자는 잉여금의 반환을 구하는 부당이득반환청구의 소를 제기할 수 있다.

제3채무자가 공탁하거나 추심채권자가 공탁을 한 때에는 집행법원은 배당등 절차를 개시하여야 한다(민집 제252조 제2호).

저당권부채권의 압류를 등기기록에 기입한 후 압류채권의 추심을 완료하여 추심 신고서가 제출된 경우 채권자의 신청에 의하여 압류기입등기의 말소등기를 촉탁하게 되면 좋으나, 사실상 이를 기대할 수 없으므로 법원사무관등은 이를 직권으로 촉탁함이 상당하다.¹³⁹⁾

VI. 추심명령의 취하, 취소 및 집행정지

1. 추심명령의 취하

가. 채권자는 추심명령이 발부된 후에도 자유로이 추심명령의 신청을 취하할 수 있다.¹⁴⁰⁾

이때 채무자에게는 민사집행규칙 제16조에 의하여 취하의 사실을 통지하여야 하나, 추심명령을 송달받은 제3채무자도 채무자에 대한 지급이 금지되므로 신청의 취하에 의하여 지급금지의 구속이 해소되었음을 알려주는 것이 상당하다고 보아 민사집행규칙 제160조 제2항은 제3채무자에게도 위와 같은 취하의 통지를 하도록 규정하고 있다.

138) 대법원 2015. 7. 9. 선고 2013다60982 판결

139) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 92.; 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 380.

140) 별지서식 [4-13] 추심명령신청취하서 참조(제4장 말미 수록)

나. 채권자는 현금화절차가 끝나기 전까지 압류명령의 신청을 취할 수 있고, 이 경우 채권자의 추심권도 당연히 소멸하게 되며, 추심금청구소송을 제기하여 확정 판결을 받은 경우라도 그 집행에 의한 변제를 받기 전에 압류명령의 신청을 취하여 추심권이 소멸하면 추심권능과 소송수행권이 모두 채무자에게 복귀한다.¹⁴¹⁾ 이는 채권자가 압류명령은 그대로 둔 채 추심명령만을 취한 경우도 동일하다.

또한 국가가 국세징수법에 의한 체납처분으로 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 압류하였다가 압류를 해제한 경우에도 마찬가지이다.¹⁴²⁾

2. 추심명령의 취소

추심명령 발령 후 추심의 신고서가 제출되기까지 채무자가 민사집행법 제49조 제1호, 제3호, 제5호, 제6호 등의 서류를 제출한 때에는 집행법원은 기존의 압류 및 추심명령을 취소하여 그 효력을 상실시킨다.

이 취소결정은 당사자인 채권자와 채무자에게 고지될 것이지만 추심명령의 취하와 같은 취지로 제3채무자에게도 그 결정이 있었다는 사실을 송달하여야 한다(민집규 제160조 제2항).

3. 집행정지

추심명령이 있는 후 민사집행법 제49조 제2호, 제4호의 서류가 제출된 경우 집행법원은 어떻게 할 것인가.

일반적으로 채권집행절차에서 집행정지서면이 제출되면 집행법원이 그 이후의 절차를 행하지 아니함으로써 사실상 집행절차가 정지되는 것이 원칙이나, 추심명령이 있는 후에는 이와 같은 소극적 조치만으로는 정지의 목적을 달할 수 없는 위험이 있기 때문에 종래에 집행법원이 피압류채권의 추심을 금지하는(추심권의 일시정지) 뜻의 재판을 하여야 한다는 견해¹⁴³⁾가 있기도 하였으나, 구 민사소송규칙 제128조 제1항은 위와 같은 번거로움을 피하기 위해 결정의 고지방식을 취하지 아니하고, 단지 채권자에게는 추심금지의 취지를, 제3채무자에게는 채권자에 대한 변제금지의 취지를 각 통지하도록 규정하였으며, 현행 민사집행규칙 제161조 제1항 역시 같은 취지로 규정하고 있다.

141) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2009다48879 판결

142) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2009다48879 판결

143) 兼子—(주)4, 131.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 360.

그리하여, 법원사무관등은 이 경우 채권자 및 제3채무자에 대하여 그 서류가 제출되었다는 사실과 서류의 요지 및 위 서류의 제출에 따른 집행정지의 효력이 상실되기 전에는 압류채권자는 채권의 추심을 하여서는 아니되고 제3채무자는 채권의 지급을 하여서는 아니된다는 취지를 통지하여야 한다[민집규 제161조 제1항, 통지서의 양식은 [4-9] 집행정지 통지서 참조(제4장 말미 수록)].

위 추심금지의 효력발생시기에 대하여는 채권자 또는 제3채무자 중에서 먼저 통지를 받은 때, 채권자와 제3채무자 모두에게 송달된 때라는 견해가 있을 수 있으나 추심명령과 같이 제3채무자에게 통지된 때라고 봄이 타당할 것이다.¹⁴⁴⁾ 이에 의하여 제3채무자는 채권자에게도 채무자에게도 이행을 할 수 없는 상태가 된다.¹⁴⁵⁾

제3채무자로부터 추심을 하였으나 아직 추심신고를 하기 전에도 집행정지의 효과는 생길 수 있으나 제3채무자의 변제는 유효한 것으로 취급될 것이다. 이때 채무자는 채권자에 대하여 추심금의 공탁 또는 집행법원에의 제출을 구할 수 있을 것이다.¹⁴⁶⁾

144) 조관행(주112), 533.

145) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 360.

146) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 360.

제3절 추심소송

I. 개요

압류채권자는 추심명령을 얻은 후 제3채무자가 추심절차에 대하여 의무를 이행하지 아니하는 때에는 소로써 그 이행을 청구할 수 있는데(민집 제238조, 제249조 제1항), 이와 같이 채권자가 추심명령에 의한 채무를 이행시키기 위하여 제3채무자를 피고로 하여 제기하는 소송을 추심소송이라고 한다.

압류채권자는 추심명령을 얻어 추심권을 갖게 되면 제3채무자에 대하여 피압류채권의 지급을 구할 수 있지만, 제3채무자가 그 지급을 거절하고 또 공탁(민집 제248조 제1항 참조)도 하지 않는 때에는 피압류채권의 추심을 위하여 추심소송을 제기할 수 있도록 한 것이다.

추심의 소에 관하여는 민사집행법 제249조 제1항 외에 제238조의 규정이 있어 양자의 관계가 문제되는데, 위 제238조가 추심의 소에 관한 일반규정이고 위 제249조 제1항은 채권자가 경합한 경우의 추심소송에 관한 특칙이라고 보는 것이 일반적 견해이다. 즉 위 제249조 제1항의 「제3채무자가 추심절차에 대하여 의무를 이행하지 아니한 때」라고 하는 것은 제3채무자가 민사집행법 제248조 제2항, 제3항에 따라 채무액의 공탁의무를 이행하지 아니할 때 그 이행을 구하는 청구에 한하는 것이라고 할 수 있다.¹⁴⁷⁾ 제3채무자가 채무액 공탁의무를 이행하지 아니할 때 위 제249조 제1항의 규정에 의하여 그 이행을 구하는 소는 추심명령을 받은 압류채권자가 제기할 것이며, 추심채권자가 아니면 소제기의 원고적격이 없다.¹⁴⁸⁾

이 추심을 위한 재판절차는 피압류채권의 이행을 구하는 소송에 한하는 것이 아니라 지급명령이나 조정을 신청하는 것 등을 포함한다. 또한 채무액의 공탁을 청구하는 소송과 그 채권의 확인소송도 포함하며, 민사집행법 제249조의 소송참가도 추심소송에 준하여 파악할 수 있다. 나아가 민사집행법 제238조는 추심명령에 기한 것 외에 전부명령에 기하여 피전부채권의 이행을 구하는 소의 경우도 포함한다고 해석하여야 할 것이다.¹⁴⁹⁾

147) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 128.; 조관행(주112), 512.; 兼子—(주4), 217.

148) 대법원 1979. 7. 24. 선고 79다1023 판결 [판결요지]민사소송법 제581조 에 의하면 배당참가채권자는 제3채무자에 대하여 채무액이 공탁을 청구할 권리가 있으나 추심명령을 받은 압류채권자에 한하여 위 공탁 청구의 소를 제기할 수 있고 추심명령을 받지 아니한 압류채권자는 위 소를 제기할 원고 적격이 없다.

149) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 128.

II. 추심소송의 성질

추심소송의 성질에 관하여는 추심소송판결의 효력이 채무자에게 미친다고 볼 것인가와 관련되어, 다음과 같은 견해의 대립이 있다.

1. 법정소송담당설

가. 이는 추심소송을 채권자대위소송과 동일하게 제3자인 압류채권자가 타인인 집행채무자의 권리를 행사하는 것으로 보는 설로서, 민사소송법 제218조 제3항¹⁵⁰⁾의 존재를 강조하는 견해이다. 일본과 우리나라의 통설이다.¹⁵¹⁾

나. 이 견해 하에서는 아래의 문제들에 대하여 다음과 같은 결론에 이르게 된다.

1) 채무자가 제기하는 소송에의 영향

채무자가 제기하는 소송은 추심소송의 제기 전후를 불문하고 추심소송의 대상으로 되어 있는 채권의 범위 내에서는 중복소송의 제기로 되고, 따라서 추심소송 제기 후에 채무자가 제기하는 소는 중복제소에 해당하는 것으로 되어 각하를 면하지 못하게 된다.

또한 이미 압류채권자에 의한 추심소송이 계속된 후 다른 압류채권자가 추심소송을 제기하는 것은 압류가 경합하는 경우 민사소송법 제83조의 공동소송참가의 방법에 의하지 않으면 그 소는 부적법한 것으로 될 것이다.

이 견해하에서도 압류가 피압류채권의 일부만 압류한 것인 경우는 그 압류를 하고 있는 범위 내에서 채무자에게 기판력이 미치는 것으로 될 것이므로 중복소송의 문제도 그 범위를 초과하는 압류가 있어 압류의 효력이 피압류채권 전부에 미치게 될 경우에 한정될 것이다.

150) 제218조 [기판력의 주관적 범위]

- ① 확정판결은 당사자, 변론을 종결한 뒤의 승계인(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결을 선고한 뒤의 승계인) 또는 그를 위하여 청구의 목적물을 소지한 사람에 대하여 효력이 미친다.
- ② 제1항의 경우에 당사자가 변론을 종결할 때(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결을 선고할 때)까지 승계사실을 진술하지 아니한 때에는 변론을 종결한 뒤(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결을 선고한 뒤)에 승계한 것으로 추정한다.
- ③ 다른 사람을 위하여 원고나 피고가 된 사람에 대한 확정판결은 그 다른 사람에 대하여도 효력이 미친다.
- ④ 가집행의 선고에는 제1항 내지 제3항의 규정을 준용한다

151) 이영섭(주29), 173.; 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 131.; 兼子—(주4), 208.; 宮脇幸彦(주6), 147, 252. 이하; 菊井維大(주7), 676.; 新堂幸司, 民事訴訟法, 弘文堂(平成2), 193.; 日大判 昭和 15(1940). 3. 15.(民集 19, 586) 등

2) 추심소송의 채무자에의 영향

이 견해는 추심소송의 기판력이 그 소송의 인용, 기각을 불문하고 채무자에게 미친다고 보고 있다. 그리고 압류채권자가 승소한 후 압류명령의 신청을 취하한 때에는 그 판결에 대하여 채무자가 승계집행문의 부여를 받아 강제집행을 하는 것이 인정된다. 또한 채무자에 대한 다른 채권자도 채권압류명령 및 추심명령을 얻은 후 그 판결의 효력을 이용하여 강제집행을 하는 것이 가능하다.

3) 추심소송의 중단

추심소송 제기 후 판결확정에 이를 때까지 압류명령의 신청을 취하하거나 그 압류명령이 취소된 경우에는 민사소송법 제237조의 규정에 의해 소송절차를 중단하고 채무자가 그 소송을 수제하게 된다.

4) 다른 압류채권자의 추심소송에의 참가방식

이 견해 하에서는 다른 압류채권자가 추심소송에 참가하기 위해서는 공동소송참가(민소 제83조)의 방식에 의해야 한다. 별개의 추심소송의 제기는 중복제소에 해당 하는 것으로서 각하된다.¹⁵²⁾

다. 이 견해의 문제점

이 견해에 대한 비판은 다음과 같은 점에서 제기되고 있다. 즉 첫째로, 추심소송도 제3자 소송담당의 일례이기는 하지만 제3자 소송담당의 다른 경우, 예컨대 파산관재인이 파산자의 권리를 재판상 행사하는 경우나 직무상 당사자인 검사의 경우에 있어서는 정도의 차이는 있으나 담당자는 「피담보자를 위하여」 소송을 수행하는 면이 존재하는데 비하여, 추심소송에 있어서 채권자는 「채무자를 위하여」 소송을 수행하는 면이 조금도 없고 오로지 「자기의 이익을 위하여」 본래의 채권자를 밀어내고 그 권리를 그 의사에 반하여 행사하고 그 결과를 자기의 채권의 변제에 충당하기 위하여 소송을 수행하기 때문에 다른 면이 있는 점, 둘째로, 모법인 독일법은 집행채무자에 대한 소송고지를 집행채권자의 의무로 하고 있지만(일본의 경우 구 민사소송법에 있었던 고지의무에 관한 규정을 현행 민사집행법에서 삭제하였다), 집행채권자가 받은 판결의 효력은 일체 채무자에게 미치지 않는다는 것이 판례 및 다수설이라는 점, 셋째로, 패소판결의 효력도 집행채무자에게 미친다고 한다면 채무자로서는 자기가 관여하지 아니한 소송에서 제3자의 졸렬한 소송수행에 의해 자기의 권리가 상실되는 것을 감수해야 하는 등 매우 가혹한 결과를 초래하게 되는 점 등이 그것이다.¹⁵³⁾

152) 浦野雄幸, 條解民事執行法(1985), 681.

153) 三ヶ月章, 注解民事執行法(4), 590-592. 그 외에 일본 민사집행법이 구 민소법에 있었던 채무

2. 고유적격설

가. 이 견해는 압류채권자에게 추심권이 생기면 그에게 고유한 실체법상의 권리가 발생하고 그에 따라 압류채권자는 그 자신의 권리를 행사하는 것이라고 보는 입장이다 (즉 추심소송의 소송물은 추심권에 의해 급부를 구하는 권리라고 본다).¹⁵⁴⁾ 이 설은 채무자가 추심소송에 참가하지 않은 점, 압류채권자와 채무자와의 사이에 대립의 경우가 있는 점 등을 근거로 추심소송의 기판력은 채무자에게 미치지 않는다고 보고 있다.

이 설은 추심소송에 있어서 원고(압류채권자)가 처분권을 가지는 대상인 권리는 피압류채권 그 자체가 아니라 원고에게 속하는 추심권이고, 그 권리는 단순히 절차적으로 존재하는 것이 아니라 실체적으로, 즉 그 자체가 처분권의 대상이 되는 것으로서 존재하는 것이라고 말할 수 있으며, 또 원고가 소송에 의해 확정할 것을 구하고 있는 것은 피압류채권이 아니라 추심권에 의해서 어떠한 급부를 얻을 수 있는 권리가 있는가라는 점에 있다고 보고 있다.

나. 법정소송담당설과 비교하여 이 견해가 가지는 특징을 보면 다음과 같다.

1) 채무자가 제기하는 소의 영향

이 견해하에서 채무자는 추심소송이 계속되어 있는가 아닌가에 불구하고 제3채무자에 대하여 급부소송을 제기하는데 지장이 없다(채무자가 제기한 소송에 관하여도 인용판결이 가능하고, 다만 압류가 계속되어 있는 한 집행할 수 없을 뿐이다).

따라서 제3채무자로서는 추심소송이 계속된 경우에도 채무자에 대하여 기판력이 미치지 않기 때문에 피압류채권의 존재를 다투는 경우에는 채무자에 대하여 별개로 채무부존재확인소송을 제기할 필요가 있다. 그 밖의 채권자로부터 별도의 추심소송이 제기되는 것을 회피하기 위해서도 기본적으로는 위의 방법과 동일하다. 다만 다른 압류채권자가 있는 경우 중 일정한 경우에 민사집행법 제249조 제3항의 규정에 의해 기판력을 확장할 수 있는 절차가 인정되어 있다.

2) 추심소송의 채무자에의 영향

압류채권자가 추심소송에서 승소해도 그 판결의 효력을 채무자 또는 참가명령을 받고 있지 않은 그 밖의 다른 채권자가 이용할 수 없다.¹⁵⁵⁾ 따라서 승계집행문을 받

자에 소송고지의무 규정을 없앤 것은 법정소송담당설이 아닌 절충설에 의해서만 설명이 가능하다는 취지로 주장하고 있다.

154) 田中康久, 新民事執行法の解説(増補改訂版, 1980), 336.; 中野貞一郎, 民事執行法(第二版, 1991), 547.; 林屋禮二 編, 民事執行法(1991), 222.

아 집행하는 것이 가능하지 않다. 이 견해하에서 추심소송의 승소판결이 채무자에게 영향을 미치지 않는 것은 당연하다.

3) 추심소송의 다른 압류채권자에의 영향

이미 압류채권자에 의한 추심소송의 제기 후 다른 압류채권자가 추심소송을 제기하는 것도 허용된다. 양자가 중복제소의 관계에 있다고 보지 않기 때문에 공동소송 참가의 방식에 의하지 않더라도 각하되지 않는다. 다만 민사집행법 제249조 제3항의 규정에 의한 공동소송인으로서의 참가명령을 받은 후에는 공동소송참가의 방식에 의해야 하기 때문에 그 경우 별소의 제기는 부적법한 것으로서 각하된다.¹⁵⁵⁾

4) 소송중단의 문제

이 견해하에서는 추심소송이 취하된 경우 또는 압류명령의 신청이 취하된 경우, 압류명령이 취소된 경우 등 어느 경우라도 소송중단의 효과는 발생하지 않고 그 취하 등에 의해 당해 추심소송은 종료하게 되며, 취하·취소의 경우에는 청구를 기각하게 된다.¹⁵⁷⁾

5) 다른 압류채권자의 추심소송에의 참가방식

다른 압류채권자가 별개의 추심소송을 제기할 수 있는가 어떤가에 관하여, 이 견해하에서는 소극설과 적극설로 나뉘어지고 있다.

다. 이 견해의 문제점

이 견해하에서는 제3채무자가 추심소송에서 승소해도 채무자나 다른 압류채권자로부터 피압류채권에 대하여 다시 소가 제기되는 것을 피할 수 없게 되고, 그 결과 제3채무자에게 이중의 절차를 강요하게 되는 단점이 있다. 제3채무자가 그와 같은 결과를 회피하기 위해서는 다른 압류채권자에 대한 추심소송에서 민사집행법 제249조 제3항의 참가명령을 얻든가 또는 채무자에 대하여 채무부존재확인¹⁵⁶⁾의 소를 제기하든가 하여야 한다.

3. 절충설

이 견해는 추심소송의 기판력이 채무자에게 미치는지 여부에 관하여 앞서 본 법

155) 다만 이 견해하에서도 추심소송의 경우 채무자 또는 다른 채권자가 그 추심 소송의 승소판결을 이용할 수 있다고 해석하는 견해가 없는 것은 아니다.

156) 이와 같이 기판력이 채무자에게 미치는 것을 부정하는 견해하에서도 참가명령을 받지 않아도 다른 채권자는 별소를 제기할 수 없고 공동소송참가방식에 의해야 한다는 견해도 있기는 하다.

157) 단, 이 견해하에서도 추심권이 소멸한 경우 소를 각하해야 한다는 견해도 있기는 하다.

정소송담당설과 고유적격설의 절충적 입장을 취하는 견해로서, 추심소송의 기판력은 승소의 경우에 한하여 채무자에게 미친다고 보고 있다.^{158) 159)}

여기에는 추심소송의 효력이 채무자에게 미치는 것을 전제로 하면서 추심소송의 승소의 경우와 구분하여 패소의 경우에는 기판력이 채무자에게 미치지 않는다는 견해¹⁶⁰⁾와 추심소송의 효력이 채무자에게 미치지 않는 것을 전제로 하면서 승소의 경우에는 채무자에게 기판력이 미치는 것을 긍정하는 견해¹⁶¹⁾도 존재한다.

이 견해는 앞서 본 법정소송담당설과 고유적격설의 결점을 보완하면서 결과적으로 타당한 결론을 도출시키고자 하는 것이지만, 채무자가 제기하는 소송과의 관계를 어떻게 처리할 것인가 또는 압류채권자의 압류명령이 취소된 경우에 소송중단의 효과가 발생하는가 어떤가에 대하여 통일적인 명확한 설명이 가능하지 않다. 또한 추심소송의 판결이 일부인용, 일부청구기각의 경우에는 어떻게 해석해야 하는가에 대하여도 명확한 기준을 잡지 못하고 있다.

4. 소결론

위와 같이 추심소송의 성질에 관하여 여러 견해가 나타나고 있으나, 그것은 주로 그 논점의 핵심이 추심소송의 기판력이 채무자에게도 미치는지 여부에 관하여 어떻게 볼 것인가에 맞추어져 있다.

위 학설들 중 고유적격설과 절충설 등이 주장하는 논거도 상당히 경청할 만한

158) 三ヶ月章, “わが國の代位訴訟, 取立訴訟の特異性とその判決の效力の主觀的範圍”, 民事研究 6卷, 1.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 407-408.; 齋藤秀夫, 注解民事訴訟法(3), 第一法規, 374.

159) 이 설의 주장자 중 대표자적인 三ヶ月章은 그 논거로서, 첫째, 추심소송도 제3자소송담당의 일례이기는 하지만 제3자소송담당의 다른 경우 예컨대 파산관재인이 파산자의 권리를 재판상 행사하는 경우나 직무상 당사자인 검사의 경우에 있어서는 정도의 차이는 있으나 담당자는 「피담보자를 위하여」소송을 수행하는 면이 존재하는데 비하여 추심소송에 있어서 채권자는 「채무자를 위하여」소송을 수행하는 면이 조금도 없고 오로지 「자기의 이익을 위하여」본래의 채권자를 밀어내고 그 권리를 그 의사에 반하여 행사하고 그 결과를 자기의 채권의 변제에 충당하기 위하여 소송을 수행하기 때문인 점, 둘째, 모법인 독일법은 일본의 구민사소송법과 같이 집행채무자에 대한 소송고지를 집행채권자의 의무로 하고 있지만 집행채권자가 받은 판결의 효력은 일체 채무자에게 미치지 않는다는 것이 判例 및 압도적 多數說이라는 점, 세째, 패소판결의 효력도 집행채무자에게 미친다고 한다면 채무자로서는 자기가 관여하지 아니한 소송에서 제3자의 졸렬한 소송수행에 의해 자기의 권리가 상실되는 것을 감수해야 하는 집행채무자에게는 매우 가혹한 결과를 초래하게 되는 점 등을 들고 있다.

160) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(4), 590.; 岩野徹 外 編, 注解強制執行法(2), 第一法規出版株式會社(1974), 408.

161) 福永, “當事者適格理論の再構成”, 山木戸還曆(上), 68.

것이기는 하나, ① 추심소송의 경우에는 채무자에 대한 소송고지가 채권자의 의무로 되어 있어(민집 제238조) 채무자가 모르는 사이에 추심소송이 진행되는 예가 실제로 드물 것이기 때문에 채무자로서는 추심소송에 보조참가하여 자기의 권리를 주장할 기회가 어느 정도 보장되어 있는 점, ② 제3채무자로 하여금 동일채권에 대하여 여러 번 응소할 것을 강요하는 것은 바람직하지 않은 점, ③ 또한 독일의 경우 집행채무자에 대한 소송고지를 집행채권자의 의무로 하고 있음에도 불구하고 판례 및 압도적 다수설이 추심소송에 있어서 집행채권자가 받은 판결의 효력이 일체 채무자에게 미치지 않는다고 해석하고 있어 보이지만, 이는 우리 민사소송법 제218조 제3항¹⁶²⁾과 같은 규정이 없기 때문이라고 생각되며 따라서 반드시 이와 같은 독일의 판례 및 학설이 우리에게도 타당한 것이라고 할 수는 없는 점, ④ 그리고 추심소송과 그 구조가 유사한 채권자대위소송에 대하여 우리 판례¹⁶³⁾가 “어떠한 사유로 인하였건 적어도 채권자대위권에 의한 소송이 제기된 사실을 채무자가 알았을 경우에는 그 판결의 효력이 채무자에게 미친다”라고 보고 있는 점 등 여러 가지 사정을 감안하여 보면, 통설과 같이 추심소송의 판결의 효력이 채무자에게 미친다고 봄이 적절하다고 생각된다.¹⁶⁴⁾

따라서 여기서는 위 법정소송담당설의 입장에서 설명을 하되, 다만 필요한 한도에서 다른 견해들의 입장, 차이점 등도 함께 언급하여 가기로 한다.

Ⅲ. 추심소송의 관할

추심소송은 채무자의 제3채무자에 대한 채권의 추심을 목적으로 하는 것이므로 원칙적인 관할법원은 피고인 제3채무자의 보통재판적 소재지 또는 의무이행지를 관할하는 법원이다(민집 제238조).

압류채권자가 추심권을 취득해도 그 추심권에는 제3채무자에게 새로운 부담을 과하는 내용의 권리는 포함되어 있지 않아서 추심권에 의하여 급부를 구하는 권리의 의무이행지도 피압류채권의 의무이행지에 의해 결정되는 것이라고 해석해야 하기 때문에 이와 같이 정하고 있다.

피압류채권이 지참채무인 때는 그 의무이행지가 집행채무자의 주소지이고 압류

162) 민사소송법 제218조 제3항 : 다른 사람을 위하여 원고나 피고가 된 사람에 대한 확정판결은 그 다른 사람에 대하여도 효력이 미친다.

163) 위 대법원 1975. 5. 13. 선고 74다1664 전원합의체 판결 참조

164) 조관행(주112), 515.

채권자의 주소지가 아니므로 압류채권자의 주소지에서 제기한 추심소송은 관할위반으로 된다.^{165) 166)}

IV. 추심소송의 당사자

1. 원고

가. 추심소송의 원고는 피압류채권에 대하여 추심명령을 얻어 추심권을 취득한 채권자이다. 압류가 경합하고 있는 경우에도 압류채권자 중 1인은 추심명령을 얻어 단독으로도 소를 제기할 수 있다.¹⁶⁷⁾

채권에 대한 압류 및 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만 제기할 수 있고 채무자는 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실한다.¹⁶⁸⁾ 다만 채권자는 현금화절차가 끝나기 전까지 압류명령의 신청을 취하할 수 있고, 이 경우 채권자의 추심권도 당연히 소멸하게 되며, 추심금청구소송을 제기하여 확정판결을 받은 경우라도 그 집행에 의한 변제를 받기 전에 압류명령의 신청을 취하여 추심권이 소멸하면 추심권능과 소송수행권이 모두 채무자에게 복귀한다.¹⁶⁹⁾ 이는 채권자가 압류명령은 그대로 둔 채 추심명령만을 취하한 경우도 동일하다. 또한 국가가 국세징수법에 의한 체납처분으로 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 압류하였다가 압류를 해제한 경우에도 마찬가지이다.¹⁷⁰⁾

2인 이상의 불가분채무자 또는 연대채무자(이하 ‘불가분채무자 등’이라 한다)가 있는 금전채권의 경우에, 그 불가분채무자 등 중 1인을 제3채무자로 한 채권압류 및 추심명령이 이루어지면 그 채권압류 및 추심명령을 송달받은 불가분채무자 등에 대한 피압류채권에 관한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고 추심채무자는 그 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실하지만, 그 채권압류 및 추심명령의 제3채무자가 아닌 나머지 불가분채무자 등에 대하여는 추심채무자가 여전히

165) 浦野雄幸(주152), 681.

166) 채권이 지참채무일 때 전부명령을 얻은 경우에는 관할법원이 채무의 이행지인 전부채권자의 주소지를 관할하는 법원으로 바뀌게 된다(민사소송법 제8조). 이 경우 증가된 비용은 전부채권자가 부담하여야 할 것이다(민법 제473조 단서 유추).

167) 竹下守夫, 民事執行法の論点(1985), 239.

168) 대법원 2000. 4. 11. 선고 99다23888 판결 등

169) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2009다48879 판결

170) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2009다48879 판결

채권자로서 추심권한을 가지므로 나머지 불가분채무자 등을 상대로 이행을 청구할 수 있고, 이러한 법리는 위 금전채권 중 일부에 대하여만 채권압류 및 추심명령이 이루어진 경우에도 마찬가지이다.¹⁷¹⁾

나. 나아가 다른 채권자가 추심소송을 제기하고 있는 때는 소송을 제기하지 않은 경합채권자는 그 소송에 공동소송참가(민집 제249조 제2항, 민소 제83조)할 수 있다. 법정소송담당설에서는 다른 채권자가 별개로 소송을 제기하는 것은 중복소송으로 허용되지 않는 것이라고 해석하지만,¹⁷²⁾ 고유적격설에 의할 경우 민사집행법 제249조 제3항에 따라 참가명령을 받은 채권자가 별개로 소송을 제기한 때는 참가명령 제도의 취지를 존중하여 피고의 신청에 의해 전소에 병합(법원이 다른 경우는 이송한 후)해야 한다고 보고 있다.¹⁷³⁾

다. 추심권을 가지는 채권자의 추심명령의 전제가 되는 압류명령이 취소되거나 압류명령의 신청이 취하된 경우 혹은 추심명령이 취하·취소된 경우, 즉 채권자의 추심권이 상실된 경우에 그것이 소송에 어떠한 영향을 미칠 것인가가 문제로 될 수 있다.

이에 관하여 법정소송담당설의 입장에서는 추심권의 존재를 소송수행의 요건으로 보고 있으므로 그 흠결에 대하여 당해 소를 각하해야 한다고 하거나 또는 민사소송법 제237조의 적용 내지 유추적용에 의해 소송절차를 정지하고 채무자가 이를 수계해야 한다고 주장하게 된다. 고유적격설은 추심권의 존재를 단지 소송수행권한에 머무르지 않고 청구원인사실로 보고 있으므로 이 경우 원고(채권자)의 추심소송은 기각된다(소 제기 전에 그와 같은 상태였다면 그 청구는 당연히 기각되고, 소송수행과정에서 그와 같은 상태로 되었다면 그 단계에서 소송절차는 중단될 것이다).

라. 또한 채권자(원고)가 승소판결확정 후에 추심권을 상실한 경우, 법정소송담당설은 채무자가 승계집행문을 얻어 제3채무자에 대하여 강제집행을 할 수 있다고 보지만(절충설도 동일), 고유적격설의 입장에서는 채무자에게 청구이익의 소를 인정하게 될 것이다.

2. 피고 등

가. 추심소송의 피고는 피압류채권의 채무자(제3채무자)이다.

171) 대법원 2013. 10. 31. 선고 2011다98426 판결

172) 浦野雄幸(주152), 681.

173) 中野貞一郎(주154), 549.도 같은 취지라고 생각된다.

나. 집행채무자(피압류채권의 채권자)가 추심소송에 민사소송법 제83조의 공동소송참가를 하는 것이 가능한가.

이에 대하여 법정소송담당설에서는 공동소송참가(민소 제83조)를 인정하지만, 고유적격설은 보조참가(민소 제71조)만을 인정한다. 다만 법정소송담당설을 취한다고 하더라도 우리 민사소송법의 경우 채권자대위소송에 있어서의 채무자, 선정당사자에 의한 소송에 있어서 선정자 등에 대하여 중복제소금지에 저촉됨을 이유로 공동소송참가가 아닌 공동소송적 보조참가를 인정하고 있으므로,¹⁷⁴⁾ 이와 그 구조가 유사한 추심소송에 있어서도 동일하게 해석할 여지가 있다.¹⁷⁵⁾

다. 이 경우 집행채무자가 별도로 피압류채권의 지급을 청구하는 것이 가능한 것인가에 대하여도 법정소송담당설에서는 이를 허용하지 않고 그러한 경우에는 중복소송으로 각하해야 한다고 보지만,¹⁷⁶⁾ 고유적격설은 이 경우에도 집행채무자가 별도로 피압류채권의 지급을 청구할 수 있다고 보며,¹⁷⁷⁾ 다만 이때에 취득한 판결은 압류가 취하 등에 의해 효력을 상실할 때까지 집행할 수 없는 것이라고 한다. 또한 압류 후 그 취하 전에 피압류채권의 변제 효력이 생긴 때는 제3채무자인 피고가 집행채무자가 제기한 별소에서 그 사유를 청구이의사유로서 주장할 수 있다고 본다.¹⁷⁸⁾

3. 소송고지의무

가. 채권자가 제3채무자에 대하여 소를 제기한 때에는 채무자에게 소송고지를 하지 않으면 안 된다(민집 제238조). 그러나 채무자가 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 고지를 생략할 수 있다(민집 제238조 단서). 이때 소송고지의 방식은 민사소송법 제85조¹⁷⁹⁾의 규정에 의한다.

이처럼 채무자에게 소송고지를 하도록 한 것은 추심소송의 본안판결은 채무자에게도 기판력이 미치므로(법정소송담당설), 채무자에게 보조참가(공동소송적 보조참가)

174) 법원실무제요 민사소송[1], 법원행정처(2005), 308.

175) 한편 판례는 상법 제404조 제1항에 따라 회사가 주주의 대표소송에 대한 참가의 성격을 공동소송참가로 보고 있다.

176) 原田和徳/富越和厚, “執行關係等訴訟に關する實務上の諸問題, 法曹會刊(1983), 344.

177) 田中康久(주154), 336.; 中野貞一郎(주154), 551.; 이 경우 소송물은 다르지만 추심소송과 병합심리가 가능하다고 한다.

178) 田中康久(주154), 336.

179) 민사소송법 제85조 [소송고지의 방식]

① 소송고지를 위하여서는 그 이유와 소송의 진행정도를 적은 서면을 법원에 제출하여야 한다.

② 제1항의 서면은 상대방에게 송달하여야 한다.

할 기회를 주는 동시에 나중에 이 소송에서 원고인 채무자가 패소한 경우에 그 참가적 효력으로서 채무자로부터 부당히 패소하였다고 비난받는 것을 면하는 데에 필요가 있기 때문이다.

나. 이 소송고지의무는 추심명령에 기초한 소송의 경우뿐만 아니라 전부명령이나 양도명령에 기초한 소송의 경우, 압류채권자가 아닌 집행력 있는 정보를 가진 채권자가 민사집행법 제249조 제2항에 의하여 추심소송에 공동소송인으로 참가하는 경우에도 발생하고, 또한 이행을 청구하는 경우뿐만 아니라 당해 채권의 확인을 청구하는 경우에도 인정된다.¹⁸⁰⁾

다. 채권자가 지급명령을 신청한 경우에는 제3채무자의 이익에 의하여 통상소송으로 이행한 후에 채무자에게 소송고지를 하면 족하다.¹⁸¹⁾ 법문상 소송고지는 채권자의 의무로 되어 있으므로 채권자는 반드시 고지의 이유, 소송의 정도를 기재한 서면을 작성하여 법원에 제출하여야 한다(민소 제85조 제1항). 그러나 이 소송고지는 채권자의 추심의 소재기 자체에 대한 필요적 요건도 아니고 법원의 직권조사사항도 아니다.¹⁸²⁾

라. 채권자가 위와 같은 소송고지를 한 때에는 채무자가 추심소송에 보조참가(공동소송적 보조참가)를 하지 않더라도 채무자에게 참가적 효력(민소 제86조, 제77조)이 미친다.

마. 채권자가 소송고지를 게을리하고 그로 말미암아 패소함으로써 채무자에게 손해가 발생한 때에는, 명문의 규정은 없으나 채무자는 채권자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있고, 이 경우 채권자는 제대로 소송고지를 하였더라도 패소하였을 것이라는 점을 항변으로서 주장·입증하지 못하면 손해배상책임을 면하지 못한다.¹⁸³⁾

바. 고지의무를 게을리 한 효과는 채권자와 채무자 사이에서만 발생하므로 제3채무자가 소송고지가 없었음을 이유로 항변할 수는 없다. 그러나 일반원칙에 따라 스

180) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 373.

181) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 96.; 宮脇幸彦(주6), 147.

182) 대법원 1976. 9. 28. 선고 76다1145, 1146 판결【판결요지】제3채무자가 채무명의를 얻은 소외 회사에 공사대금채무를 임의변제하였다 하더라도 동 채무명의를 성립되기에 앞서 채권자의 채권압류명령이 유효히 발효되어 있었고 당시 소외 회사는 가압류채권에 불과하여 그 이후에 같은 공사대금채권에 대하여 채무명의로만 얻었을 뿐이므로 제3채무자는 그 변제의 결과를 채권자에게 대항할 수 없으며 추심명령을 얻은 채권자에게 압류채무를 이행할 의무가 있다 할 것이다.

183) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 373.; 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 97.; 宮脇幸彦(주6), 147.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 407.

스로 채무자나 다른 채권자에 대하여 소송고지를 할 수는 있다.

V. 추심권의 발생원인 및 범위

1. 추심권의 발생원인

추심권의 발생원인은 압류명령을 전제로 한 추심명령의 발령과 그것의 제3채무자 및 채무자에 대한 송달 사실이다. 자세하게는, ① 압류명령·추심명령의 발령, ② 압류명령·추심명령의 제3채무자에 대한 송달, ③ 압류명령·추심명령의 채무자에의 송달 등이다.

추심소송에 있어서는 원고로 되는 압류채권자에게 위와 같이 추심권이 있을 것이 전제로 되어 있으므로 원고는 피압류채권의 존재를 주장하는 외에 압류명령·추심명령의 존재, 추심권의 범위, 추심권의 발생사실(압류명령·추심명령의 발령과 제3채무자와 채무자에 대한 송달 사실)을 주장하고¹⁸⁴⁾ 이에 대하여 입증해야 한다.

급료 등의 계속적 수입채권의 경우나 예금 등 채권의 경우에는 제3채무자의 협력을 얻지 않으면 피압류채권의 특징이 쉽지 않지만, 어느 채권을 어느 한도에서 압류하고 있는 것인가에 대하여 제3채무자가 판단하는 것이 가능한 정도로는 특정하여야 하고, 그렇지 않으면 그 압류명령은 무효이므로(그에 따라 추심명령도 효력 없음), 그 보정을 명한 후 그에 응하지 않으면 소장을 각하할 것이다.

또 압류명령·추심명령에 대하여 즉시항고가 제기되어도(민집 제227조 제4항, 제229조 제6항), 집행법상 즉시항고에는 집행정지의 효력이 없으므로(민집 제15조 제6항) 추심권은 소멸하지 않는다. 즉시항고와 함께 집행정지결정이 있으면, 법원사무관 등은 집행정지의 취지를 채권자와 제3채무자 등에게 통지해야 하지만(민집규 제161조 제1항), 집행정지결정의 존재는 후술하는 바와 같이 추심소송판결을 집행하는 데 있어서의 장애사유는 될 수 있지만, 추심소송의 제기·수행을 저지하는 효과를 가지고 있다고 보기는 어렵다 할 것이다.¹⁸⁵⁾

2. 추심소송의 소송물 및 추심권의 범위

추심소송에 있어서 소송의 대상으로 되는 것은 피압류채권에 기초한 청구권(채무

184) 별지서식 [4-5] 추심소송의 소장 및 [4-6] 추심명령에 의한 부동산소유권이전등기청구소송 소장 등 참조(제4장 말미 수록)

185) 東京地裁債權執行等手續研究會(주113), 140.

자의 제3채무자에 대한 청구권)의 유무 및 그 범위이며, 청구채권에 기초한 청구권(압류채권자의 채무자에 대한 청구권)의 유무에 대한 것이 아니다(이에 대한 다툼은 청구이의의 소로 해야 한다). 따라서 제3채무자는 추심소송에 있어서 청구채권의 유무를 다툴 수 없다.

추심소송에 있어서 압류채권자는 채무자가 할 수 있는 주장을 하여 피압류채권의 급부를 구할 수 있지만, 청구할 수 있는 급부내용은 피압류채권에 대하여 추심권이 생기는 범위에 의하여 규제된다. 그래서 먼저 검토되어야 하는 것은 압류명령에 의해 압류된 채권은 어느 범위의 채권인가, 즉 채권자가 압류명령에 의해 취득한 추심권은 어느 범위의 채권에 대하여 생기고 있는가의 문제이다.

가. 피압류채권이 일회성의 채권(임금, 특정물매매대금 등)인 경우

1) 압류의 효력범위가 한정되지 않은 경우

가) 이 경우에는 채권자의 청구채권액이 피압류채권에 미치지 못하더라도 압류의 효력이 피압류채권 전부에 대하여 미치고, 추심명령에 특별한 제한이 없는 한 추심권의 범위 또한 압류된 채권 전액에 미치게 되므로(민집 제232조 제1항), 피압류채권의 전부가 추심권의 범위에 속하게 된다. 예컨대 500만 원의 집행채권 등을 가지고 1000만 원인 피압류채권 전부를 추심하는 것은 500만 원의 집행채권 등을 가지고 1000만 원 상당의 1개 부동산을 경매하는 것과 다를 바 없는 것이다.

나) 그리고 압류 후에 발생하는 이자나 지연손해금은, 원본채권과 사이에 주물과 종물의 관계에 있고, 주물에 대한 압류의 효력은 종물에 미친다는 일반원칙에 따라 피압류채권의 원본만을 표시하여 압류명령·추심명령이 발하여졌더라도 그 효력 발생 후에 발생하는 이자, 지연손해금에 대해서는 압류·추심명령의 효력이 미친다고 볼 것이다. 따라서 추심소송으로 압류 후 완제시까지의 지연손해금도 청구하는 때의 청구 취지는 원본 외에 지연손해금 청구를 표시하여, 「피고는 원고에게 금 1,000만 원 및 이에 대하여 2018. 〇〇. 〇〇.부터 완제일까지 연 〇〇%의 비율에 의한 돈을 지급하라.」는 형태가 될 것이다.

다) 그러나 채권자는 압류가 피압류채권의 전부에 대하여 미치는 경우라도 피압류채권의 일부에 대해서만 추심명령을 얻을 수 있다. 그리고 채무자도 추심할 금액이 채권자의 청구채권액(집행채권 및 집행비용)보다 많을 때에는 집행법원에 대하여 압류액을 위 청구액으로 제한하여 줄 것을 신청할 수 있다(민집 제232조 제1항 단서). 이 경우에는 추심권의 범위가 제한된 피압류채권의 일부에 그치게 된다.

2) 압류의 효력 범위가 한정된 경우

예를 들어, 1,000만 원인 피압류채권에 대하여 채권자 甲이 500만 원의 청구채권으로써 그 청구채권액 범위에서 피압류채권을 압류한 경우에는 압류의 효력도 그 범위에서 미치게 되고, 위 甲이 추심명령을 얻더라도 그 추심권의 범위는 압류된 피압류채권 한도에 그칠 뿐이다. 추심명령은 압류명령을 전제로 하므로 압류되어 있지 않은 부분에 대하여 추심권이 미치지 않는 것은 당연하다.

또한 이 경우에도 압류한도액의 원본채권에 대하여 압류의 효력이 생기는 것과 함께 그 원본채권에 대하여는 압류 후에 발생하는 지연손해금에 대하여 채권자의 추심권이 미치게 된다.

채권의 일부가 압류된 후에 다른 채권자가 그 나머지 부분을 초과하여 다시 압류한 때에는 당해 채권의 전액에 대하여 압류의 효력이 미치게 되기 때문에(민집 제 235조 제1항), 이 경우의 추심권의 범위가 문제로 된다.

이 경우 원칙적으로 압류의 효력이 확장되어 추심명령에서 특히 한정하지 않은 추심권의 범위도 확장된다고 보는 것이 옳을 것이다.¹⁸⁶⁾ 다만 일부 압류의 부분에 대해서만 추심명령이 발하여진 후에 압류경합이 생긴 때에는 제3채무자가 그 사실을 말하지 않는 한 추심채권자로서는 압류경합의 사실을 판별할 수 없기 때문에 실제로 이전의 추심명령에서 정한 범위 이상으로 추심권을 행사하기는 어렵다고 할 것이다.

나. 피압류채권이 급료 그 밖의 계속적 급부에 관계된 채권인 경우

급료채권 등의 계속적 급부를 목적으로 하는 채권을 피압류채권으로 하는 경우에는 압류의 효력은 집행채권(청구채권) 및 집행비용의 액을 한도로 하여 압류 후에 받아야 할 급부에 미치게 된다.¹⁸⁷⁾ 그와 같은 경우에, 피압류채권의 원본 외에 그 원본에 대하여 생기는 지연손해금도 압류의 대상으로 된다고 볼 것인가가 문제로 된다.

이 경우에 급료채권의 원본액이 압류의 한도액에 미치지 않는 때(예컨대 중도에 퇴직한 경우)에는 지연손해금에도 압류의 효력이 미치고, 초과한 때 또는 동액인 때에는 압류의 효력이 미치지 않는다는 견해¹⁸⁸⁾ ¹⁸⁹⁾도 있다.

186) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 353.

187) 이시운, 신민사집행법(제6보정판), 박영사(2014), 420.

188) 吉野 衛/三宅弘人 共著, 香川保一 監修, 注解民事執行法(6), きんぎい, 平成 7年(1995), 563.

189) 이는 즉 압류의 한도액이 1,000만 원인데 채무자가 중도 퇴직할 때까지의 급료채권의 원본액이 800만 원이라면 그 원본액이 압류 한도액에도 미치지 못하므로 그 원본액의 지연손해금까지 포함하여 압류의 효력이 미치고 있다고 보고, 그와 달리 급료채권의 원본액이 이미 1,000만 원 이상인 경우에는 그것만으로도 압류의 한도액에 충분하므로 그 원본액의 지연손해금에 대하여는 이에 끌어들이 필요도 없어서 압류의 효력이 미치지 않는다고 보는 것이다.

그러나 이와 같이 압류의 한도까지 지연손해금을 포함시키기 위해서는 제3채무자가 각 월의 급료채권의 원본마다 그에 해당하는 지연손해금의 발생상황을 정확히 계산하고 그 시점에서 원본과 지연손해금의 총합계가 압류의 한도에 달하는가를 계산으로 확정하여 그 결과에 따라 압류·추심의 범위를 확정하여야 하는데, 일반국민(제3채무자)의 입장에서 그것이 용이하지 않은 것임은 자명하다(즉 이를 위해서는 제3채무자가 급료의 지급일마다 그때까지의 압류된 원본액을 검토해야 하고 또 그 원본액에 대하여 우선 지연손해금이 발생하고 있는가 어떤가를 점검해야 하지만, 그렇게 하려면 그 채무를 추심채무라고 볼 것인가 혹은 지참채무라고 볼 것인가를 제3채무자의 책임으로 판정해야 하는데, 법률가도 아닌 일반국민의 법률지식으로 그것이 가능하지가 않다. 그리고 제3채무자가 지연손해금이 발생하고 있는 것과 발생하고 있지 않는 것을 나누어 발생하고 있는 것에 대하여만 시기를 확정하여 급료의 지급기마다 그때까지의 지연손해금을 계산하여 그 누계액을 산정한 후 압류된 원본액과의 총합계를 산출하여 그 액과 압류의 한도액과를 비교한 다음 그 차액의 유무에 따라 계산을 해야 하지만, 그와 같은 번잡한 계산을 제3채무자가 감당할 수 있다고 보기 어렵다).

압류의 효력이 지연손해금에 미친다는 이론은, 지연손해금은 급료채권의 원본에 대하여 종물이므로 주물인 급료채권의 처분에 따르는 것이 적당하다는 것에 있다. 이 주물·종물의 이론은 주물에 해당하는 것이 이미 타인의 것으로 되어 있는데도 종물에 불과한 것이 종전 권리자에게 남아 있다는 것은 상당하지 않다는 실질적 가치판단이나 종물은 통상 주물과 경제적으로 보아 일체의 관계에 있고, 예컨대 종물은 주물의 경제적인 가치를 동일수준에서 유지하는 기능을 가지고 있는 것이기 때문에 어지간하지 않는 한 그 분리를 인정하지 않는 것이 타당하다는 것에 기초하고 있다. 그와 같은 견해에서 보면, 일단 주물의 종된 권리에 대하여 주물인 원본채권과의 분리를 인정하는 것은 압류의 효력을 지연손해금에 미치는 것으로 하는 근본이론 자체를 부정하는 것으로 되므로 이러한 주물종물의 이론은 그것을 실현하는 데 있어서 특히 곤란한 문제가 없는 경우에는 당사자간의 권리관계의 균형을 보장하고 권리 실현을 확보하기 위해 충분히 존중해야 하는 원칙이기는 하다.

그러나 다른 한편, 그것을 실현하고자 할 때에 위의 제3채무자와 같이 본래는 당사자의 권리관계로부터는 외부에 있는 사람에 대하여, 무용의 또는 다소 가혹한 부담을 지우게 되는 경우 그 이론을 관철시킬 것인가 아닌가를 재고할 필요가 있게 된다. 급료채권의 지연손해금과 같이 일반적으로는 극히 소액인 것에 대하여, 지연손해

금의 지급이 없으면 급료의 지급을 받았다고 말하기 어렵다는 일반적인 의식이 존재한다면 몰라도, 그렇지 않다면 이 경우에 주물·종물의 이론을 관철시켜 제3자에게 위와 같이 상당한 부담을 지워도 될 만한 중요한 이익상황이 존재한다고 말할 수는 없다고 본다. 그리고 제3채무자 이외의 급료생활자 등의 이익보호의 관점으로부터 보아도 압류의 범위의 계산방법이 복잡하면 지급을 받아야 하는 금액을 파악하기가 곤란하게 되어 손해를 받을 가능성도 있으므로 문제가 없다고 말할 수 없다.

이렇게 보면, 압류채권자의 입장에서는 약간 불리하지만, 급료 등 계속적 수입채권에 있어서 대부분 그다지 큰 금액이 아닌 지연손해금에 대하여 무리를 하여 압류의 효력이 미치고 있는 것으로 취급하는 것은 상당하지 않고, 원본만으로 계산하면 족하다고 해석하는 것이 실제에도 부합하는 것이라고 생각된다. 이상과 같은 고려에 입각하여, 급료채권 등의 계속적 급부를 목적으로 하는 채권의 경우는 지연손해금이 압류의 대상으로 되지 않는다고 볼 것이다.¹⁹⁰⁾

VI. 추심소송의 청구원인

추심소송의 청구원인으로서 기재해야 하는 사항은, 크게 나누어 다음 3종의 사항이다.

즉 ① 압류명령·추심명령이 발령되어 그 효력이 생기고, 그 결과 추심권이 생겼다는 것(즉 추심권의 발생) ② 어느 범위의 채권이 압류되고, 채권자(원고)가 추심권을 가지고 있는지 여부(즉 소송물의 특정) ③ 피압류채권의 발생원인인 요건사실(계약 등, 또한 필요가 있으면 반대급부의 이행 여부) 등이 그것이다.

①의 추심권의 발생은, 구체적으로는 앞서 본 V. 1.의 추심권 발생원인과 그 입증에 있어서 서술한 사실을 주장·입증하는 것에 의해서 인정된다.

②의 소송물의 특정 즉 추심권이 생기는 범위는, 앞의 V. 2.에서 본 추심권의 범위에서 서술한 바에 따라 판정할 수 있을 것이다.

그리고 ③의 피압류채권의 발생원인사실은, 그 피압류채권 자체의 청구소송에 있어서의 청구원인과 다를 것이 없다[추심소송의 소송물이 추심권과 그 대상인 피압류채권에 의하여(고유적격설) 또는 피압류채권에 의하여(법정소송담당설) 특정되고 그에

190) 東京地裁管内簡易民事事務調査會, “取立訴訟の請求原因”, 最高裁判所事務總局 編·簡易裁判所民事事務調査會の研究報告書集(民事裁判資料第188号, 平成2年), 205-207.; 東京地裁債權執行等手續研究會(주113), 145.

기초하는 것이므로 피압류채권의 발생원인사실을 기재할 필요가 있다.

다만 추심소송에서는 피압류채권의 발생원인사실 등을 직접 경험하지 않은 채권자가 원고나 신청인이 되어 주장·입증해야 하고, 이러한 사실에 관한 증거자료의 수집에 있어서 채무자의 협력을 얻을 수 없는 경우에는 원고는 외형상 알고 있는 사실을 주장할 수밖에 없어서, 법원으로서의 피고(제3채무자)가 정확한 사실을 반론해줄 것을 기대하여야 하며, 반론이 없는 경우에는 원고가 주장하는 외형상 알 수 있는 사실만으로 원고의 청구를 판단하는 수밖에 달리 방법이 없다. 특히 피압류채권이 급료 등 계속적 급부에 관계된 채권인 경우에는 고용계약 등의 당사자가 아닌 원고가 피압류채권의 발생원인사실이나 어느 기간의 급료채권까지 이미 추심권이 발생하고 있는가를 인식하는 것이 상당히 곤란하다. 이와 같은 곤란이 있어서 원고가 주장하는 청구원인이 불특정하여 원고가 받은 판결의 기판력 범위가 불명확하게 되거나 원고가 추심권을 취득하여 판결(또는 지급명령)을 얻은 피압류채권과 다른 경합채권자가 압류한 피압류채권이 동일한 채권인가 어떤가가 구별되지 않으면, 원고나 다른 경합채권자 뿐만 아니라 제3채무자나 집행채무자에게도 무의식중에 손해를 주게 될 수도 있다.

따라서 추심소송의 원고는 최소한 추심권을 얻은 피압류채권의 범위를 명확하게 할 의무가 있고, 이 점이 명확하지 않은 소나 지급명령의 신청은 소송물을 특정하지 않아 부적법하다고 볼 여지가 있으므로 그 보정을 명하여야 한다.

급료채권에 대한 추심소송의 경우 원고는 집행채무자가 제3채무자로부터 지급받을 급료나 상여금의 수취액을 주장하고 그 가운데 어느 기간의, 얼마의 금액이 압류되어 있는가를 주장하게 되지만, 고용계약의 당사자가 아닌 원고로서는 급료나 상여금의 수취액에 대하여 외형적 사실로서 확실하다고 인정되는 최저한의 금액을 주장하면 족하고 그 이상의 정확한 금액은 피고(제3채무자)의 반론을 기대해야 할 것이다.

Ⅶ. 피고(제3채무자)의 답변 및 항변

원고(압류채권자)의 청구원인에 대하여 피고(제3채무자)가 주장할 수 있는 답변이나 항변은 추심권에 관한 주장과 피압류채권에 관한 주장으로 나누어 볼 수 있다.

1. 추심권에 관한 항변

추심권의 발생은 법정소송담당설의 입장에서 볼 때에는 당사자적격을 기초지우

는 사실이지만,¹⁹¹⁾ 고유적격설의 견해에서는 청구원인을 구성하는 요소 중 하나가 된다.

추심권에 관하여 피고가 제출할 수 있는 항변은, 절차적인 원인으로 추심권이 발생하지 않았거나 소멸하였다는 것 외에, 실체적으로 그것이 소멸하였다는 것을 포함한다. 이때에 추심권의 발생이나 그 절차적인 원인 혹은 실체적인 원인에 의한 불발생·소멸은, 법정소송담당설에서는 소송요건이므로 법원의 직권조사사항이 된다.¹⁹²⁾ 고유적격설의 입장에서는 변론주의하에서 주요사실이 되고, 단순한 소송요건은 아니라고 본다.

이러한 추심권에 관하여 피고가 제출할 수 있는 항변을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

가. 압류명령의 무효

피압류채권이 압류 적격을 흠결하여 추심명령의 전제가 되는 압류의 효력이 생기지 않는 경우에는 추심권도 부정된다. 압류명령에 절차 위배가 있으면 압류명령을 취소해야 하지만, 항고법원의 취소결정이 있지 않으면 무효인 경우와 달리 추심권에 영향이 없다.¹⁹³⁾

나. 집행의 취소결정 또는 집행신청의 취하가 있었던 사실

추심소송은 채권자의 압류가 존속하고 있는 것이 전제조건이므로 압류가 압류명령의 취소나 압류명령신청의 취하로 효력을 가지지 않게 된 경우나 민사집행법 제50조, 제266조 제2항의 규정에 의해 집행권원의 집행력이 소멸한 경우에는 제3채무자가 이를 주장할 수 있다.¹⁹⁴⁾

집행취소문서를 채무자가 소지하고 있지만 아직 압류명령이 취소되지 않은 경우에 제3채무자가 추심권 부존재의 항변을 주장할 수 있는가가 문제로 되지만, 취소문서에 해당하는가 어떤가는 집행법원이 판단해야 하는 것이고 집행절차 외의 법원인 수소법원에서 판단하는 것은 상당하지 않기 때문에 소극적으로 볼 것이다.¹⁹⁵⁾

191) 原田和徳/富越和厚(주176), 355.

192) 原田和徳/富越和厚(주176), 355.

193) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(4), 587.

194) 岩野徹 外 編, 위 注解強制執行法(2), 406, 475.

195) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(4), 588.

집행정지문서가 제출된 경우에는 추심권 행사에 어떠한 영향을 줄 것인가가 또한 문제로 된다. 이에 대하여는 ① 추심권의 행사를 방해하는 실체적인 사유로 된다는 설(실체사유설),¹⁹⁶⁾ ② 이는 부활의 여지를 남긴 소송활동의 금지이므로 소송절차의 중단 규정을 유추하여 소송을 일시적으로 중단해야 한다는 설,¹⁹⁷⁾ ③ 이는 새로운 집행상태의 작출을 방해하는 것이므로 추심소송의 제기 전에는 원고의 당사자적격에 장애사유가 되지만 제기 후라면 소송의 속행을 방해하지 않고 다만 현실의 지급을 방해하는 것으로만 된다는 설(집행장애설의 일종),¹⁹⁸⁾ ④ 현실의 지급(배당금등의 지급)을 방해하는 집행장애사유로 된다는 설(집행장애설)¹⁹⁹⁾등이 나타나고 있으나, 집행정지결정에 대하여 추심소송의 제기·수행이나 판결의 취득을 방해하는 것으로 하는 것은 장래 집행정지가 해소될 경우를 고려하면 너무 과도한 효력을 부여하게 된다고 보여지므로 집행취소결정과 달리 추심권 소멸 사유가 아니고 단지 집행장애사유로 된다고 할 것이다. 따라서 ④의 집행장애설이 타당하다고 본다.

다. 원고가 추심권에 기초한 급부를 받을 권리를 실체법적으로 상실한 것

원고가 집행채권을 다른 사람에게 양도한 경우 압류채권자로서의 지위도 이것과 함께 양수인에게 이전하고 그에 따라 원고가 추심권에 의해 급부를 받을 권리도 실체법적으로 상실하게 된다. 그렇게 되면, 피고는 그와 같은 채권양도의 사실을 주장하여 원고의 청구를 배척할 수 있다.²⁰⁰⁾

또한 경합하는 채권자나 배당요구채권자가 없는 경우에 원고가 자신의 권리를 자동채권으로 하여 피고를 채권자로 하고 자신을 채무자로 하는 수동채권과 사이에서 상계한 때는 그 효력이 생기고, 그 상계의 한도에서 원고는 추심권에 의해 급부를 받을 권리를 상실한다.²⁰¹⁾ 피고는 이와 같은 상계의 효과를 주장하여 원고의 주장을

196) 日大阪高判 昭和 39(1964), 12, 16.(判タ 173号 139.)

197) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(4), 590.

198) 原田和徳/富越和厚(주176), 381.

199) 中野貞一郎(주154), 547.; 中務, “債權取立命令による取立と執行の停止”, 民事訴訟雑誌12号(1966), 13, 이하

200) 또한 원고로부터의 채권양도 등의 특정승계가 있으면, 양수인은 민사소송법 제79조에 의해 참가하여 소송을 수계할 수 있다. 그리고 원고의 사망에 의한 상속, 합병 등의 일반승계가 있으면, 그 상속인 또는 흡수회사가 승계인으로서 소송을 수계하는 것은 말할 것도 없다[中野貞一郎(주154), 548, 참조].

201) 宮脇幸彦(주6), 146.; 田中康久(주154), 36.; 中野貞一郎(주154), 563.은 피압류채권을 자동채권으로 하는 상계를 허용한다.

배척할 수 있다.

그리고 피고가 원고(추심채권자)에 대하여 자동채권을 가지고 원고의 추심권에 의한 급부청구권을 수동채권으로 하는 상계에 대하여, 이를 허용하는 견해²⁰²⁾에 따르면, 피고는 이와 같은 상계를 항변으로 주장할 수 있다.²⁰³⁾

라. 집행채권이나 실행담보권의 부존재·소멸·감소·귀속 등에 관한 사유

집행채권의 부존재·소멸 등 사유의 주장은 추심권 부존재의 주장에 해당하지 않고 따라서 추심소송의 항변으로는 되지 않는다.²⁰⁴⁾ 그것을 이유로 압류채권자의 추심소송의 제기를 권리남용 또는 신의칙위반에 해당하는 것이라고 주장하는 것도 허용되지 않는다.²⁰⁵⁾ 다만 추심소송의 과정에서 집행채권의 부존재가 명확하게 된 때는 예외적으로 신의칙 위반을 이유로 하여 청구를 기각해야 한다는 견해가 있다.²⁰⁶⁾

집행채무자가 청구이의의 소를 제기하면 인용될 수 있는 사정이 있다는 것을 제3채무자가 알고 있어도 그와 같은 사정을 항변으로 제출하는 것은 가능하지 않다.²⁰⁷⁾ 그러나 집행채무자가 청구이의의 소, 압류·추심명령에 대한 즉시항고, 담보권 부존재의 확인의 소 등에 의하여 위 사실을 주장하고 그 승소판결 또는 결정을 얻어 이것을 집행법원에 제출함으로써 집행처분인 압류·추심명령이 취소되면, 피고(제3채무자)도 추심소송에서 그 집행취소의 결정을 추심권의 소멸원인으로서 주장할 수 있고 또 추심권의 부존재 주장을 항변으로 제출할 수 있다.

2. 피압류채권에 관한 항변

제3채무자는 추심권을 얻은 채권자의 청구가 있으면, 본래의 권리자인 집행채무자로부터 청구가 있었던 경우와 동일하게 채무를 이행해야 할 의무를 부담한다. 그러나 그 경우에도 집행채무자에 대하여 부담하는 것과 동일한 채무를 동일한 형태로 부

202) 이에 대하여는, 달리 경합압류채권자나 배당요구채권자가 없는 때는 허용된다고 보는 견해[東京地裁債權執行等手續研究會(주113), 151.], 추심명령 후에는 관계인의 이익균형을 위하여 허용할 것이라는 견해[松岡義正(주79), 1192.], 민사집행법 제232조 제1항 단서의 압류액 제한 허가가 있는 때에는 허용할 것이라는 견해[조관행(주112), 520.] 등이 있다.

203) 田中康久(주154), 335.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(4), 587.

204) 대법원 1996. 9. 24. 선고 96다13781 판결; 日最判 昭和 45(1970). 6. 11.(民集 24-6, 509; 判タ 251, 183); 三ヶ月章(주49), 392.; 浦野雄幸(주152), 680.

205) 日最判 昭和 45(1970). 6. 11.(民集 24-6, 509; 判タ 251, 183)

206) 中野貞一郎(주154), 546.; 石川, “取立訴訟と執行債權”, 判タ442号(1981), 2.

207) 대법원 1996. 9. 24. 선고 96다13781 판결

담하는 것에 불과하므로 집행채무자에 대하여 가지고 있었던 일체의 실제법상 주장을 하는 것이 가능하다.

가. 피압류채권의 성립관계에 대한 항변

제3채무자는 피압류채권의 성립에 관한 항변 등, 예컨대 계약의 부존재, 공서양속위반무효(민법 제103조), 진의아닌 의사표시(민법 제107조), 통정허위표시무효(민법 제108조), 착오의사표시(민법 제109조), 사기·강박에 의한 취소(민법 제110조), 동시이행의 항변(민법 제536조), 변제기의 미도래, 약정에 의한 계약해제 등의 주장을 할 수 있을 뿐만 아니라 신의칙위반(민법 제2조 제1항), 권리남용(민법 제2조 제2항), 불법원인급여(민법 제746조) 등 주장이 가능하다.

이들 중 형성권의 행사에 해당하는 것은 압류 전에 의사표시를 한 것에 그치지 않고 압류 후에 채무자에게 의사표시를 한 것도 항변으로서 주장할 수 있다.

추심소송은 압류채권자가 채무자의 권리를 대신하여 행사하고 있음에 불과하므로 위 항변 가운데 선의의 제3자에게 대항할 수 없는 통정허위표시, 사기에 의사표시 등에 대하여도 압류채권자가 악의인 경우에는 제3채무자가 이를 주장할 수 있다.

나. 채권양도

집행채무자가 피압류채권을 타인에게 양도한 경우 제3채무자는 그 채권양도에 의해 집행채무자가 채권자의 지위를 잃었다는 것을 원고(압류채권자)에게 항변으로 주장할 수 있다. 이 항변은 집행채무자의 권리상실의 항변이고, 그 요건사실은 집행채무자와 채권의 양수인 사이의 대물변제계약 그 밖의 채권양도의 효과가 생기는 계약의 성립 및 집행채무자의 제3채무자에 대한 확정일자 있는 채권양도통지 등 2가지이다(민법 제450조).

이에 대하여 원고(압류채권자)는 재항변으로서 압류명령의 송달이 위 채권양도통지의 도달시보다 선행한다는 것을 주장할 수 있고, 그 사실의 입증에 성공하면 승소판결을 얻을 수가 있다.

동시도달(선후불명을 포함)의 경우에 문제로 될 수 있는데, 이 경우 제3채무자는 민법 제487조 후문의 채권자불확지 변제공탁 및 민사집행법 제248조 제1항의 집행공탁을 합한 혼합공탁을 하는 것도 가능하고,²⁰⁸⁾ 압류채권자·채권양수인 어느 쪽에

208) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 567.

대하여도 변제가 가능하다고 해석되므로²⁰⁹⁾ 제3채무자가 일방에 대해 전액 변제하면 채무는 소멸하고 다른 청구는 기각된다. 그러나 제3채무자가 임의로 공탁 또는 변제하지 않는 경우에는 압류채권자는 전액의 지급을 구하는 추심소송을 제기하고 그 판결을 얻는 것이 가능하다. 이때에 제3채무자는 압류명령의 송달과 동시에 채권양도의 통지가 도달하였다는 취지의 항변으로 대항할 수 없다.²¹⁰⁾

다. 변제의 항변

제3채무자가 압류 전에 집행채무자에 대하여 변제하였으면 그 변제를 항변으로 주장할 수 있다.

압류채권자가 추심권을 행사하는 것에 대하여 제3채무자가 채권자에게 변제한 경우 이는 추심권에 의한 급부청구권에 대한 변제로서의 법률효과도 생기지만(민집 제236조 참조), 피압류채권 자체도 변제에 의해 소멸하므로 항변으로 될 수 있다.

또한 압류명령이 발령된 후 그것이 제3채무자에게 도달할 때까지 채무자에게 변제하였다면 그것을 가지고 압류채권자에게 대항할 수 있다. 압류명령 송달 후의 변제는 압류채권자에게 대항할 수 없다.

제3채무자가 피압류채권을 공탁한 경우 그 공탁이 유효로 된 때에는 제3채무자

209) 대법원 1994. 4. 26. 선고 93다24223 판결【판결요지】[1] 채권이 이중으로 양도된 경우의 양수인 상호간의 우열은 통지 또는 승낙에 붙여진 확정일자 선후에 의하여 결정할 것이 아니라, 채권양도에 대한 채무자의 인식, 즉 확정일자 있는 양도통지가 채무자에게 도달한 일시 또는 확정일자 있는 승낙의 일시의 선후에 의하여 결정하여야 할 것이고, 이러한 법리는 채권양수인과 동일 채권에 대하여 가압류명령을 집행한 자 사이의 우열을 결정하는 경우에 있어서도 마찬가지이므로 확정일자 있는 채권양도 통지와 가압류결정 정본의 제3채무자(채권양도의 경우는 채무자)에 대한 도달의 선후에 의하여 그 우열을 결정하여야 한다. [2] 채권양도 통지, 가압류 또는 압류명령 등이 제3채무자에 동시에 송달되어 그들 상호간에 우열이 없는 경우에도 그 채권양수인, 가압류 또는 압류채권자는 모두 제3채무자에 대하여 완전한 대항력을 갖추었다고 할 것이므로 그 전액에 대하여 채권양수금, 압류전부금 또는 추심금의 이행청구를 하고 적법하게 이를 변제받을 수 있고, 제3채무자로서는 이들 중 누구에게라도 그 채무 전액을 변제하면 다른 채권자에 대한 관계에서도 유효하게 면책되는 것이며, 만약 양수채권액과 가압류 또는 압류된 채권액의 합계액이 제3채무자에 대한 채권액을 초과할 때에는 그들 상호간에는 법률상의 지위가 대등하므로 공평의 원칙상 각 채권액에 안분하여 이를 내부적으로 다시 정산할 의무가 있다. [3] 채권양도의 통지와 가압류 또는 압류명령이 제3채무자에게 동시에 송달되었다고 인정되어 채무자가 채권양수인 및 추심명령이나 전부명령을 얻은 가압류 또는 압류채권자 중 한 사람이 제기한 급부소송에서 전액 패소한 이후에도 다른 채권자가 그 송달의 선후에 관하여 다시 문제를 제기하는 경우 기판력의 이론상 제3채무자는 이중지급의 위험이 있을 수 있으므로 동시에 송달된 경우에도 제3채무자는 송달의 선후가 불명한 경우에 준하여 채권자를 알 수 없다는 이유로 변제공탁을 함으로써 법률관계의 불안으로부터 벗어날 수 있다. [4] 채권양도 통지와 채권가압류결정 정본이 같은 날 도달되었는데 그 선후관계에 대하여 달리 입증 없으면 동시에 도달된 것으로 추정한다.

210) 日最判 昭和 55(1980). 1. 11.(民集 34-1, 42)

가 변제에 의해 피압류채권이 소멸하였다는 취지의 항변을 할 수 있는 것은 당연하다. 그 공탁은 민사집행법 제248조 제1항 내지 제3항에 의한 것에 한하지 않고 민법 제487조에 의한 것도 포함된다.

라. 상계의 항변

제3채무자가 집행채무자에 대한 채권을 가지고 하는 상계는, 일정한 한도에서 항변으로 될 수 있다. 즉 상계의 경우에는 제3채무자의 자동채권이 압류 전에 취득한 것이어야 한다(민법 제498조).²¹¹⁾

위 민법 제498조를 적용함에 있어서는 수동채권(압류된 채권) 및 자동채권의 변제기와 압류의 시기와의 관계(즉 자동채권·수동채권의 변제기와 관련하여 압류명령의 송달을 받기 이전에 상계적상에 있어야 하는가, 특히 자동채권의 변제기가 도래하고 있어야 하느냐)에 대하여 견해가 나뉘어지고 있는데, 우리 판례는 압류명령이 송달될 당시 제3채무자가 채무자에 대하여 가지는 채권(자동채권)과 압류된 채권(수동채권)이 모두 변제기에 도래하여 상계적상에 있었던 경우는 물론 상계적상에 있지 아니한 경우에도 자동채권만이 변제기가 지났거나, 또는 두 채권 모두 변제기가 지나지 않았더라도 자동채권이 먼저 또는 압류된 채권과 동시에 변제기에 도달할 경우에는 제3채무자의 상계를 허용하고 있다.²¹²⁾ 또 제3채무자가 압류채무자에 대한 사전구상권(민법 제442조)을 가지고 있는 경우에 상계로써 압류채권자에게 대항하기 위해서는 압류의 효력 발생 당시 사전구상권에 부착된 담보제공청구(민법 제443조)의 항변권이 소멸하여 사전구상권과 피압류채권이 상계적상에 있거나, 압류 당시 여전히 사전구상권에 담보제공청구의 항변권이 부착되어 있는 경우에는 제3채무자의 면책행위 등으로 인해

211) 다만 제3채무자의 압류채무자에 대한 자동채권이 수동채권인 피압류채권과 동시이행의 관계에 있는 경우에는, 압류명령이 제3채무자에게 송달되어 압류의 효력이 생긴 후에 자동채권이 발생하였다고 하더라도 제3채무자는 동시이행의 항변권을 주장할 수 있고, 따라서 그 채권에 의한 상계로 압류채권자에게 대항할 수 있다(대법원 1993. 9. 28. 선고 92다55794 판결; 대법원 2001. 3. 27. 선고 2000다43819 판결; 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004다37676 판결; 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007다35152 판결 등).

212) 대법원 1973. 11. 13. 선고 73다518 전원합의체 판결; 대법원 1982. 6. 22. 선고 82다카200 판결【판결요지】가압류 명령을 받은 제3채무자가 가압류 채무자에 대한 반대채권을 가지고 있는 경우에 상계로써 가압류 채권자에게 대항하기 위하여는 가압류의 효력발생 당시에 양 채권이 상계적상에 있거나, 반대채권이 압류 당시 변제기에 이르지 않는 경우에는 피압류 채권인 수동채권의 변제기와 동시에 또는 보다 먼저 변제기에 도달하는 경우이어야 된다.; 대법원 1989. 9. 12. 선고 88다카25120 판결【판결요지】채권가압류명령을 받은 제3채무자는 그 후에 취득한 채권에 의한 상계로 그 가압류채권자에게 대항하지 못하지만 수동채권이 가압류될 당시 자동채권과 수동채권이 상계적상에 있거나 자동채권의 변제기가 수동채권의 그것과 동시 또는 그보다 먼저 거래하는 경우에는 제3채무자는 자동채권에 의한 상계로 가압류채권자에게 대항할 수 있다.

위 항변권을 소멸시켜 사전구상권을 통한 상계가 가능하게 된 때가 피압류채권의 변제기보다 먼저 도래하여야 한다.²¹³⁾

이 경우 상계의 의사표시는 압류채권자 또는 채무자 어느 쪽에 해도 된다.²¹⁴⁾

마. 채무면제의 항변

압류명령이 제3채무자에 대하여 송달되기 전에 채무자가 채무면제의 의사표시를 한 경우에는 당연히 채무면제의 효력이 생기고 있으므로 제3채무자가 그 취지의 항변을 할 수 있다.²¹⁵⁾

하지만 채무자에 대한 압류명령의 송달 후에는 채무자가 압류와 저촉되는 처분을 하여도 그 효력을 채권자에게 대항할 수 없기 때문에 그 후의 채무면제는 압류채권자와의 관계에서 대항할 수 없다.

문제로 되는 것은 압류명령이 제3채무자에 대해 송달되었지만 채무자에게 아직 송달되기 전에 채무자가 선의로 채무면제의 의사표시를 한 경우이다. 압류의 효력은 압류명령이 제3채무자에게 송달된 때에 생기는 것으로 되어 있지만(민집 제227조 제3항), 채무면제는 채권자의 단독의사표시로 되어 있으므로 당해 채권의 채권자인 집행채무자가 압류의 존재를 모르고 채무면제의 의사표시를 한 경우에는 채무면제의 효과가 생기는 것으로 해석해야 할 것이다.²¹⁶⁾

바. 소멸시효의 원용

피압류채권에 대하여 소멸시효 기간이 도과한 경우에는 시효이익을 원용하는 것도 가능하다. 다만 채권자가 압류 및 추심명령을 발령받으면 시효가 중단되므로(민법 제168조 제2호, 제174조, 제175조, 제176조),²¹⁷⁾ 추심명령이 송달될 때까지 시효가 완성되어 있어야 한다.

사. 질권 존재의 항변

피압류채권에 대하여 압류 전에 소정의 대항요건을 구비한 질권이 설정되어 있었던 경우에는 질권자의 추심권(민법 제353조)이 우선하므로 제3채무자는 압류를 받아도 질권자에게 우선하여 지급할 의무가 있다. 그 때문에 압류채권자는 질권 설정이

213) 대법원 2019. 2. 14. 선고 2017다274703 판결

214) 日最判 昭和 39(1964). 10. 27.(民集 18-8, 1801) 참조

215) 中野貞一郎, 民事執行法(下), 546.

216) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 570.

217) 대법원 2003. 5. 13. 선고 2003다16238 판결 참조

되어 있는 것을 안 때에는 추심소송을 제기하지 않거나 제기하여도 그것을 알고 취하는 것이 통례일 것이지만, 압류채권자가 그 사정을 알면서 추심소송의 취하를 하지 않는 경우도 있을 수 있는데, 이 경우 제3채무자는 당해 피압류채권에 대하여 질권이 이미 설정되어 있다는 것을 항변으로 주장할 수 있는지 여부가 문제로 된다.

그러나 이 주장은 인정되지 않는다. 그것은 질권설정계약이 이후 무효로 되거나 취소 또는 해제될 가능성을 배제할 수 없고 따라서 압류채권자가 추심소송을 속행하는 것에 대하여 법적인 이익이 인정되기 때문이다.

물론 압류채권자가 추심소송에서 승소해도 질권이 해제되지 않는 한 질권의 대상으로 되어 있는 부분에 대한 강제집행은 허용되지 않는다.²¹⁸⁾

아. 피압류채권의 압류금지양도금지

제3채무자는 피압류채권이 압류금지의 대상인 취지 또는 성질상 양도금지이고 그에 따라 압류명령이 무효라는 취지를 주장할 수 있다.²¹⁹⁾ 이 경우에도 청구기각의 판결을 해야 한다.

그러나 채권발생의 원인인 계약 등에 부수하여 양도금지의 특약이 된 경우에는 압류채권자의 선의·악의를 불문하고 압류가 가능하기 때문에²²⁰⁾ 그에 관한 제3채무자의 항변은 인정되지 않는다.

Ⅷ. 채무자가 제기한 소송에 대한 영향

1. 채무자가 급부소송을 제기한 후 추심소송이 제기된 경우

가. 채무자가 제3채무자를 상대로 제기한 이행의 소가 법원에 계속되어 있는 경

218) 이와 동일한 상태는 체납처분과의 관계에서도 생길 수 있다. 체납처분에 의한 압류가 되어 있는 채권에 대하여도 강제집행에 의한 압류, 담보권의 실행 또는 행사로서의 압류도 허용되므로 이에 따라 민사집행의 압류채권자에 의한 추심소송의 제기도 허용되지만, 강제집행에 의한 압류채권자는 체납처분에 의한 압류가 되어 있는 부분에 대하여는 체납처분에 의한 압류가 해제되지 않는 한 추심이 가능하지 않다. 이와 같이 체납처분에 의한 압류가 선행하고 있는 데 민사집행법 규정에 의한 추심소송이 제기되어 있는 경우 제3채무자가 그 소송에서 체납처분에 의한 압류가 선행되어 있다는 취지의 항변을 주장하는 것이 가능한가 어떤가가 문제로 되지만, 이것도 소극적으로 해석해야 할 것이다. 즉 체납처분에 의한 압류가 해제되는 경우가 있을 수 있고 따라서 민사집행의 압류채권자가 추심소송의 판결을 얻어놓을 이익이 인정될 수 있기 때문이다. 물론 추심소송에서 승소판결을 얻어도 체납처분에 의한 압류가 해제되지 않는 한 그 압류부분에 대하여 강제집행을 하는 것은 인정되지 않는다고 볼 것이다.

219) 三ヶ月章(주49), 391.은 제3채무자가 압류명령이 무효인가 아닌가를 조사할 의무는 없으므로 선의로 추심명령에 응하여 지급하면 그 지급은 유효하다고 한다.

220) 宮脇幸彦(주6), 108.

우에도 압류채권자는 제3채무자를 상대로 압류된 채권의 이행을 청구하는 추심의 소를 제기할 수 있고, 제3채무자를 상대로 압류채권자가 제기한 추심의 소는 채무자가 제기한 이행의 소에 대한 관계에서 민사소송법 제259조가 금지하는 중복된 소제기에 해당하지 않는다.²²¹⁾

그런데 이와 같이 압류채권자가 추심명령을 얻어 추심소송을 제기한 시점에 이미 채무자가 급부소송을 제기하고 있었던 경우, 위 추심소송에 의하여 채무자가 제기하고 있는 소송이 어떠한 운명에 처하게 되는지가 문제로 된다.

압류채권자가 채권을 압류한 후 추심명령까지 얻게 되면 채무자의 추심권이 제한된다는 데에는 이론이 없지만, 압류명령·추심명령이 취소 또는 취하되면 압류·추심명령의 효력이 소멸하고 채무자의 소송수행권한이 회복될 수 있기 때문에, 이 문제는 압류·추심에 의해 추심권이 제한된 것을 강조하는가 아니면 그에 불구하고 추심권이 회복할 가능성이 있는 것을 강조하는가에 따라 견해가 나뉘어지고, 또 추심소송의 기판력이 채무자에게 미치는가 어떤가의 견해 차이에도 영향을 받게 된다.

나. 채권자의 압류·추심에 의해 채무자의 추심권이 제한되는 것을 강조하는 견해하에서는 압류·추심에 의해 채무자의 급부청구권이 제한되므로 채무자에 의한 급부의 소는 소송요건을 흠결하여 각하되며,²²²⁾ 이를 확인의 청구로 소를 변경하면 그 한도에서 청구를 인용하게 된다.²²³⁾ 이 견해하에서 다시 추심소송의 기판력이 채무자에게 미친다는 입장을 취하게 되면 추심소송의 제기에 의해 확인소송도 소송요건을 흠결하여 각하되기에 이른다. 이렇게 기판력이 채무자에게 미친다는 견해를 유지할 경우 채무자에 의한 급부소송이 이미 제기되어 있었던 때에 압류채권자가 추심소송을 제기하였다면 압류채권자는 민사소송법 제79조 및 제81조가 규정하는 권리승계인의 참가 방법에 의해 소송에 참가하고 채무자는 당해소송에서 탈퇴하게 된다.²²⁴⁾ 또 이 견해하에서는 압류명령이 취소되거나 채권자가 압류신청을 취하한 때는 소송절차가 중단되고 채무자가 이를 승계한다. 물론 추심권이 제한된 급부의 소가 소송요건을 흠결한다는 견해하에서도 기판력이 채무자에게 미치는 것을 인정하지 않는 견해도 있을 수 있다. 이 견해하에서는 확인판결을 인정하는 것으로 된다.

221) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2013다202120 전원합의체 판결

222) 兼子一(주4), 209.; 宮脇幸彦(주6), 149.; 岩野徹 外 編, 위 注解強制執行法(2), 357.

223) 松岡義正(주79), 1102.

224) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(4), 592.; 岩野徹 外 編, 위 注解強制執行法(2), 405.

다. 이와 달리 압류에 의해 추심권이 제한되는 것을 인정하기는 하지만, 그 추심권의 제한은 강제집행의 단계의 제한에 그치고 채무자가 제기하는 소의 진행에는 영향을 미치지 않는다는 견해도 있다.²²⁵⁾ 이 견해하에서 법원은 채무자의 청구에 이유가 있는 때에는 단순한 급부판결을 하면 족하나, 다만 그 판결이 확정되더라도 그 판결에 기한 강제집행은 채권자가 한 압류명령의 존재에 의해 정지되거나 취소된다고 해석한다. 위 견해는 추심소송의 기판력이 채무자에게 미치지 않는다는 입장을 전제로 하고 있다.

이 견해하에서는 채무자가 제기한 소송과 압류채권자가 제기한 추심소송은 별개의 절차를 거쳐 쌍방에 대하여 판결을 할 수 있다고 해석한다(이 경우 병합하여 심리하는 것이 가능하다. 오히려 그렇게 하지 않으면 판단이 나뉘어져 버리게 될 수도 있다). 물론, 채무자가 제기한 소송에 관계된 채권에 대하여 압류가 되어 있는 것이므로 압류의 효과(처분제한효)에 의해 압류채권자에게 불이익한 소송행위의 결과에 대하여는 압류채권자에게 대항할 수 없다. 청구의 포기나 채무면제에 한하지 않고, 진실에 반하는 자백 등에 의해 채무자가 패소해도 압류채권자는 그 패소의 결과에 구속되지 않는다. 이것은 추심소송을 제기하고 있는 압류채권자에 대하여 뿐만 아니라 추심소송을 제기하지 않고 또 추심소송에 참가하고 있지 않은 다른 압류채권자에 대하여도 동일하다. 따라서 그러한 압류채권자는 채무자 패소 후에도 별도로 추심소송을 제기할 수 있게 된다. 반면 압류채권자는 압류 전에 채무자가 한 소송상의 효과를 다룰 수 없다. 압류에 의해 처분 제한효과 발생하기까지 채무자가 한 행위의 효과는 다룰 수 없기 때문이다.

라. 채권에 대한 압류 및 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고 채무자는 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실한다는 우리 대법원의 입장²²⁶⁾을 기초로 하면, 이 경우 채권자의 압류

225) 菊井維大(주7), 172.; 兼子一, 判例民訴法, 89.

226) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007다60417 판결; 대법원 2000. 4. 11. 선고 99다23888 판결 【판결요지】[1] 일반적으로 채권에 대한 가압류가 있더라도 이는 가압류채무자가 제3채무자로부터 현실로 급부를 추심하는 것만을 금지하는 것이므로 가압류채무자는 제3채무자를 상대로 그 이행을 구하는 소송을 제기할 수 있고, 법원은 가압류가 되어 있음을 이유로 이를 배척할 수 없는 것이며, 채권양도는 구 채권자인 양도인과 신 채권자인 양수인 사이에 채권을 그 동일성을 유지하면서 전자로부터 후자에게로 이전시킬 것을 목적으로 하는 계약을 말한다 할 것이고, 채권양도에 의하여 채권은 그 동일성을 잃지 않고 양도인으로부터 양수인에게 이전된다 할 것이며, 가압류된 채권도 이를 양도하는 데 아무런 제한이 없으나, 다만 가압류된 채권을 양수받은 양수인은 그러한 가압류에 의하여 권리가 제한된 상태의 채권을 양수받았다고 보아야 할 것이다. [2] 채권에 대한 압류 및 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고 채무자는 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실한다.

및 추심명령에 기해 채무자의 급부소송이 소송요건을 흠결하여 부적법하게 되므로 압류채권자가 민사소송법 제81조에 따라 권리승계인으로서 참가하고 채무자는 당해 소송에서 탈퇴하여야 할 것이다. 또한 압류채권자는 스스로 위 추심명령에 기하여 추심소송을 제기할 수도 있다.²²⁷⁾

2. 추심소송 계속 후에 채무자가 제기하는 급부소송

채권자에 의한 추심소송 계속 후에 채무자가 제3채무자에 대하여 급부소송을 제기하는 것이 가능한가 어떤가에 대하여는, 위에서 서술한 바가 그대로 적용된다.

즉 추심소송의 기판력이 채무자에게 미치는 것을 긍정하는 견해(법정소송담당설)에 의하면 추심소송이 제기되어 있는 범위 내에서 채무자는 급부소송을 제기할 수 없고 따라서 그 부분의 소는 중복제소로 각하된다. 다만 이 견해하에서도 압류에 의한 처분제한효가 상대적이라는 이유로 채무자의 소송수행권을 긍정하고 추심소송에 공동소송참가가 가능하다는 견해도 있다.²²⁸⁾ 이에 대해, 추심소송의 기판력이 채무자에게 미치는 것을 부정하는 견해에 서면, 이 경우 채권자의 추심소송이 채무자가 제기한 급부소송의 수행에 대하여 아무런 영향도 주지 않게 된다.

대법원은 이를 중복제소로 보고 있다고 해석된다.²²⁹⁾ 다만 채권에 대한 압류 및 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고 채

227) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2013다202120 전원합의체 판결

228) 原田和徳/富越和厚(주176), 344.

229) 대법원 2013. 12. 18. 선고 2013다202120 전원합의체 판결 참조. 이는 채권자대위소송에 관한 판례의 입장과 같다. 즉 대법원은 채권자가 채무자를 대위하여 제3채무자를 상대로 제기한 채권자대위소송이 법원에 계속중인데 채무자와 제3채무자 사이에 채권자대위소송과 소송물을 같이하는 내용의 소송이 제기된 경우, 양 소송은 동일소송이므로 후소는 중복제소금지 원칙에 위배되어 부적법하다고 판시하여 채무자의 知·不知를 불문하고 양 소송의 동시 제기는 중복제소에 해당한다고 판시하고 있다. 대법원 1992. 5. 22. 선고 91다41187 판결; 대법원 1995. 4. 14. 선고 94다29256 판결; 대법원 1989. 4. 11. 선고 87다3155 판결【판결요지】[1] 채권자대위소송의 계속 중 다른 채권자가 같은 채무자를 대위하여 같은 제3채무자를 상대로 법원에 출소한 경우 두개 소송의 소송물이 같다면 후소는 중복제소금지의 원칙에 위배하여 제기된 부적법한 소송으로서 각하를 면할 수 없다. [2] 전항의 경우 전소, 후소의 판별기준은 소송계속의 발생시기 즉 소장이 피고에게 송달된 때의 선후에 의한 것이며, 비록 소제기에 앞서 가압류, 가처분 등의 보전절차가 미리 경료되어 있더라도 이를 기준으로 가릴 것은 아니다. [3] 민법 제405조 제2항은 채무자가 하는 처분행위의 효력에 관한 것으로서 채무자는 같은 조 제1항의 채권자에게 대위의 목적인 권리에 대하여 대위행사를 방해하는 관리처분권을 잃는 것을 규정한 것이지 다른 사람이 채무자의 처분권을 대위 수행할 수 있는 권능(관리권)에 기하여 행사하는 소송행위까지 금지시키는 것은 아니다. [4] 채권자가 채무자를 대위하여 제3채무자에게 한 처분금지가처분은 채권자 자신의 채무자에 대한 청구권 보전을 위하여 제3채무자가 채무자 이외의 다른 사람에게 소유권이전 등 처분행위를 하지 못하도록 하는 데 그 목적이 있으므로 실질상의 가처분권리자인 채무자에 대한 처분의 금지가 포함되는 것은 아니다.

무자는 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실한다는 우리 대법원의 입장²³⁰⁾에 따르면, 채무자는 이행의 소를 제기할 당사자적격이 없는 상태이므로 급부소송을 제기하더라도 이를 이유로 부적법각하될 것이다.

3. 채권자대위소송과 추심소송의 관계

채권자가 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 행사하는 것으로는 추심소송 외에 민법 제404조의 채권자대위소송이 있다.²³¹⁾

그런데 동일채권에 대하여 추심소송과 채권자대위소송이 경합된 경우, 즉 채권자대위소송이 제기된 후 당해 대위된 채권에 대하여 다른 채권자에 의해 압류 및 추심명령이 발령되고 그에 따라 추심소송이 제기된 경우 또는 이미 추심소송이 계속된 후에 다른 채권자에 의한 채권자대위소송의 제기되는 경우 등에 이를 어떻게 합리적으로 해결한 것인가가 문제로 될 수 있다.

먼저 채권에 대하여 압류 및 추심명령이 있으면 채무자의 소송수행권이 제한되는 것으로 보는 견해나 추심소송의 기판력이 채무자에게 미치는 것을 전제로 하는 견해하에서는 이 경우 채무자는 추심의 권능을 잃게 되고 또 대위채권자는 자신의 채무자가 가지는 권리 이상의 것을 행사할 수 없으므로 대위채권자 역시 추심소송으로 그 소송수행권을 상실하게 되어 결국 채권자대위소송은 당사자적격이 없는 것으로서 부적법 각하를 면치 못하며,²³²⁾ 나아가 추심소송제기 후에 채권자대위소송을 제기하는

230) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007다60417 판결; 대법원 2000. 4. 11. 선고 99다23888 판결【판결요지】[1] 일반적으로 채권에 대한 가압류가 있더라도 이는 가압류채무자가 제3채무자로부터 현실로 급부를 추심하는 것만을 금지하는 것이므로 가압류채무자는 제3채무자를 상대로 그 이행을 구하는 소송을 제기할 수 있고, 법원은 가압류가 되어 있음을 이유로 이를 배척할 수 없는 것이며, 채권양도는 구 채권자인 양도인과 신 채권자인 양수인 사이에 채권을 그 동일성을 유지하면서 전자로부터 후자에게로 이전시킬 것을 목적으로 하는 계약을 말한다 할 것이고, 채권양도에 의하여 채권은 그 동일성을 잃지 않고 양도인으로부터 양수인에게 이전된다 할 것이며, 가압류된 채권도 이를 양도하는 데 아무런 제한이 없으나, 다만 가압류된 채권을 양수받은 양수인은 그러한 가압류에 의하여 권리가 제한된 상태의 채권을 양수받는다고 보아야 할 것이다. [2] 채권에 대한 압류 및 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고 채무자는 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실한다.

231) 채권자대위소송은 원래 프랑스법에서 유래한 것인데 채권집행규정이 보다 정비된 독일의 추심소송을 계수한 이상 위 대위소송은 폐지되었어야 할 것을 법계수상의 혼란으로 양 제도를 모두 존치하고 있는 것이라고 한다[鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(4), 595.].

232) 三ヶ月章, “取立訴訟と代位訴訟の解釋論的立法論的調整”, 法協 91卷 1号, 1.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 476-477.; 이 경우에 추심명령을 받은 채권자는 대위소송의 피고에게 보조참가하여 추심명령의 존재를 주장하고 대위소송의 각하를 구할 수 있으며, 또한 대위소송에 당사자참가를 할 수 있는 한편 대위소송계속 후에도 그것과는 별도로 추심소송을 제기할 수도 있다고 한다[鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 477.].

것도 허용되지 않게 된다.

이에 대해, 채무자의 추심권이 회복될 가능성을 강조하는 견해나 추심소송의 기판력이 채무자에게 미치지 않는다는 견해하에서는 채권압류 및 추심명령 및 나아가 추심소송의 제기가 있더라도 채무자의 급부소송 제기권능에는 영향이 없다고 보므로 채권자대위소송이 선행되어 있는 경우에 그 후 압류 및 추심명령이 발하여져도 채권자대위소송의 속행에는 영향이 없고, 또 추심소송 제기 후에도 채권자대위소송을 제기할 수 있다고 해석하며,²³³⁾ 다만 채권자대위소송에서 승소해도 압류채권자의 압류 및 추심명령이 해제되지 않는 한 그 압류의 효력이 미치고 있는 부분에 대하여 채권자의 추심이 가능하지 않을 뿐이라고 보고 있다.

이에 관하여 일본 판례²³⁴⁾는 甲 채권자의 대위소송 제기 후에 乙 채권자가 동일 채권에 대하여 압류·추심명령을 얻어 그 지급을 구하는 소를 제기하였다고 하더라도 甲 채권자의 대위권행사의 권한이 상실되는 것은 아니고 법원은 두 소송을 병합심리하여 쌍방의 청구를 인용할 수 있다고 한다. 그리고 이때에도 제3채무자가 자기의 채무액을 넘는 현실의 지급을 강제당하는 것은 아니라는 취지로 판시하고 있으나, 왜 그와 같이 되는가에 대하여는 논거를 들고 있지 않다.²³⁵⁾ 우리 대법원의 경우 앞서 본 바와 같이 채권자가 압류 및 추심명령을 받게 되면 채무자의 추심권능 또는 소송수행권이 박탈된다는 입장에 있으므로 논리상 어느 채권자의 추심소송 제기 후에 다른 채권자가 채무자를 대위하여 채권자대위소송을 제기할 수 없다는 결론에 다다르게 될 것이다.

IX. 추심의 소에 대한 소송참가

1. 다른 채권자의 소송참가(민집 제249조 제2항)

채권자가 경합한 경우 각 추심채권자가 같은 추심소송을 각자 독립하여 제기하면

233) 田中康久(주154), 336.; 中野貞一郎(주215), 551.

234) 日最判 昭和 45(1970). 6. 2.(民集 24-6, 447)

235) 이에 대하여 일본 민사집행법 제정 전의 학설은 대체로 압류채권자에게 추심권이 부여된 이상은 채무자의 소송수행권은 그 한도에서 박탈되고, 따라서 채무자의 소송수행권에서 유래하는 대위채권자의 소송수행권은 그 한도에서 소멸한다고 하여 판례에 반대하는 입장이다[日本 注釋 民事訴訟法(5)(1998), 224.; 竹下守夫, (判批) 金融·商事判例 237号(1970), 2.; 三ヶ月章, “取立訴訟と代位訴訟の解釋論的·立法論的調整”, 民事訴訟法研究 第七卷(1978), 95 이하]. 이 경우 추심명령을 받은 압류채권자가 소송을 수행하여야 하는데, 절차적으로는 소송 계속 중의 승계인으로서 민사소송법 제79조, 제81조의 규정에 따라 대위소송을 승계하여야 한다고 한다[다만 日本 주석 강제집행법(2)(1976), 477은 대위소송의 판결의 기판력이 채무자에게 미치지 않는다는 점을 근거로 이 경우 압류채권자는 대위소송에 승계참가하지 않고 별도로 추심의 소를 제기할 수도 있고, 이는 중복제소에 해당하지 않는다고 한다].

여러모로 혼란과 불경제를 초래할 뿐만 아니라 제3채무자로 하여금 다수의 추심소송에 응소케 하는 불편이 있기 때문에 이를 막는 것과 함께 모든 채권자와 제3채무자 사이의 분쟁을 되도록 통일적으로 해결하기 위한 것이 필요하다. 그리하여 민사집행법 제249조 제2항은 집행력 있는 정본에 의한 각 채권자는 다른 압류채권자가 이미 제기한 추심소송에 공동소송인으로서 원고 쪽에 참가할 권리가 있음을 규정하고 있다.

추심소송이 이미 제기되어 있으면 다른 압류채권자, 집행력 있는 정본을 가지고 있는 채권자는 추심명령을 얻지 아니하더라도 위의 소송에 원고의 공동소송인으로 참가할 수 있다. 이 소송참가는 공동소송참가에 해당하며 이로써 유사필수적 공동소송이 된다.

일단 어떤 채권자가 본조의 추심소송을 제기하고 있는 때에는 다른 채권자는 따로 추심소송을 제기할 수 없으며 만일 그러한 소가 제기될 때에는 중복제소금지에 걸려 부적법한 소로서 각하된다(법정소송담당설).²³⁶⁾ 다만 앞의 추심소송이 제기되어 있음을 모르고 따로 추심소송을 제기할 가능성이 있음을 고려하면 각 추심소송의 병합에 의하여 공동소송참가로 전환시켜 구제할 것이라는 견해²³⁷⁾가 있다.

2. 소송참가명령(민집 제249조 제3항)

가. 제도의 목적

1) 적용범위

소를 제기당한 제3채무자는 집행력 있는 정본을 가진 채권자로서 원고(압류채권자) 쪽에 참가하지 아니한 자를 공동소송인으로 참가하도록 명할 것을 첫 변론기일까지 신청할 수 있다(민집 제249조 제3항, 제4항).

이는 채권자가 경합한 경우 분쟁을 통일적으로 해결하고, 제3채무자로 하여금 다수의 추심소송에 응소하여야 하는 불편을 덜어주기 위한 규정이다.

여기서 채권자라고 함은 추심소송의 원고로 참가할 자격이 있는 집행력 있는 정본을 가진 채권자를 말하며, 집행력 있는 정본에 의하지 아니한 배당요구채권자에 대하여는 참가명령의 신청을 할 수 없다. 따라서 제3채무자는 이들 집행정본이 없는 채권자에 대하여 소송고지(민소 제84조)를 함으로써 원고에 대한 보조참가를 하게 할 수 있을 뿐이다.

236) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 129.

237) 宮脇幸彦(주6), 249.

이미 보았듯이, 민사집행법 제238조와 관련해서 위 제249조 제1항은 채권자가 경합한 경우의 추심소송에 관한 특칙이라고 보는 것이 일반적 견해이다. 즉 위 제249조 제1항의 「제3채무자가 추심절차에 대하여 의무를 이행하지 아니한 때」라고 하는 것은 제3채무자가 민사집행법 제248조 제2항, 제3항에 따라 채무액의 공탁의무를 이행하지 아니할 때 그 이행을 구하는 청구에 한하는 것이라고 할 수 있다.²³⁸⁾

2) 참가명령의 대상자

가) 소송참가명령의 대상으로 되는 것은 집행력 있는 정본을 가진 채권자로서 원고(압류채권자) 쪽에 참가하지 아니한 채권자에 한정된다.

그 채권자에 대하여 집행정지사유가 있더라도 참가명령의 대상이 된다. 앞서 본 바와 같이 참가명령제도가 추심소송의 중복을 피하기 위해 마련된 것이기 때문이다.

나) 질권자는 질권에 기초하여 목적채권의 추심이 인정되고(민법 제353조), 제3채무자가 임의로 이행하지 않는 경우에는 압류명령을 거치지 않고 급부소송을 제기할 수 있는데, 이와 같은 질권자에 대하여 소송참가명령을 발하는 것은 가능하지 않다.²³⁹⁾

또한 질권자가 별도로 급부소송을 제기하고 있는 경우에도 참가명령을 발령하여 공동소송참가인으로서 당해 추심소송에 참가하게 하는 것도 인정되지 않는다. 단지 병합하여 판단할 수 있을 뿐이다.

그리고 질권자는 민사집행법 제273조의 규정에 의해 압류명령을 받은 후 추심소송을 제기하는 것도 가능하지만, 질권자가 그러한 절차를 경유한 경우에도 실제적인 질권에 기한 추심권을 상실하지 않으므로,²⁴⁰⁾ 그와 같은 지위에 있는 질권자를 강제 집행채권자가 제기한 추심소송에 참가하게 하는 것은 타당하지 않다.

나. 참가명령의 신청

1) 참가명령의 신청시기·방법

가) 참가명령 발령의 신청시기

이 참가명령신청은 제1회 변론기일까지 하여야 한다(민집 제249조 제3항).²⁴¹⁾ 여기서 제1회 변론기일이란 최초로 변론을 한 기일을 말하며 제1회 기일로 지정된

238) 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 128.; 兼子—(주4), 217.

239) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 598.

240) 田中康久(주154), 467. 참조

241) 조관행(주112), 527.

변론기일을 뜻하지 않는다. 만일 최초의 변론기일 후에 중복압류 또는 집행력 있는 정본에 의한 배당요구가 있는 때에는 그 직후의 변론기일까지 신청하면 될 것이다.²⁴²⁾

그러나 참가명령의 신청이 제3채무자를 위해서 마련된 취지를 감안하면 이와 같은 한정은 바람직하지 않으며, 또한 현재 배당요구의 종기가 추심소송에 의한 집행완료시(또는 추심신고시)까지로 되어 있는 점을 보더라도 이는 문제가 있다. 다만 추심소송의 기판력이 채무자에게 미치는 것을 증명하는 법정소송담당설에서는 다른 채권자의 경우 공동소송인으로서 참가하지 않고 별소를 제기하면 중복소송으로 각하될 것이므로 신청시기를 제한하기가 어려울 것이다.

나) 참가명령 발령의 신청방식

이 신청방식에 대하여 별도로 정하지 않고 있지만, 민사소송법 제84조의 소송고지방식에 준하여 신청을 하면 족하다고 볼 것이다. 신청에 기초하여 법원이 참가명령을 발한다고 해도 그 성질은 소송고지에 가까운 것이라고 보아야 하기 때문이다.²⁴³⁾

따라서 제3채무자는 다른 채권자의 압류의 내용, 압류의 시기를 기재한 서면을 제출하여 참가명령발령의 신청을 해야 할 것이다.

2) 신청 철회의 가부(可否)

참가명령 발령의 신청은, 그것이 제3채무자를 위해서 인정된 특례이기 때문에 다른 압류채권자가 공동소송참가를 할 때까지는 철회(취하)할 수 있다고 볼 것이다.

그러나 이 명령에 따라 다른 채권자가 공동소송인으로서 참가한 후에는 당해 추심소송이 유사필수적 공동소송의 형태로 되는 것이므로 그 신청의 철회가 허용되지 않는 것으로 보아야 할 것이다.

3) 불복신청의 가부(可否)

위 참가명령의 신청에 대한 재판에 대하여는 대체로 즉시항고가 인정되지 않는다고 보고 있으나, 이와 달리 참가명령발령의 신청이 그 신청시거나 대상자의 범위와의 관계에서 인용되거나 인용되지 않을 수도 있고, 더욱이 그 명령이 발하여진 경우에 기판력이 미치게 되는 것(민집 제249조 제4항)을 감안하면, 그 신청의 재판에 대하여는 인용의 경우 또는 신청기각(각하)의 경우에 당사자는 민사소송법 제73조 제3항의 유추에 의하여 즉시항고를 할 수 있다는 견해도 있다.²⁴⁴⁾

242) 조관행(주112), 527.

243) 深澤利一, 民事執行の實務(中), 594.

244) 中野貞一郎(주215), 549.

다. 소송참가명령

1) 참가명령이 발하여지는 경우

제3채무자의 신청이 있는 경우에 한한다(민집 제249조 제3항). 제3채무자의 신청이 없는데도 법원이 직권으로 소송참가명령을 발할 수는 없다. 그리고 제3채무자로부터 신청이 있고 요건 구비에 대하여 증거가 있는 이상 수소법원은 소송참가명령을 발할 의무가 있다고 볼 것이다.

참가명령의 신청은 제3채무자를 위해서 인정되는 것이므로 제3채무자에게는 신청권한이 있을 뿐 신청의무가 있는 것은 아니다.²⁴⁵⁾ 물론 참가명령이 발하여지는 것은 신청의 대상에 대하여 요건이 구비되어 있을 것을 조건으로 하므로 그 요건을 구비하고 있지 않은 자(예컨대, 집행력 없는 배당요구채권자나 질권자인 경우)에 대한 신청인 때에는 그 신청을 취하지 않는 한 법원은 이를 각하해야 할 것이다.²⁴⁶⁾

2) 참가명령의 형식, 내용 및 통지

가) 참가명령의 형식

소송참가명령은 결정의 형식에 의할 것이기 때문에 구두변론을 열지 않고도 가능하다(민소 제134조 제1항 참조). 물론 구두변론을 경유할 수도 있으므로 필요한 경우에는 참가명령의 가부(可否)에 대하여 증거조사를 할 수도 있고 또 구두변론을 거치지 않더라도 당사자심문을 하는 것은 가능하다(민소 제134조 제2항 참조). 구두변론을 개시한 경우에도 명령의 형식은 결정이다.

이 명령은 어떠한 형식적 효력을 가지는 것은 아니며, 이 명령에 응하여 참가하는가 아닌가 또한 다른 채권자의 재량에 맡겨져 있다.²⁴⁷⁾

나) 참가명령의 내용·통지

참가명령의 내용은 공동소송인으로서 원고쪽에 참가하도록 명하는 것이어야 한다(민집 제249조 제3항).

공동소송인으로서 참가해야 하는 것을 내용에 포함시키지 않은 명령은 그 내용에 명백한 오류가 있는 것이므로 명령을 경정해야 할 것이다(민소 제211조, 제224조).

참가명령은 결정의 형식에 의하므로 그 고지 방법에 대하여는 민사소송법 제221

245) 岩野徹 外 編, 위 注解強制執行法(2), 474.

246) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(4), 582.

247) 浦野雄幸(주152), 681.

조가 적용된다. 따라서 상당한 방법에 의하여 고지하. 될 것이지만, 다른 한편 참가 명령을 받고도 참가하지 않았던 다른 채권자에게 추심소송의 기관력이 미치도록 되어 있는 것(민집 제249조 제4항)을 감안하면 이 명령이 적식으로 고지되어야 할 필요성이 있기 때문에 다른 채권자에 대한 참가명령은 민사소송법 제174조 이하의 송달방식에 의하는 것이 바람직하다고 볼 것이다.

또한 참가명령이 발하여진 경우에는 그 취지를 추심소송의 원고에게도 고지하는 것이 바람직하다.²⁴⁸⁾ 다만 그 고지의 방식으로는 민사소송법 제174조 이하의 송달방식에 의할 것까지는 없을 것이다.

3) 다른 압류채권자 또는 채무자의 소송참가형식

가) 집행력 있는 정보를 가진 채권자가 명령에 따라 소송에 참가하는 방법은 민사소송법 제83조의 공동소송참가의 방식에 의해야 하고(참가명령을 받은 채권자가 참가 방식에 의하지 않고 별개의 추심소송을 제기한 경우에는 그 소가 참가의 신청으로 볼 수 없는 것이면 각하되어야 할 것이다.²⁴⁹⁾), 민사소송법 제71조의 보조참가 방법에 의하는 것이 아니다.

나) 이 참가의 방식에 대하여는 민사소송법 제71조의 규정이 준용되지만, 당해 채권자는 위 신청에 의해 공동소송인으로 되므로 그 실질은 소의 제기와 동일하고 따라서 그 신청서에는 소장과 동일한 정도의 내용을 기재하여야 한다. 따라서 그 참가 신청서에는 이미 계속되어 있는 추심소송에 참가하는 취지 외에 자신의 집행력 있는 정보의 존재 등을 명확하게 기재해야 한다. 그 신청이 적식의 것이 아닌 경우에는 민사소송법 제254조를 유추적용하여 보정명령을 발하고 그것에 응하지 않는 경우에는 참가신청서를 소장각하에 준하여 각하해야 할 것이다.

또한 참가명령이 있으면 참가의 자격은 생기는 것이지만 참가의 신청을 하지 않는 한 당연히 참가한 것으로서 취급되는 것은 아니다.²⁵⁰⁾

다) 공동소송참가가 된 경우 그 소송은 민사소송법 제67조의 필수적 공동소송으로 전화(轉化)된다. 즉 유사필요적공동소송의 형태로 되는 것이다.²⁵¹⁾ 그 결과 원고로 된 채권자가 한 유리한 소송행위는 모두를 위하여 효력이 생기지만, 불리한 소송행위는 모두 함께 하지 않으면 효력이 생기지 아니한다(민소 제67조 제1항

248) 原田和徳/富越和厚(주176), 364.

249) 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(4), 583.; 岩野徹 外 編, 위 注解強制執行法(2), 474.

250) 中野貞一郎(주215), 548.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(4), 582.

251) 中野貞一郎(주215), 549.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(4), 582.

). 252)

라) 제3채무자로부터 소송참가명령의 신청이 없는데, 집행력 있는 정본 가진 채권자 중 채무자에 대하여 압류명령을 받은 다른 압류채권자가 추심소송에 개입함에 있어서 공동소송참가방식에 의해야 하는가 아니면 다시 추심소송을 제기할 수 있는가 어떤가가 문제로 될 수 있다.

추심소송 판결의 효력이 채무자에게, 따라서 다른 압류채권자에게 미치는 것으로 보는 견해(법정소송담당설)하에서는 참가명령을 받지 않은 다른 압류채권자가 별도로 제기하는 추심소송은 중복소송으로서 위법하므로 이 경우 공동소송인으로 참가하지 않는 한 별도의 제기는 각하되어야 할 것이다.²⁵³⁾ 이에 대해, 추심소송 판결의 효력이 채무자에게 미치지 않는다는 입장(고유적격설)하에서는 이 경우 다른 압류채권자는 공동소송참가방식에 의할 수 없고 별소를 제기해야 하는 것으로 된다.²⁵⁴⁾

마) 채무자가 추심소송에 참가하는 방법에 대하여도, 채무자에게 추심소송의 판결 효력이 미치지 않는다는 견해(고유적격설)는 이 경우 민사소송법 제71조 이하의 보조참가를 할 수는 있지만 공동소송참가는 할 수 없다고 보는 반면, 추심소송의 기판력이 채무자에게 미친다는 견해(법정소송담당설)에서는 채무자가 공동소송참가를 하는 것을 인정하는 견해도 있을 것이다.

4) 참가명령 후 소의 취하 또는 참가신청 철회의 가부(可否)

공동소송인으로서 소송에 참가해야 한다는 명령이 발하여진 후에 소를 취하하는 것이 가능한가 여부에 대하여는 다음과 같이 보아야 할 것이다.

가) 다른 채권자가 참가하지 않은 경우

참가명령이 발하여졌지만, 다른 채권자가 소송에 참가하지 않은 경우에는 당해 압류채권자의 소 취하에 의해 당연히 추심소송은 종료된다.

나) 다른 채권자가 소송참가명령에 응하여 공동소송참가를 한 경우 소를 제기한 압류채권자의 소 취하의 가부(可否)

이 경우에도 추심소송을 제기한 압류채권자가 소를 취하하는 것은 허용된다. 앞서 본 대로 다른 채권자가 소송에 참가하면 그 소송형태는 유사필수적 공동소송의 형

252) 유사필수적공동소송에 있어서는 청구의 포기, 재판상의 화해 등과 같이 불리한 소송행위는 모두 함께 하지 않으면 가능하지 않지만, 추심소송 재판의 효력이 채무자에게 미치지 않는다는 입장(고유적격설)에서는 청구의 전부 또는 일부의 포기·면제의 효과는 채무자에게 미치지 않는 것으로 해석되므로 논할 실익이 없다.

253) 浦野雄幸(주152), 681.; 이영섭 대표, 주석강제집행법(中), 29.

254) 中野貞一郎(주215), 549.; 물론 이 견해하에서는 별소를 제기하였더라도 양 소송이 동일 법원에 계속하고 있는 경우에는 제3채무자로부터의 공동소송인 참가명령 신청이 인정되고 그 명령이 발령되어 병합하게 되면 양 소송은 유사필수적 공동소송으로 바뀌게 될 것이다.

태로 되지만, 이 경우 원고로 된 소송당사자 중 일부에 의한 소의 취하는 허용되기 때문이다.²⁵⁵⁾ 그러나 원고로 된 채권자들 전원이 소를 취하한 경우가 아닌 한 남은 당사자를 위하여 소송은 계속된다.

다만 남은 당사자에 대하여 판결이 된 경우에는 그 판결은 민사집행법 제249조 제4항의 유추적용에 의해 소를 취하한 압류채권자에 대하여도 그 효력이 미치는 것으로 해석해야 할 것이다.

원고가 소를 취하한 결과 참가한 채권자가 1인으로 된 경우에는 유사필수적 공동소송이던 것이 통상의 소송으로 바뀌게 된다.

다) 소송참가명령에 응하여 참가한 채권자의 참가신청 철회의 가부(可否)

추심소송에 공동소송인으로서 참가한 채권자도 참가 후에는 원고의 지위에 있게 되므로 추심소송의 제기를 한 압류채권자와 동일하게 참가신청을 철회(실질상 소의 취하)하는 것이 인정된다고 볼 것이다.

그리고 이와 같은 참가신청의 철회가 있더라도 남은 당사자를 위해서 소송이 계속되는 것은 앞서와 동일하고, 철회 후에 당해 추심소송 판결의 효력이 그에게 미치는 것도 같다.

라. 공동소송참가가 있는 경우 인용판결 형식

예컨대, 압류채권자 甲이 제기한 추심소송에 공동소송인으로서 참가해야 한다는 명령이 발하여지고 그에 따라 집행력 있는 정본을 가진 다른 채권자 乙이 공동소송참가를 한 경우 그 인용판결에 있어서는 “甲 또는 乙에 대하여” 지급을 해야 한다는 취지를 명해야 할 것이다.

이 소는 특수한 공동소송이고, 甲·乙은 모두 원고로서 승계집행문 부여절차를 거치지 않고 인용판결의 효력을 주장할 수 있기 때문에 소송에 참가한 乙도 당사자로서 주문에 기재해야 한다. 이 경우 甲과 乙의 관계는 일종의 연대채권자적인 입장이 된다고 볼 것이다.

이와 달리 참가를 명하였음에도 추심소송에 참가하지 않은 다른 채권자는 판결에 표시할 필요가 없을 것이다.²⁵⁶⁾

255) 법원실무제요 민사소송[1], 법원행정처(2005), 292.; 이시운, 신민사소송법, 박영사(2011), 689.

256) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 607.; 다만 이 경우 당사자에 준하여 판결에 표시하는 것이 바람직하다는 견해도 있다[岩野徹 外 編, 위 注解強制執行法(2), 476.].

X. 추심소송의 취하·화해

1. 추심소송의 취하

압류채권자가 추심소송을 제기한 후 그 소를 취하하는 것은 허용된다. 추심소송의 소를 취하해도 압류명령의 신청을 취하하지 않는 한 당해 압류채권자의 지위에 영향이 없고 또 다시 추심소송을 제기할 수도 있다.

소의 취하에 의해 당연히 소송은 종료된다. 다만 이 경우 소의 취하에 대하여도 민사소송법 제267조 제2항²⁵⁷⁾의 적용이 있으므로 당해 압류채권자는 다시 소를 제기하는 것이 제한될 수 있다.

이와 같은 소제기 제한의 효과가 채무자 또는 다른 채권자 등에게 미치는 것인가에 대하여는 추심소송의 기판력이 채무자에게 미친다고 볼 것인지 여부에 따라 달리 보게 된다. 즉 추심소송 판결의 효력이 채무자에게 미치지 않는다는 고유적격설의 입장에서는 당해 압류채권자에 대한 위와 같은 소제기 제한의 효과는 채무자 또는 다른 채권자에 대하여 미치지 않는 것으로 된다. 이에 대해, 추심소송의 기판력이 채무자에게 미친다는 견해(법정소송담당설)하에서는 추심소송의 소를 취하한 압류채권자가 다시 소를 제기할 수 없게 된 이상 채무자 및 그 밖의 다른 채권자도 소를 제기할 수 없고 단지 당해 소를 취하한 압류채권자가 민사집행법 제239조에 따라 손해배상책임을 부담할 뿐이라고 해석할 여지가 있다.

2. 추심소송에 있어서 화해의 가부(可否)

추심소송 중에 압류채권자가 채권을 포기하거나 채권에 대해 화해할 수 있는가 어떤가가 다투어지고 있다. 즉 이는 압류채권자에 의한 포기가 있으면 그것이 채권자(집행채무자)의 포기(민법 제506조)의 효과를 발생시키고 따라서 그 후에는 다른 채권자나 채무자가 그 채권의 행사를 할 수 없게 되는 것인가에 관한 문제이다.

일반적으로 추심권자(원고)는 피압류채권에 대하여 처분권을 가지는 것은 아니므로 피압류채권에 대하여 추심목적을 넘어서는 행위를 할 수 없다고 볼 것이다. 그리하여

257) 민사소송법 제267조 [소취하의 효과]

① 취하된 부분에 대하여는 소가 처음부터 계속되지 아니한 것으로 본다.

② 본안에 대한 중급판결이 있는 뒤에 소를 취하한 사람은 같은 소를 제기하지 못한다.

소송상의 화해가 추심목적을 넘어서는 피압류채권 자체의 면제, 포기,²⁵⁸⁾ 기한의 유예, 채권양도 등의 실체상의 행위를 포함할 때는 화해를 할 수 없다.²⁵⁹⁾ 이러한 내용의 화해를 하기 위해서는 집행채무자를 이해관계인으로서 참가시킬 필요가 있지만, 실체상 압류명령을 받은 집행채무자를 참가시키는 데에는 장애가 있는 경우가 많을 것이다.

그러나 원고의 추심 자체에 대한 유예·할부지급이나 추심권의 일부 포기를 내용으로 하는 소송상의 화해는 허용될 수 있다.²⁶⁰⁾ ²⁶¹⁾ 따라서 추심소송서 피압류채권을 양수하였다고 주장하는 자를 이해관계인으로 가입시킨 후 피고(제3채무자)가 피압류채권의 일부를 원고(압류채권자)에게, 남은 일부를 채권양수인에게 지급하는 내용의 화해를 하는 것은 피압류채권 자체의 면제·포기·채권양도에는 해당하지 않고 단지 추심권의 일부를 포기하는 것에 그치므로 집행채무자를 관여시키지 않아도 유효하게 할 수 있다.

그리고 채권의 압류와 채권양도가 경합하여 제3채무자가 혼합공탁을 한 후 압류채권자와 채권양수인 사이의 공탁금출급청구권확인소송에서, 압류채권자와 채권양수인이 공탁금출급청구권의 일부는 압류채권자에 대한 배당재단으로서 집행채무자에게 귀속시키고 남은 일부는 채권의 양수인에게 귀속시키기로 하는 내용의 화해를 하는 것도, 압류채권 자체의 면제·포기·채권양도에 해당되지 않고 다만 추심권의 일부를 포기하는 것에 그치므로 집행채무자를 관여시킬 필요 없이 유효하게 할 수 있다.

XI. 집행채권에 대한 장애사유의 발생

1. 집행취소문서 제출의 경우

압류채권에 대하여 민사집행법 제49조 제1호, 제3호, 제5호, 제6호 또는 제183

258) 채권의 전부 또는 일부의 포기가 채무자에게도 효과가 있는가 여편가의 문제 또한 추심소송의 기판력이 채무자에게 미치는가 아닌가의 논의와 무관계한 것은 아니다. 즉 이 경우 기판력이 채무자에게 미친다고 보는 견해(법정소송담당설)하에서는 압류채권자에게 피압류채권에 대한 선관주의 의무가 부과되어 있는 것으로 해석하므로 채무의 전부 또는 일부 포기나 채무에 대한 지급기한 유예 등은 이러한 선관주의의무에 반하는 것으로 보아 그 효력을 부정하게 될 것이다. 반면 기판력이 채무자에게 미치는 것을 부정하는 견해(고유적격설)하에서는 포기의 효과가 채무자에게 미치지 않고 다만 압류채권자의 포기는 추심권의 일부 포기 내지 추심의 유예로서의 효력밖에 없는 것으로 된다(이 견해하에서는 압류채권자가 추심한 채권의 한도에서 청구채권의 변제가 있었던 것으로 된다. 따라서 포기된 부분에 대하여는 집행채무자에게 추심권이 인정된다).

259) 宮脇幸彦(주6), 146.

260) 中野貞一郎(주154), 548.

261) 고유적격설의 입장에서는, 이러한 행위가 추심권에 의해 급부를 구하는 권리의 실체적인 처분의 일부이므로 허용된다고 보고 있다.

조 제1항 제1호 내지 제4호 해당의 사유가 있는 경우 추심소송절차는 어떻게 될 것인가.

이에 대해, 기판력이 채무자에게 미친다는 견해(법정소송담당설)는 추심소송 계속 후에 위와 같은 집행취소문서가 제출된 때에는 추심소송절차를 정지하고 채무자가 그 소송을 승계하는 것으로 본다. 반면 기판력이 채무자에게 미치지 않는다는 견해(고유적격설)는 이 경우 압류명령·추심명령은 취소되고 그에 따라 추심권도 소멸되므로 추심소송 제기 후에 그와 같은 사유가 발생한 때에는 그 청구가 기각되는 것으로 해석한다.

2. 집행정지문서 제출의 경우

이 경우에는 압류채권자의 추심권은 정지된 상태로 된다. 그 이후의 절차 진행에 관하여, 기판력이 채무자에게 미친다는 견해(법정소송담당설)하에서는 취소문서 제출의 경우 소송절차를 중단하고 채무자가 당해 소송을 승계하는 것과 달리 집행정지문서가 제출된 경우에는 추심소송의 진행을 정지하는 사유로 되지 않고 급부판결을 할 수 있다고 본다.²⁶²⁾

기판력이 채무자에게 미치지 않는다는 견해(고유적격설)하에서는 이 경우 추심소송의 진행을 정지하는 사유가 되지 않기 때문에 추심소송 제기 전이라도 추심소송의 제기는 방해되지 않고 또 추심소송 제기 후 정지문서 제출의 경우에는 그대로 절차를 진행시키게 되며, 수소법원은 급부판결을 할 수 있다. 물론 정지문서가 제출되어 있으므로 추심소송의 승소판결이 확정되어도 정지의 효력이 소멸되지 않는 한 그 판결에 기초한 강제집행 또는 경매를 행하는 것은 인정되지 않는다.²⁶³⁾

3. 채무자 파산의 경우

압류채권자가 추심소송을 제기한 후에 채무자가 파산한 경우에는 파산채권자는 파산절차에 의하지 않으면 채권을 실행할 수 없고[채무자 회생 및 파산에 관한 법률(이하, 채무자회생법이라고 한다) 제424조], 파산재단에 대한 강제집행은 재단에 대하여 효력이 부정되지만(채무자회생법 제348조 제1항 전단), 파산절차가 폐지되는 경우도 있을 수 있기 때문에 채무자가 파산해도 압류의 효력은 중단된 상태로 되는 것에 불과하고 그것 때문에 압류의 효력이 소멸하게 된다고 말할 수는 없다.

이 경우 추심소송의 효력이 채무자에게 미친다는 견해(법정소송담당설)하에서는 채무자의 파산에 의해 당해 추심소송은 중단되고(민소 제239조), 파산관재인이 그 소

262) 浦野雄幸(주152), 681.; 深澤利一(주243), 598.

263) 中野貞一郎(주215), 546.; 宮脇幸彦(주6), 145.

송을 수계하는 것으로 된다(채무자회생법 제347조). 이와 달리 추심소송의 효력이 채무자에게 미치지 않는다는 견해(고유적격설)는 이 경우 압류채권자가 추심소송절차를 속행하고 판결을 얻는 것이 가능하다고 본다. 또한 파산관재인은 추심소송을 수계하는 것이 가능하고(채무자회생법 제347조 제1항), 이 수계가 있으면 당해 추심소송의 효력은 채무자에게도 미치게 되는데, 이는 파산관재인의 특수한 지위 때문이라고 한다.

4. 압류채권자의 채권이 압류된 경우

예를 들어, 채권자 甲이 채무자 乙의 제3채무자 丙에 대한 채권을 압류한 상태에서 채권자 甲의 채권자 A가 甲의 乙에 대한 채권을 압류한 경우, 甲이 자신의 압류명령에 기해 추심명령을 발령받을 수 있는지가 문제로 되는데, 이에 대하여 우리 대법원²⁶⁴⁾은 이를 부정하는 듯한 판시를 하고 있다. 하지만 전부명령과 달리 추심명령은 그 성질상 채권 귀속 자체에 변경을 가하거나 혹은 채권의 만족을 부여하는 것이 아니므로 위와 같은 예에서 채무자인 甲은 A가 집행채권을 압류하였더라도 乙이 丙에 대하여 가지는 채권을 압류한 후 나아가 추심명령까지 얻을 수 있으나, 다만 그 추심권 행사로 인한 만족은 저지된다고 봄이 타당하다.

또 이 경우 추심명령을 얻은 甲이 자신의 제3채무자인 丙에 대하여 추심소송을 제기할 수 있는지의 문제는 압류된 채권의 채무자가 제3채무자에 대하여 이행청구소송을 제기할 수 있는지 여부의 문제와 동일선상에서 논의되어야 할 것이고 그에 관한 이론 전개 역시 같다고 보면 될 것이므로 압류채권자 A가 아직 추심명령을 발령받지

264) 대법원 2000. 10. 2.자 2000마5221 결정【판결요지】[1] 집행법원은 강제집행의 개시나 속행에 있어서 집행장애사유에 대하여 직권으로 그 존부를 조사하여야 하고, 집행개시 전부터 그 사유가 있는 경우에는 집행의 신청을 각하 또는 기각하여야 하며, 만일 집행장애사유가 존재함에도 간과하고 강제집행을 개시한 다음 이를 발견한 때에는 이미 한 집행절차를 직권으로 취소하여야 한다. [2] 집행채권자의 채권자가 채무명의에 표시된 집행채권을 압류 또는 가압류, 처분금지가처분을 한 경우에는 압류 등의 효력으로 집행채권자의 추심, 양도 등의 처분행위와 채무자의 변제가 금지되고 이에 위반되는 행위는 집행채권자의 채권자에게 대항할 수 없게 되므로 집행기관은 압류 등이 해제되지 않는 한 집행할 수 없는 것이니 이는 집행장애사유에 해당한다고 할 것이다. [3] 채권압류명령과 전부명령을 동시에 신청하더라도 압류명령과 전부명령은 별개로서 그 적부는 각각 판단하여야 하는 것이고, 집행채권의 압류가 집행장애사유가 되는 것은 집행법원이 압류 등의 효력에 반하여 집행채권자의 채권자를 해하는 일체의 처분을 할 수 없기 때문이며, 집행채권이 압류된 경우에도 그 후 추심명령이나 전부명령이 행하여지지 않은 이상 집행채권의 채권자는 여전히 집행채권을 압류한 채권자를 해하지 않는 한도 내에서 그 채권을 행사할 수 있다고 할 것인데, 채권압류명령은 비록 강제집행절차에 나간 것이기는 하나 채권전부명령과는 달리 집행채권의 환가나 만족적 단계에 이르지 아니하는 보전적 처분으로서 집행채권을 압류한 채권자를 해하는 것이 아니기 때문에 집행채권에 대한 압류의 효력에 반하는 것은 아니라고 할 것이므로 집행채권에 대한 압류는 집행채권자가 그 채무자를 상대로 한 채권압류명령에는 집행장애사유가 될 수 없다.

않은 상태라면(A가 이미 추심명령을 발령받았다면 불가²⁶⁵⁾) 추심명령을 받은 甲은 자신의 채무자 乙이 丙에 대하여 가지는 채권에 대하여 추심소송(이행청구)을 제기할 수 있다고 볼 것이다.^{266) 267)}

물론 이 경우 甲의 채권을 압류한 A도 추심명령을 얻어 추심소송을 제기할 수 있는데, 양 추심소송의 취급은 앞서 본 바와 같이(Ⅷ. 1.항 참조) 채무자가 제기한 급부소송과 압류채권자가 제기한 추심소송과의 관계에 준하여 고려하면 될 것이다.

그리하여, 추심소송 판결의 효력이 채무자에게 미치는 것을 긍정하는 견해(법정 소송담당설)하에서는 A의 압류 및 추심명령에 의해 甲이 제기하고 있는 추심소송은 A가 민사소송법 제79조 및 제81조의 참가 방법에 의해 승계하는 것으로 된다. 이에 대해 추심소송 판결의 효력이 채무자에게 미치지 않는다는 견해(고유적격설)에 의하면 이 경우 쌍방의 추심소송에 대하여 인용판결이 있었던 경우에는 甲은 A에 의한 압류가 해소되지 않는 한 강제집행을 할 수 없게 될 뿐이다. 따라서 甲의 집행채권을 압류한 A는 甲이 제기한 추심소송에 참가할 수 없고 별도로 추심소송을 제기해야 한다.

5. 제3채무자 파산의 경우

추심소송 제기 후에 제3채무자(피고)가 파산한 경우에는 당해 추심소송은 중단된다(민소 제239조).

파산된 제3채무자(피고)의 파산관재인이 인부절차에 의해 추심소송이 제기된 채

265) 대법원 2000. 4. 11. 선고 99다23888 판결【판결요지】[1] 일반적으로 채권에 대한 가압류가 있더라도 이는 가압류채무자가 제3채무자로부터 현실로 급부를 추심하는 것만을 금지하는 것이므로 가압류채무자는 제3채무자를 상대로 그 이행을 구하는 소송을 제기할 수 있고, 법원은 가압류가 되어 있음을 이유로 이를 배척할 수 없는 것이며, 채권양도는 구 채권자인 양도인과 신 채권자인 양수인 사이에 채권을 그 동일성을 유지하면서 전자로부터 후자에게로 이전시킬 것을 목적으로 하는 계약을 말한다 할 것이고, 채권양도에 의하여 채권은 그 동일성을 잃지 않고 양도인으로부터 양수인에게 이전된다 할 것이며, 가압류된 채권도 이를 양도하는 데 아무런 제한이 없으나, 다만 가압류된 채권을 양수받은 양수인은 그러한 가압류에 의하여 권리가 제한된 상태의 채권을 양수받는다 고 보아야 할 것이다. [2] 채권에 대한 압류 및 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고 채무자는 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실한다.

266) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 582.

267) 압류의 범위는 채무자의 제3채무자에 대한 채권(피압류채권)의 일부에 그치는 것도 있는데, 그와 같은 경우에 채무자가 급부판결(추심소송)을 구하는 것을 인정하지 않는 것은 상당하지 않으며, 또한 압류명령이 취소되거나 취해질 수도 있는 상황에서 채무자의 소송수행권을 부정하는 것은 채무자의 보호에 소홀할 수 있다는 점 등도 감안하여야 할 것이다.

권을 인정하면 그 채권이 확정되므로(채무자회생법 제458조) 소송을 수계할 필요가 없다. 반면 당해 관재인이 이의를 진술하여 채권자가 채권확정소송을 제기해야 되는 경우에는 당해 추심소송을 채권확정소송으로 소를 변경하여 관재인에게 그 소송을 수계시켜 이를 속행하는 것이 가능하다(채무자회생법 제464조).

추심소송이 질권 등 실체적인 우선 추심권에 기초한 것인 때에는 별제권의 행사는 파산절차에 의하지 않아도 되는 것으로 되어 있으므로(채무자회생법 제412조) 제3 채무자(피고)가 파산해도 추심소송의 절차에는 영향이 없다.

XII. 판결의 주문

1. 주문의 형태

추심소송을 법정소송담당의 일종이라고 보는 견해(법정소송담당설)에 의하면, 추심권 부존재의 경우 추심소송의 판결주문은 각하로 된다(피압류채권의 유무를 불문). 즉 소송판결이 되는 것이다. 이에 대해 추심권이 존재하는 경우에는 피압류채권의 유무에 의해 인용 또는 기각의 실체판결로 된다. 그리고 원고가 복수인 때, 어느 원고의 추심권이 부존재해도 나머지 원고의 추심권이 존재하면, 추심권이 없는 원고의 소는 각하되지만 나머지 원고의 소는 각하되지 않고 실체판결을 하게 된다.

그 반면, 추심소송의 소송물을 추심권에 의해 급부를 구하는 권리라고 보는 입장(고유적격설)에서는 추심소송의 판결주문은 다음과 같이 실체판결로 된다. 즉 「① 추심권 부존재의 경우 : 기각 ② 피압류채권이 없는 경우 : 기각 ③ 추심권이 존재하는데, 피압류채권이 존재하지 않은 경우 : 기각 ④ 추심권이 존재하고 피압류채권도 있었지만 원고가 추심권에 의해 급부를 구하는 것이 가능한 지위를 실체적으로 상실하였다고 판단되는 경우 : 기각 ⑤ 추심권이 존재하고 피압류채권도 존재하는 경우 : 인용」으로 되는 것이다.

2. 집행의 경합과 공탁판결

피압류채권이 금전채권인 경우 추심소송청구를 인용하는 판결에 있어서 는 제3 채무자(피고)에 대하여 압류채권자(원고)에게 피압류채권을 지급하도록 명하는 판결이 선고된다.

추심명령을 받아 채권을 추심하는 채권자는 자기채권의 만족을 위하여서 뿐만

아니라 압류가 경합되거나 배당요구가 있는 경우에는 집행법원의 수권에 따라 일종의 추심기관으로서 압류나 배당에 참가한 모든 채권자를 위하여 제3채무자로부터 추심을 하는 것이므로 그 추심권능은 압류된 채권 전액에 미치게 된다.²⁶⁸⁾ 따라서 채권자가 경합하고 있더라도 추심채권자에게 채권 전액을 지급하라는 취지의 판결이 가능하다.

그러나 다른 한편, 채권자가 경합하고 있는 경우라면 채권 전액을 지급하라는 추심소송판결에 따라 그 전액을 지급받은 추심채권자는 민사집행법 제236조 제1항에 따라 집행법원에 이를 신고한 후 집행경합을 원인으로 같은 조 제2항에 따라 공탁한 다음 사유신고를 하여 집행법원이 행하는 배당절차에서 자신에게 안분배당된 채권액만을 배당받아 가야 할 것인데도, 실무상 추심채권자가 위와 같은 공탁 및 사유신고를 하지 않는 바람에 채권집행절차가 파행되어 운영되고 있는 실정이다(채권집행절차의 미종료, 다른 채권자들의 손해 등). 이를 감안하여 볼 때, 추심소송판결을 하는 법원으로서의 당해 피압류채권에 대하여 채권자가 경합하고 있는 사실이 소송 중 밝혀진 경우에는 공탁판결을 하는 것이 바람직하다 할 것이다.

이때 공탁판결의 주문은, 「피고는 원고에게 금 〇〇〇원 및 이에 대한 20 년 〇월 〇일부터 다 갚는 날까지 연 〇〇%의 비율에 의한 돈을 지급하라. 위 지급은 공탁의 방법에 의해 하여야 한다.」 또는 「피고는 원고에게 금 〇〇〇원 및 이에 대한 20 년 〇월 〇일부터 다 갚는 날까지 연 〇〇%의 비율에 의한 돈을 공탁의 방법에 의해 지급하라.」라고 표시하면 된다.

다만 현재 이와 같은 공탁판결에 대한 근거규정이 없으므로 민사집행법 제249조에 새로운 조항을 신설하여, '제248조 제2항, 제3항에 따라 공탁의 의무를 부담하는 제3채무자에 대한 추심소송에서 법원이 원고의 청구를 인용하는 때에는 금전의 지

268) 대법원 2005. 11. 10. 선고 2005다41443 판결【판결요지】압류경합의 경우에는, 추심명령을 받아 채권을 추심하는 채권자는 집행법원의 수권에 따라 일종의 추심기관으로서 압류나 배당에 참가한 모든 채권자를 위하여 제3채무자로부터 추심을 하는 것이므로 제3채무자로서도 정당한 추심권자에게 변제하면 그 효력은 압류경합 관계에 있는 모든 채권자에게 미치고, 또한 제3채무자가 집행공탁을 하거나 상계 기타의 사유로 압류채권을 소멸시키면 그 효력도 압류경합 관계에 있는 모든 채권자에게 미친다.; 대법원 2001. 3. 27. 선고 2000다43819 판결【판결요지】같은 채권에 관하여 추심명령이 여러 번 발부되더라도 그 사이에는 순위의 우열이 없고, 추심명령을 받아 채권을 추심하는 채권자는 자기채권의 만족을 위하여서 뿐만 아니라 압류가 경합되거나 배당요구가 있는 경우에는 집행법원의 수권에 따라 일종의 추심기관으로서 압류나 배당에 참가한 모든 채권자를 위하여 제3채무자로부터 추심을 하는 것이므로 그 추심권능은 압류된 채권 전액에 미치며, 제3채무자로서도 정당한 추심권자에게 변제하면 그 효력은 위 모든 채권자에게 미치므로 압류된 채권을 경합된 압류채권자 및 또 다른 추심권자의 집행채권액에 안분하여 변제하여야 하는 것도 아니다.

급은 공탁의 방법에 의하여야 한다는 취지를 판결 주문에 기재하여야 한다'는 내용의 규정을 마련함이 타당할 것이다.

XIII. 추심소송 판결의 효력

1. 판결 효력의 내용과 확장

가. 효력의 내용

추심의 소는 채무액의 추심을 구하는 이행청구의 소이고 이를 인용한 판결은 추심금의 지급을 명하는 이행판결²⁶⁹⁾이라고 볼 수 있는데, 추심소송판결 효력의 내용은 판결 효력 가운데 기판력이라고 불리워지는 효력에 해당된다.

나. 판결 효력의 확장

민사집행법 제249조 제1항에 따라 제기된 추심소송에 위 제249조 제3항에 의해 공동소송인으로서 참가할 것을 명령받은 다른 채권자가 당해 추심소송에 참가한 경우에는 그 소송은 이미 본 바와 같이 민사소송법 제67조의 유사필수적 공동소송으로 바뀌게 되므로 그 추심소송의 판결의 효력이 당해 참가채권자에게 미치는 것은 당연하다. 이에 대해, 참가명령을 받고도 참가하지 않았던 채권자에 대하여는 판결의 효력이 미쳐야 할 근거가 없으므로 민사집행법 제249조 제4항이 그 판결의 효력(기판력)이 그 자에게 미친다고 규정한 것이다. 이는 참가명령을 받아 공동소송인으로서 참가하고 있지 않아도 공동소송인으로서 참가한 경우와 동일한 효력이 예외적으로 인정되는 것이고, 보조참가의 경우에 인정되는 민사소송법 제77조²⁷⁰⁾의 효력은 아니다.

추심소송의 효력(기판력)이 채무자에게 미치는 것을 긍정하는 견해(법정소송담당설)하에서는 이는 당연한 것을 규정한 것으로 될 것이나, 판결의 효력이 채무자에게 미치지 않는다는 견해(고유적격설)에서 위 규정은 이 추심소송의 기판력이 채무자 및 다른 채권자에게는 미치지 않는 것을 전제로 하여 예외적으로 기판력의 효력을 확장

269) 대법원 2009. 5. 28.자 2007마767 판결

270) 민사소송법 제77조 [참가인에 대한 재판의 효력] 재판은 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하지 아니하면 참가인에게도 그 효력이 미친다.

1. 제76조의 규정에 따라 참가인이 소송행위를 할 수 없거나, 그 소송행위가 효력을 가지지 아니하는 때
2. 피참가인이 참가인의 소송행위를 방해한 때
3. 피참가인이 참가인이 할 수 없는 소송행위를 고의나 과실로 하지 아니한 때

한 것이라고 해석한다. 그리고 추심소송의 기판력이 승소의 경우에 한하여 채무자에게 미친다는 절충설 하에서는 위 규정은 추심소송 패소의 경우에도 예외적으로 효력이 미치는 것을 정한 것이라고 풀이할 것이다.

또한 위 규정의 반대해석으로서 공동소송참가명령을 받지도 않고 당해 추심소송에 참가하지도 않았던 집행력 있는 정본을 가진 다른 채권자에 대하여는 위 판결의 효력이 미치지 않는다고 보아야 한다.²⁷¹⁾

다. 적용범위

위 효력이 미치는 것은 추심소송이 원고(압류채권자) 승소로 확정된 경우뿐만 아니라 패소로 확정된 경우도 포함한다.²⁷²⁾

위 규정의 존재가 우선 의미가 있는 것은 피고(제3채무자)가 승소한 경우이다. 즉 제기된 추심소송에 승소한 제3채무자는 민사집행법 제249조 제3항의 규정에 따라 공동소송인으로서 참가해야 한다는 취지의 명령을 송달했지만 이에 응하지 않은 채권자에 대하여도 추심소송이 패소로 확정된 효력(기판력)이 미치고 있다는 주장을 할 수 있으므로 통지를 받고서도 참가하지 않았던 다른(압류)채권자로부터 새로운 추심소송이 제기된 경우에는 그 소가 기판력에 저촉되기 때문에 각하해야 한다는 취지의 주장을 하는 것이 가능하다.

다음으로, 추심소송이 원고(압류채권자) 승소의 경우라면, 참가명령을 받았지만 공동소송인으로서 참가하지 않았던 다른 채권자도 그 판결의 효력을 주장하여(승계집행문 부여를 받은 후) 제3채무자의 재산에 대하여 강제집행을 할 수 있다.

그러나 제3채무자가 소송참가명령을 신청하지 않았던 경우에는 당해 추심소송에 참가하지 않았던 다른 채권자에게 판결의 효력이 미치지 않는다. 참가명령의 발령이 위와 같은 기판력 확장의 근거로 되기 때문이다.²⁷³⁾

2. 판결의 집행채무자에 대한 효력

가. 추심소송판결의 효력이 채무자에 미친다고 볼 것인가에 대하여는, 앞서 본 바와 같이 견해가 나뉘어지고 있다.

그 중 집행채권자인 원고는 자기의 이름으로 집행채무자의 권리를 재판상 행사

271) 中野貞一郎(주215), 549.

272) 山口, “差し押えた債権の取立てと轉付”, 竹下守夫/鈴木正裕 編, 民事執行法の基本構造, 482.

273) 이 경우 채무자에게 미치는 기판력이 다른 채권자에게 미치지 않는 것을 설명해야 하는데, 법정소송당당설하에서는 그 설명이 용이하지 않을 것이다.

하는 것이기 때문에 이는 제3자에 의한 법정소송담당의 일종이라고 보는 견해(법정소송담당설)는 이 경우 제3자가 타인의 권리에 대하여 소송수행권을 갖는 경우에 해당하므로 민사소송법 제218조 제3항의 규정에 따라 그 제3자가 받은 재판의 효력은 그 법률관계의 주체인 자에게도 미치기 때문에 위 추심소송에 대한 판결의 효력도 당연히 채무자에게 미친다고 해석한다. 이것이 일본과 우리나라의 통설이다.²⁷⁴⁾

그러나 이에 대하여는 그 판결의 효력이 채무자에게 미치지 않는다는 견해(고유적격설)²⁷⁵⁾와 채권자가 승소한 때에는 그 판결의 기판력이 채무자에게 미치지만 패소한 때에는 채무자에게 미치지 않는다는 견해(절충설),²⁷⁶⁾ ²⁷⁷⁾ 소송고지가 없었던 경우에는 채무자에게 판결의 효력이 미치지 않는다는 견해, 추심채권자도 채권자대위권과 같은 법정소송담당이므로 대법원 1975. 5. 13. 선고 74다1664 전원합의체 판결²⁷⁸⁾의 이론과 같이 적어도 추심소송이 제기된 사실을 채무자가 알았을 경우에 그 판결의 효력이 채무자에게 미친다고 하는 견해 등도 나오고 있다.²⁷⁹⁾

나. 추심소송 판결의 효력이 채무자에게 미치지 않는다는 견해(고유적격설)에서는 채무자에 의한 급부소송이 제기된 후 압류채권자에 의해 추심소송이 제기된 경우

274) 이영섭(주29), 173.; 이영섭 대표, 위 주석강제집행법(中), 131.; 이백규, “압류된 채권양수인의 이행청구와 추심명령” 민사판례연구XXIV(2002), 민사판례연구회, 531.; 兼子一(주4), 208.; 宮脇幸彦(주6), 147, 252. 이하; 菊井維大(주7), 676.; 新堂幸司, 民事訴訟法, 弘文堂(平成2), 193.; 日大判 昭和 15(1940), 3, 15.(民集 19, 586) 등

275) 田中康久(주154), 336.; 中野貞一郎(주154), 547.; 林屋禮二(주154), 222.

276) 三ヶ月章, “わが國の代位訴訟, 取立訴訟の特異性とその判決の效力の主觀的範圍”, 民事研究 6卷, 1.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解民事執行法(2), 407-408.; 齋藤秀夫, 注解民事訴訟法(3), 第一法規, 374.

277) 이 설의 주장자 중 대표자격인 三ヶ月章은 그 논거로서, 첫째, 추심소송도 제3자소송담당의 일레이기는 하지만 제3자소송담당의 다른 경우 예컨대 파산관재인이 파산자의 권리를 재판상 행사하는 경우나 직무상 당사자인 검사의 경우에 있어서는 정도의 차이는 있으나 담당자는 「피담보자를 위하여」소송을 수행하는 면이 존재하는데 비하여 추심소송에 있어서 채권자는 「채무자를 위하여」소송을 수행하는 면이 조금도 없고 오로지 「자기의 이익을 위하여」본래의 채권자를 밀어내고 그 권리를 그 의사에 반하여 행사하고 그 결과를 자기의 채권의 변제에 충당하기 위하여 소송을 수행하기 때문인 점, 둘째, 모법인 독일법은 일본의 구민사소송법과 같이 집행채무자에 대한 소송고지를 집행채권자의 의무로 하고 있지만 집행채권자가 받은 판결의 효력은 일체 채무자에게 미치지 않는다는 것이 판례 및 압도적 다수설이라는 점, 셋째, 패소판결의 효력도 집행채무자에게 미친다고 한다면 채무자로서는 자기가 관여하지 아니한 소송에서 제3자의 졸렬한 소송수행에 의해 자기의 권리가 상실되는 것을 감수해야 하는 집행채무자에게는 매우 가혹한 결과를 초래하게 되는 점 등을 들고 있다.

278) 대법원 1975. 5. 13. 선고 74다1664 전원합의체 판결 【판결요지】채권자가 채권자대위권을 행사하는 방법으로 제3채무자를 상대로 소송을 제기하고 판결을 받은 경우에는 어떠한 사유로 인하였던 적어도 채무자가 채권자 대위권에 의한 소송이 제기된 사실을 알았을 경우에는 그 판결의 효력은 채무자에게 미친다.(판례변경)

279) 이러한 견해의 대립에 관하여는 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 373 참조

에도 급부판결과 추심소송판결은 서로 어떠한 영향이 없게 되고, 법원으로서도 양 소송에 대하여 각 인용판결을 하는 것이 가능하다. 또한 양 소에 대하여 사건을 병합한 후 하나의 판결로 인용하는 것도 가능하다.

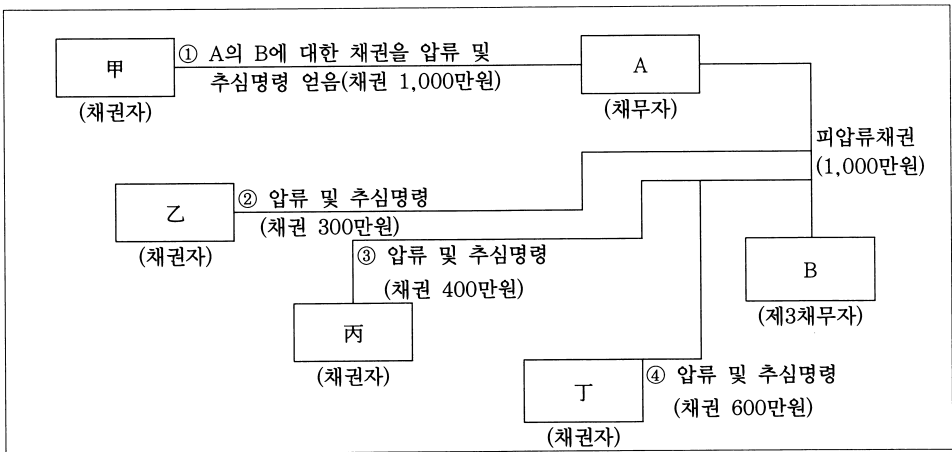
그리고 추심소송판결의 기판력이 채무자에게 미치는 것을 긍정하는 견해(법정소송담당설)에서도 압류가 피압류채권의 일부에 대하여만 된 경우에는 법원은 추심소송의 인용판결과 압류부분을 제외한 나머지 피압류채권의 인용급부판결을 함께 해야 된다. 이때 만일 추심소송의 승소채권자가 그 판결확정 후에 압류 신청을 취하하거나 압류명령이 취소되었다면 채무자는 추심소송판결에 대하여 압류명령의 취소 또는 채권압류신청의 취하를 이유로 승계집행문을 얻어 그 승계집행문을 받은 추심소송판결과 자기가 가지는 급부판결 등 2개의 판결을 함께 집행함으로써 채권전액의 보전을 도모할 수 있다.

제4절 현행법상 추심명령 제도의 문제점

I. 약탈적 우선주의의 문제점

1. 압류채권자는 추심명령을 얻어서 피압류채권을 추심할 수 있다(민집 제229조).²⁸⁰⁾ 이와 같은 추심은 압류채권자가 스스로 추심을 하는 것이어서 집행법원으로서 그 추심이 제대로 되었는지 여부를 알 길이 없으므로 민사집행법은 제236조 제1항에서 압류채권자가 제3채무자로부터 추심을 마친 때에는 추심한 채권액등을 집행법원에 신고하도록 규정하고 있는데, 이와 같이 압류채권자가 민사집행법 제236조 제1항에 따라 집행법원에 대하여 하는 추심신고는 사건종료의 보고 성격을 가지는 것이다.

2. 그런데 여기에서 잠깐 현행법 규정의 미비로 인하여 추심과 관련하여 발생하는 문제점을 한 가지 살펴보고 가기로 한다.



280) 일본은 민사집행법을 제정하면서 금전채권은 반드시 현금화의 절차를 거쳐야 하기 때문에 실무 상으로도 압류 및 추심명령이 함께 신청되는 것이 통례이고 또한 추심명령이 금전채권현금화의 대표적인 방식(압류가 경합된 경우 등 모든 경우에 가능하다)이라는 이유로 추심명령을 폐지하고 압류명령을 받은 者は 다시 추심명령을 얻지 않더라도 채무자에 대하여 압류명령이 송달된 날로부터 1주일을 경과한 때에는 당연히 압류한 채권을 추심할 수 있는 것으로 하고 있다(일본 민사집행법 제155조 제1항).

가. 이러한 사례라면, 피압류채권 1,000만 원이 채권자들인 甲, 乙, 丙, 丁의 채권액 합계인 2,300만 원에 이르지 못하므로 민사집행법 제235조에 따라 압류의 경합이 발생하게 되며, 이에 따라 위 채권자들의 각 압류의 효력은 피압류채권 전체에 대하여 미치게 된다.

나. 그런데 이 사례와 같은 경우에 제3채무자인 B가 위 각 채권자들의 압류 및 추심에 대하여 대처하는 행위태양은 다음과 같이 분류해 볼 수 있다.

① B는 자신이 A에게 지급해야 할 피압류채권에 관하여 많은 채권자들로부터 압류 및 추심명령이 송달되어 오므로 이를 민사집행법 제248조 제1항, 제3항에 따라 집행법원에 공탁하고 사유신고를 하였다.

② B는 위 채권자들로부터 각 압류 및 추심명령을 송달받았으나, 채권자들 중 1인인 甲이 1,000만 원에 대하여 추심청구를 하므로 그에게 피압류채권 전액을 모두 지급하였다.

③ B는 위 채권자들로부터 각 압류 및 추심명령을 송달받았으나, 채권자들 중 1인인 乙이 300만 원에 대하여 추심청구를 하므로 이를 그에게 지급하였고, 그 후 다른 채권자 丙이 다시 자신의 채권 400만 원을 추심청구하므로 이를 그에게 지급하였으며, 나머지 300만 원은 민사집행법 제248조 제1항에 따라 집행법원에 공탁하고 사유신고를 하였다.

④ B는 위 채권자들 중 1인인 乙이 300만 원에 대하여 추심청구를 하므로 이를 그에게 지급하였고, 그 후 다른 채권자 丙이 다시 자신의 채권 400만 원을 추심청구하므로 이를 그에게 지급하였으며, 다른 채권자 丁이 600만 원에 대하여 추심청구를 하므로 피압류채권 중 그때까지 남은 300만 원을 지급하여 주었다. 그런 다음 다시 甲이 자신의 채권 1,000만 원을 지급하라고 추심청구하였지만, B는 더 이상 줄 것이 없다고 이를 거절하였다.

다. 위의 행위태양 중 ①의 방법을 선택한 제3채무자 B는 채권자평등주의를 취하고 있는 현행 집행법의 구조상 더할 나위 없이 “훌륭한” 행위를 선택한 것이므로 더 이상 나무랄 것이 없다. 이제 집행법원은 위 공탁 및 사유신고에 따라 배당절차를 진행하여 위 채권자들에게 배당을 해주면 되는 것이다. 이 경우 배당절차를 진행하면, 채권자 甲은 4,347,826원 [= {10,000,000원/(10,000,000원+3,000,000원+4,000,000원+6,000,000원)}x10,000,000원(피압류채권)]을, 乙은 1,304,334원을, 丙은 1,739,130원을, 丁은

2,608,696원을 각 배당받게 될 것이다. 그리고 압류의 효력에 관하여 차등이 없는 채권자평등주의를 취하는 우리 법제상 위 피압류채권에 대하여는 어떻든간에 위 각 채권자들은 위 금원만을 집행하여 만족받을 수 있을 뿐이고, 만일 이를 넘어서서 더 가져가게 된다면 그것은 제 몫을 받지 못한 다른 채권자에게 반환해야 할 부분인 것이다.

그런데 제3채무자 B가 위 방법들 중 ②의 방법을 선택하였을 경우 문제가 발생하기 시작한다. 현행법은 압류가 단일한 경우는 물론이고 압류가 경합한 경우에 있어서도 채권자의 추심권에 대해 어떠한 제한도 부여하지 않고 있으므로,²⁸¹⁾ B로서는 위 ②와 같이 채권자들 중 1인인 甲이 추심청구를 하는 경우에 그저 甲에게 그 채권액을 지급하면 면책이 되는 것이다. 여기까지도 별 이상은 없으나, 문제는 그 이후에 생기게 된다. 즉 채권자 甲은 이 경우에 채권을 추심하였으면 민사집행법 제236조 제1항에 따라 추심한 채권액을 법원에 신고하여야 하는데도 실무상 이와 같은 추심신고를 하는 채권자가 거의 없다는 것이다. 다른 채권자들과의 “살벌한” 경쟁 속에서 일단 돈을 선점한 채권자 甲은 자신의 수중에 위 1,000만 원이 들어온 사실을 기뻐하고 또 그와 같은 은총을 베풀어주신 하느님께 감사하면서 위 규정에 따른 추심신고를 해야 하는 사실을 아예 모르거나 또는 알게 되었다고 하더라도 그 돈을 다른 채권자들과 나누어 가질 생각이 전혀 없으므로 그저 이를 들고 집으로 향할 뿐 그 이후는 아무런 소식이 없게 되고 만다.

그 결과 위 집행사건은 종료되지 않고 영구미제로 남게 된다(위와 같이 집행이 경합하고 있는 상태라면 채권자 甲이 민사집행법 제236조 제2항에 의해 추심한 1,000만 원을 집행법원에 공탁하고 사유신고를 한 후 집행법원에 의한 배당절차가 종료해야만 위 사건은 종료하게 된다). 그리고 실질상 다른 채권자들인 乙, 丙, 丁은

281) 대법원 2005. 11. 10. 선고 2005다41443 판결【판결요지】압류경합의 경우에는, 추심명령을 받아 채권을 추심하는 채권자는 집행법원의 수권에 따라 일종의 추심기관으로서 압류나 배당에 참가한 모든 채권자를 위하여 제3채무자로부터 추심을 하는 것이므로 제3채무자로서도 정당한 추심권자에게 변제하면 그 효력은 압류경합 관계에 있는 모든 채권자에게 미치고, 또한 제3채무자가 집행공탁을 하거나 상계 기타의 사유로 압류채권을 소멸시키면 그 효력도 압류경합 관계에 있는 모든 채권자에게 미친다.; 대법원 2001. 3. 27. 선고 2000다43819 판결【판결요지】같은 채권에 관하여 추심명령이 여러 번 발부되더라도 그 사이에는 순위의 우열이 없고, 추심명령을 받아 채권을 추심하는 채권자는 자기채권의 만족을 위하여서 뿐만 아니라 압류가 경합되거나 배당요구가 있는 경우에는 집행법원의 수권에 따라 일종의 추심기관으로서 압류나 배당에 참가한 모든 채권자를 위하여 제3채무자로부터 추심을 하는 것이므로 그 추심권능은 압류된 채권 전액에 미치며, 제3채무자로서도 정당한 추심권자에게 변제하면 그 효력은 위 모든 채권자에게 미치므로 압류된 채권을 경합된 압류채권자 및 또 다른 추심권자의 집행채권액에 안분하여 변제하여야 하는 것도 아니다.

자신들의 “파이(pie)”가 어떻게 사라지게 된 지도 잘 모른 채 이에 대하여 사실상 권리를 잃게 되고 만다.

물론, 이 경우 乙, 丙, 丁 등 채권자들로서는 이후 甲이 제3채무자로부터 채권 전부를 추심하였으나 그에 불구하고 민사집행법 제236조에 따른 추심신고를 하지 않은 사실을 알게 된 경우 甲에게 취할 수 있는 조치가 있기는 하다. 즉 이미 본 바와 같이 乙등은 甲을 상대로 추심한 금원을 법원에 공탁하고 그 사유를 신고할 것을 구하는 소를 제기할 수 있는데, 이를 인용하는 때의 주문 방식에 관하여는, 「피고는 원고에게 ○○지방법원 2018타채○○○○호 채권압류 및 추심명령에 따른 추심금 1,000만 원을 공탁의 방법으로 지급하고 그 사유를 신고하라.」는 형식으로 함이 상당하고 이 공탁판결에 기초하여 강제집행을 하여 집행기관으로부터 배당등을 받아 그것을 공탁하여야 한다는 견해(제1설)와 「피고는 ○○지방법원 2018타채○○○○호 채권압류 및 추심명령에 따른 추심금 1,000만 원을 위 법원에 공탁하고 그 사유를 신고하라.」는 형식이 되고 이는 간접강제(민집 제261조)의 방식으로 집행할 수 있다는 견해(제2설)가 있다. 하지만 이와 같이 복잡한 방법을 乙등이 알기도 어렵거니와 설사 안다고 하더라도 위 제1설, 제2설 모두 이론상으로는 그럴 듯 하나 실재상 이를 그대로 실행하기에는 참으로 지난(至難)한 것이고 또 만약 이미 돈을 손에 쥔 추심채권자가 소재불명이라면 위 판결에 따른 집행 자체가 어렵기 때문에 대부분의 채권자들은 이를 포기하고 만다. 결국은 ‘먼저 손을 쓴’(이것은 우선주의를 취하는 독일법에서의 의미와도 다른 것이며, 평등한 위치에 있으면서도 단지 돈을 먼저 받아갔을 뿐임을 의미하는 것으로서 굳이 이를 이름붙이자면 ‘약탈적 우선주의’라고 부를 수 있겠다) 채권자 甲이 부당하게 위 1,000만 원에 대하여 우선적 지위를 부여받게 되는 결과에 이르고 마는 것이다.

이러한 약탈적 우선주의는 위 행위태양 중 ③과 ④에 이르게 되면 가히 볼 만하게 된다. 위 ③④에서는 누가 먼저 제3채무자에게 가서 손을 내밀었는지에 따라 채권 만족의 운명이 달려 있다. 그리고 그것을 나중에 바로잡기 위해 소송을 해야 한다고 한다면 그 절차적 비용은 감당하기 어려울 정도에 달할 수도 있다(혹자는 이 경우 추심한 채권자가 아닌 다른 채권자들이 사후에 부당이득반환청구를 하면 되지 않는가라고 주장하기도 하나, 그러한 부당이득반환청구가 가능하다고 하더라도 왜 효력이 동일한 압류를 하였는데 당연히 처음부터 자신이 받아가야 될 돈을 다음에 보게 되듯이 입법적 불비로 인하여 다른 사람이 가져가도록 방치한 이후에 그 회복에 관하여는

아무 잘못도 없는 채권자들로 하여금 많은 비용과 시간을 들여 소송을 제기한 후 이를 반환받아가도록 해야 하는가에 대하여는 깊이 생각해보아야 할 문제인 것이다. 이는 입법적으로 잘못된 것의 뒷처리를 원인도 모르는 채권자들에게 떠넘기고 있는 것에 다름 아닌 것이다).

라. 왜 이와 같은 문제가 발생하는가. 이 모든 문제의 발생 원인은 바로 민사집행법 제248조 제2항, 제3항이 규정하는 의무공탁 규정에서 비롯되고 있다.

우리 민사집행법 제248조 제2항은, “금전채권에 관하여 배당요구서를 송달받은 제3채무자는 배당에 참가한 채권자의 청구가 있으면 압류된 부분에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다.”라고 규정하고, 제3항은, “금전채권 중 압류되지 아니한 부분을 초과하여 거둬 압류명령 또는 가압류명령이 내려진 경우에 그 명령을 송달받은 제3채무자는 압류 또는 가압류채권자의 청구가 있으면 그 채권의 전액에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다.”라고 규정함으로써 채권자의 경합이 있는 경우(제2항은 압류된 채권에 대하여 배당요구가 있는 경우, 제3항은 압류된 채권에 대하여 압류의 경합이 있는 경우)에 있어서 제3채무자의 공탁의무를 인정하고 있다.

그런데 위 조항에서 규정하는 ‘채권자의 청구’란 채권자의 지급청구를 의미하는 것이 아니라 채권자의 공탁청구를 의미하는 것이어서, 위 규정은 다시 말해 채권자의 경합이 있는 경우 채권자의 공탁청구가 있으면 제3채무자는 이를 공탁할 의무가 있다는 것이다.

그러나 이것은 잘못된 규정이라고 보아야 한다.

첫째로, 이는 우리 집행법이 앞서 보았듯이 채권자평등주의(압류의 효력, 경합의 경우 압류효의 확장, 배당요구의 효력 등)를 취하고 있는 것에 명백히 반한다. 채권자평등주의를 취하는 우리 법제상 추심명령에 따른 추심권은 다른 채권자가 경합한 경우라면 그 자체 스스로 제한되어야 하는 한계를 가지고 있는데도 이를 간과하고 있는 것이다.

둘째로, 위 규정이 채권자의 공탁청구를 전제로 제3채무자의 공탁의무를 인정하고 있지만 이는 실제상 형해화 되어 있다. 위 채권자들 중 배당요구채권자와 가압류채권자가 공탁청구하는 예는 거의 있지 아니하고 압류채권자의 경우라면 현행법하에서 추심명령을 받아 추심권을 행사하려고 하지 제3채무자를 상대로 공탁을 해달라고 청구하는 채권자는 있지 아니하다. 실무에 있어서도 이와 같이 공탁청구를 하는 채권자는 거의 없다고 해도 지나친 말이 아니다.

셋째로, 위 규정은 앞서 본 추심채권자의 추심신고의무를 인정한 민사집행법 제236조 제1항을 믿고서 위와 같이 규정되어 있으나, 이미 본 바와 같이 추심 후에 추심고를 하는 채권자가 실재상 거의 없기 때문에 그에 따라 파행된 집행의 현실이 방지되고 있는 것이다.

마. 그러면 어떻게 해야 하는가. 위 민사집행법 제248조 제2항, 제3항의 규정태도는 원래 일본 구 민사소송법의 규정을 거의 그대로 들여온 것인데, 일본의 경우 일찍이 위와 같은 문제점을 인식하고 민사집행법을 제정하면서 의무공탁규정을 “제3채무자는 제157조 제1항에서 규정하는 소(추심의 소)의 소장 송달을 받을 때까지 압류에 관계된 금전채권 가운데 압류되지 않은 부분을 초과하여 발하여진 압류명령 또는 가압류명령의 송달을 받은 때에는 그 채권 전액에 상당하는 금전을, 배당요구의 의사표시가 기재된 문서의 송달을 받은 때에는 압류된 부분에 상당하는 금전을 채무이행지 공탁소에 공탁하여야 한다(일본 민사집행법 제156조 제2항).”라고 규정함으로써 채권자의 경합이 있는 경우 그 중 일부 채권자의 추심권 행사를 제한하고 제3채무자로서 공탁해야만 채무를 면할 수 있도록 하여 이 문제점을 깔끔히 해소하였다.

우리가 나아갈 문제점의 해결방법도 여기에서 가져올 수밖에 없다. 우리가 당초 강제집행법(민사소송법에 포함되었던 것)을 제정할 때에 일본의 강제집행법을 거의 그대로 모방하고 또 그에 따라 채권자 평등주의도 함께 들여온 이상 그것에서 비롯되는 문제점의 불식방안도 우리의 모법인 일본법이 어떻게 나아갔는지를 참고하지 않을 수 없으며, 또한 현재로서는 그것이 가장 최선의 방법이라고 생각한다.

바. 결론적으로 지금의 채권집행에 있어서 나타나는 소위 약탈적 우선주의의 모순을 해결하기 위해서는 의무공탁규정에 관한 민사집행법 제248조 제2항, 제3항을 개정하여, 채권자 경합의 경우에는 제3채무자가 공탁을 하여야만 그 채무를 면할 수 있도록 규정하여야 할 것이다.

이에 대하여 어떤 이는, 법률적 지식이 풍부하지 못한 제3채무자에 대하여 채권자 경합의 경우에는 공탁하도록 의무를 지우는 것이 과다한 의무를 부담시키는 것이 아닌가라고 반론을 제기하는 견해도 있어 보이나, ㉠ 우선 추심명령의 결정문 아래에, “채권자가 경합하는 경우에는 채권자 중 1인의 추심청구에 응하여서는 아니되며, 민사집행법 제248조 제2항 또는 제3항에 따라 공탁을 하여야만 채무를 면할 수 있습니다.”는 취지의 내용을 기재하여 제3채무자에게 그 결정문을 송달하도록 한다면 별 문제가 없을 것이고, ㉡ 또 제3채무자는 채권자 경합 혹은 압류의 경합 등의 용어를

정확히 알지 못하더라도 자신에게 압류(또는 가압류) 결정문을 송달시킨 채권자가 1명인지 2명, 3명인지 또는 그 이상의 것인지를 손가락으로 헤아릴 수 있으면 공탁해야 되는가 아닌가를 판단하는데 있어서 충분하다. ㉔ 더욱이 우리 대법원²⁸²⁾은 청구금액의 총액이 피압류채권을 넘지 않는 부진정 압류의 경우에도 제3채무자의 공탁을 인정하고 있으므로 제3채무자로서는 자신에게 (가)압류명령을 송달시킨 채권자가 2명 이상만 되면 공탁을 해야 면책이 됨을 충분히 알 수가 있는 것이다. 나아가 그와 같이 공탁을 함으로써 제3채무자가 이전의 의무보다 더 부담하게 되는 문제는 결국은 공탁비용으로 귀결될 뿐이다. 즉 그와 같이 공탁을 함으로써 들게 되는 비용을 제3채무자에게 전보(填補)해주면 이는 해결할 수 있는 문제인 것이며, 이러한 공탁비용의 전보(填補)에 관하여는 민사소송비용법 제10조의2 제1항이 명문으로 규정하고 있다 [그런데 현재의 실무는 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항에 따라 하고 있는 권리공탁의 경우에도(채권자 경합의 경우이든 채권자 경합의 경우가 아니든) 모두 그 공탁에 따른 비용을 제3채무자에게 최우선적으로 지급해 주고 있다]. 그러나 권리공탁이란 제3채무자의 채무변제행위에 불과하므로 제3채무자가 권리공탁을 할 때에는 그 공탁비용을 지급해 줄 필요가 없는 것이기 때문에 이는 잘못된 것이다. 다른 한편, 현재 민사집행법 제248조 제2항, 제3항의 의무공탁규정이 불완전하여 공탁비용의 지급을 전면 금지하는 것도 타당치 않은 면을 가지고 있다[제3채무자 입장에서서는 압류가 경합된 경우에는 의무공탁을 하면서 그에 따른 비용을 지급받고자 하는데도 채권자의 공탁청구가 없으면 의무공탁을 할 수 없는 지금의 법제상 권리공탁으로써는 모든 경우에 비용의 전보(填補)가 안 된다면 그의 입장에서 억울한 면이 있는 것이다].

어쨌든 채권자가 경합하지 않는 때에 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항에 따라 권리공탁을 하는 경우에도 공탁비용을 지급해주고 있는 현재의 실무는 명백히 잘못된 것이다. 이러한 실무의 혼란 또한 민사집행법 제248조 제2항, 제3항의 의무공탁규정이 불완전하게 규정되어 있는 것에서 비롯되는 것이다.

282) 대법원 1996. 6. 14. 선고 96다5179 판결【판결요지】민사소송법 제581조 제1항의 입법 취지에 비추어 보면, 동일한 채권에 대하여 복수의 압류명령이 있더라도 각 압류의 법률적 성질상 압류액의 총액이 피압류채권액을 초과하지 아니하여 본래의 의미에서의 압류의 경합으로 볼 수 없는 경우에도, 제3채무자의 입장에서 보아 그 우선순위에 대하여 문제가 있는 등 압류의 경합이 있는지 여부에 대한 판단이 곤란하다고 보이는 객관적 사정이 있는 경우에는, 그 규정을 유추적용하여 제3채무자에게 공탁에 의한 면책을 인정하는 것이 상당하다.

3. 그리고 이미 본 바와 같이 민사집행법 제236조 제2항은, “제1항의 신고(추심의 신고) 전에 다른 압류·가압류 또는 배당요구가 있었을 때에는 채권자는 추심한 금액을 바로 공탁하고 그 사유를 신고하여야 한다”라고 규정하고 있다. 그런데 위 규정은 압류된 금전채권에 관하여 배당요구나 압류(가압류)의 경합이 있는 경우에도 제3채무자가 추심채권자에 대하여 유효한 변제를 할 수 있으므로 추심채권자에게 공탁 및 사유신고 의무를 부과하여 배당절차를 진행하기 위한 규정이다.

4. 만일 앞서 본 바와 같이 제3채무자에게 완전한 공탁의무가 부과되는 경우에는 제3채무자는 추심채권자에게 유효한 변제를 할 수 없게 되므로 추심채권자가 공탁 및 사유신고를 하여야 하는 경우가 발생하지 아니한다. 추심채권자가 추심을 할 당시에 다른 배당요구채권자나 압류 또는 가압류 채권자가 없는 경우라면 추심채권자는 그 채권을 추심해서 자신의 채권에 대한 만족을 얻으면 충분하다. 따라서 현재의 민사집행법 제236조 제2항은 삭제함이 타당하다.

5. 여기에서, 위 제236조 제2항을 삭제해버리면, 제3채무자가 배당요구 신청이나 압류(또는 가압류) 신청을 알지 못하고 추심채권자에게 채무를 지급한 경우에 문제가 있는 것 아닌가라는 의문이 있을 수 있다. 즉 제3채무자 입장에서는 배당요구서를 송달받거나 압류결정 등을 송달받지 못하였기 때문에 공탁의무가 없고 추심채권자에게 유효한 변제를 할 수 있을 것이나, 이 경우에도 어쨌든 배당요구는 있었던 것이기 때문에 이를 어떻게 처리할 것인가가 문제라는 것이다.

그러나 압류 및 추심명령을 받은 채권자는 추심권을 행사할 수 있는데, 이때 추심채권자는 다른 채권자가 행하는 배당요구에 의해 방해받지 아니하는 것이며, 다만 추심채권자의 추심권 행사는 제3채무자에게 공탁의무가 발생한 사실로 인하여 그 직접수령이 방해받는 것에 불과하다고 보아야 한다.

따라서 제3채무자에 대하여 배당요구가 있다는 취지의 통지가 송달되기 전이라면, 제3채무자는 공탁의무를 부담하지 않고, 압류채권자에게 직접지급을 하는 것으로 면책된다고 보아야 할 것이며, 그 결과로서 배당요구는 결과적으로 목적을 달성하는 것이 가능하지 않다는 것이다.

6. 이 점에 대하여 다시 적법한 배당요구는 그 신청시에 효력이 생기는 것으로 하는 이상, 압류채권자의 독점적 만족을 인정하는 것은 의문이라는 견해가 있을 수 있는데, 이는 배당요구에 의한 평등배당의 문제를 법률상 어떻게 취급해야 하는가,

즉 평등주의의 요청을 어디까지 받아들일 것인가라는 입법정책적인 측면의 성격을 함께 포함하고 있는 것이다.

그런데 우리 집행법이 평등주의를 유지할 수 있는 부분은 당해 배당재단을 집행기관이 스스로 관리할 수 있다는 것을 전제로 해야 하는 것이고, 그렇지 않고 이미 경우와 같이 제3채무자가 배당요구의 송달을 받지 않아 그 존재 여부를 알지 못하기 때문에 추심채권자에게 채무액을 지급해버린 결과 배당재단을 집행법원이 관리할 수 없는 경우라면 이러한 평등주의의 요청을 후퇴시킬 수밖에 없는 것이다.

따라서 이와 같은 틈새에서 유효한 추심과 유효한 배당요구가 충돌하는 경우 전자를 우선시키는 것이 오히려 입법정책적으로, 그리고 문리해석상 타당하다고 보아야 한다.

II. 추심명령의 경우 배당요구종기 규정의 문제점 (민집 제247조 제1항 제2호 관련)

1. 추심명령에 의한 채권의 추심은 집행채권자가 스스로 추심을 하기 때문에 집행법원으로서 추심이 제대로 되었는지 여부를 알 길이 없다. 따라서 추심명령에 의하여 제3채무자로부터 추심을 마친 때에는 추심한 채권액등을 집행법원에 신고하도록 규정하였다(민집 제236조 제1항).

2. 현행법상 위 추심신고가 있을 때까지 다른 채권자들의 배당요구가 없으면 추심채권자가 독점적 만족을 얻게 되고, 추심을 한 범위 내에서 집행권원의 집행력은 소멸하며 집행절차가 종료하게 된다.²⁸³⁾ ²⁸⁴⁾ 그러나 배당요구를 한 다른 채권자가 있는 때에는 배당절차가 종료한 때에 집행절차가 끝난다.

따라서 민사집행법 제247조의 배당요구는 이 신고가 있기까지 허용되며 그 후에는 할 수 없다. 만약 채권자가 추심을 하고서도 그 신고를 하지 않고 있으면 다른 채권자의 배당요구를 막을 길이 없다(이에 따라 배당에 참가할 수 있는 채권자가 한정

283) 대법원 2004. 12. 10. 선고 2004다54725 판결

284) 추심의 신고에 관한 민사집행법 제236조 제1항은 독일이나 프랑스에서 연유하지 않는 우리와 일본의 독창적인 것으로서 평등배당주의를 채용하여 배당에 가입한 채권자에게 평등한 배당을 하는 것이 원칙인 우리 법제하에서 달리 경합하는 채권자가 없는 한 이 신고가 있는 범위 내에서 채권집행의 전부 또는 일부의 종료를 가져오게 하는 전제 아래 추심채권자에게 절차상의 보고의무를 지운 것이다.

없이 늘어나게 되고, 결국 배당을 받을 채권자를 확정할 수 없게 된다).

3. 채권자는 추심금에서 집행채권과 집행비용의 변제를 받고 나머지가 있으면 이를 채무자에게 반환하게 되나, 추심신고를 하지 아니한 때에는 채권자로서는 자기의 채권에 대한 변제에 충당할 수 없고, 다른 채권자로부터의 배당요구가 허용되어 불이익을 받게 되나 추심신고를 강제하는 방법이 현행법상 없기 때문에 추심채권자의 추심신고가 드물고, 그에 따라 추심신고가 없는 사건은 장기미제사건이 되거나 영구 미제사건이 되는 것이 현실이어서 그 미제사건의 처리가 문제로 되고 있다.

4. 이러한 모든 문제는 민사집행법 제247조 제1항 제2호가 추심시의 배당요구의 종기를 추심채권자의 추심신고시까지로 규정해 놓은 것에서 비롯되고 있다. 즉 배당요구의 종기는 다수의 채권자 및 채무자의 이해관계가 얽혀 있는 매우 중요한 문제임에도 이를 객관적으로 확정하지 않은 채 단지 추심채권자가 추심신고를 하느냐 않느냐라는, 추심채권자의 개인적 의사 또는 의지에 맡겨둔 잘못 때문에 이와 같은 문제가 발생하고 있는 것이다. 따라서 민사집행법 제247조 제1항 제2호는 이를 개정할 필요가 있다.

5. 그러면 추심명령과 관련된 배당요구의 종기를 어떻게 객관적으로 정할 것인가.

먼저 추심과 관련된 추심채권자와 제3채무자 사이의 행위의 태양을 한번 살펴보면, ① 압류 및 추심채권자가 1인이고, 그 채권자가 제3채무자에게 지급청구를 하였는데, 제3채무자가 채무액을 지급한 경우 ② 압류 및 추심채권자가 1인이고 당해 채권자가 제3채무자에게 지급청구를 하였는데, 제3채무자가 그 채무액을 지급하지 않는 경우 ③ 압류 및 추심채권자가 다수이고 그 중 1인의 채권자가 제3채무자에게 지급청구를 한 경우 등으로 나누어 볼 수 있을 것이다.

그런데 위 ①의 경우 추심채권자가 제3채무자로부터 당해 채권을 추심하면, 추심에 의하여 제3채무자의 채무가 소멸하고 압류·추심채권자는 채권의 만족을 얻게 되므로(압류가 목적을 달성하여 소멸함), 다른 채권자의 배당요구를 인정할 여지가 없게 된다. 그 채권자는 민사집행법 제236조에 따라 추심신고를 하면 되고, 추심을 한 범위 내에서 집행권원의 집행력은 소멸하며 집행절차가 종료하게 된다. 따라서 이 경우는 배당요구의 종기라는 개념이 필요하지 않게 된다. 위 ②의 경우 추심채권자는 제3채무자를 상대로 추심소송을 제기할 필요가 있게 된다. 그렇게 되면 과연 언제까지 배당요구를 한 채권자를 장차 진행되는 배당절차에서 배당을 받을 채권자로 포섭

시킬 것인가의 문제가 대두되므로 이 경우에 배당요구의 종기라는 개념이 필요하게 된다. 위 ③의 경우 앞서 본 대로 제3채무자에 대하여 완전한 공탁의무를 인정하는 방향으로 민사집행법 제248조 제2항, 제3항을 개정된다면, 제3채무자는 이때 공탁해야 할 의무가 있고 공탁에 의해서만 채무를 면할 수 있으므로 공탁하고 사유신고를 한 시점에 배당요구의 종기에 이르게 될 것이다. 따라서 이 경우도 따로 추심명령과 관련된 배당요구의 종기라는 개념을 상정할 필요가 없게 된다.

결국 민사집행법 제247조 제1항 제2호를 삭제할 경우 추심명령과 관련된 배당요구의 종기라는 개념은 압류 및 추심채권자가 단일한 경우 제3채무자가 추심에 응하지 않아 추심소송을 제기한 경우에만 필요하게 되는 것이다.

6. 그렇다면, 위와 같이 제3채무자가 채권자의 추심에 응하지 않아 채권자가 추심소송을 제기한 경우라면 어느 때에 배당요구가 종기에 이른다고 볼 것인가.

이 경우 생각해볼 수 있는 시기는 ㉠ 추심소송 제기 시 ㉡ 소장 송달 시 ㉢ 변론종결 시 ㉣ 판결선고 시 ㉤ 판결확정 시 등이 될 것이다.

그런데 추심소송의 소장이 제3채무자에게 송달된 시점 이후에 동일한 채권을 압류한 자를 배당으로부터 배제하는 방법에 의하여 추심소송 제기라는 적극적인 행동을 한 압류채권자의 추심 노력에 보답하는 의미가 있는 점, 소장의 송달이라는 형태로 위와 같은 압류채권자의 추심노력이 외형적으로 명확하게 될 뿐만 아니라 그때에 피압류채권이 채무자의 일반재산으로부터 분리되는 외관을 나타낸다고 볼 수 있는 점, 제249조 제3항은 제3채무자가 집행력 있는 정본을 가진 채권자를 공동소송인으로 원고 쪽에 참가하도록 신청할 수 있는 권한을 ‘첫 변론기일까지’로 제한하고 있는 점(제3채무자는 소장 송달시까지 절차에 참가한 압류채권자 등을 상대로 참가명령을 신청할 수 있어서 편의로울 수 있음) 등을 고려하면, 그 배당요구의 종기를 추심소송의 소장 송달시로 규정함이 타당하다고 본다(일본 민집 제156조 또한 이와 같이 규정하고 있다).

7. 이에 대하여 추심채권자가 추심소송을 제기하여 공탁판결을 받을 경우, 일반 원칙에 따라 피고(제3채무자)가 그 공탁판결에 따라 공탁하고 사유신고를 하면 그때에 배당요구의 종기에 이르는 것으로 하면 되므로 이 경우 따로 배당요구의 종기를 설정할 필요는 없는 것 아닌가라는 반론이 있을 수 있다. 물론 이 문제는 이론적으로 배당요구의 종기를 결정하는 것이 아니고 법정책적으로 이를 결정하고자 하는 것인데, 그 근거는 바로 채권집행절차의 안정성을 도모함에 있다.

채권집행절차는 제3채무자가 채무액을 공탁함으로써 배당절차로 진행되기 전까지는 대체로 그 절차 진행의 주도권을 당사자가 가지고 있다. 채권자가 압류 또는 추심명령, 전부명령 등을 신청하면 법원은 이에 대해 거의 형식적·절차적 심사권만 가진 채 채권자의 신청대로 그 명령을 발부해주고 있으며, 제3채무자 또한 압류가 경합되었을 때에 언제 공탁하여 그 의무를 면할 것인지에 대하여 선택권을 가지고 있고, 채무자는 언제든지 자신의 채무를 변제하여 압류집행으로 얽혀진 법률관계를 풀어헤칠 수가 있다. 이 단계에서 집행법원의 역할은 당사자에 대하여 보조적 또는 후견적 역할을 하고 있다고도 볼 수 있다.

그런데 제3채무자가 채무액을 공탁하고 사유신고함으로써 배당절차사건으로 접수되면 그때부터 절차의 주도권은 거의 집행법원으로 넘어오게 된다. 이제 추심채권자가 제3채무자의 불지급을 이유로 추심소송을 제기하였을 때 어떤 입장을 취할 것인지의 한번 깊이 생각해 필요가 있는 문제이다.

추심채권자가 그 비용과 노력, 시간 등을 들여서 제3채무자에게 지급청구를 구하는 소송을 제기하였고 그에 따라 법원이 심리한 결과 압류 경합인 것이 드러나 공탁판결을 내렸는데, 피고인 제3채무자로 하여금 다시 공탁할 수 있는 시기를 자유롭게 선택할 수 있도록 한다면, 우선 그 동안의 노력에도 불구하고 또다시 제3채무자가 언제 공탁하는 것인지를 알 수가 없게 되고, 그에 따라 배당절차가 개시되는 시기도 불명확하게 되기 때문에 절차가 상당히 불안정하게 될 수 있다. 또한 압류채권자로서는 추심소송이라는 상당히 힘든 절차를 거쳤는데도 불구하고 단지 제3채무자의 선택적 의사에 따라 당해 배당절차에 참가할 수 있는 채권자들의 범위가 얼마든지 달라지게 되며, 극단적으로 말해 제3채무자가 몇 개월 또는 몇 년 동안 혹은 계속 공탁을 하지 않는다면 배당을 받을 채권자의 범위조차 확정할 수가 없게 된다. 그리고 제3채무자가 공탁판결을 받고도 채무액을 공탁하고 사유신고를 하지 않는 경우 이를 직접적으로 강제할 방법이 쉽지 않은데, 이와 같은 경우 제3채무자의 의사에다가 배당요구의 종기 또는 배당을 받을 채권자의 확정 문제를 만연히 의존하게 하는 것은 불합리한 점이 있다.

채권집행절차의 안정적 진행을 위하여 추심소송을 제기한 경우와 같이 일단 법원의 영역 범위 내로 절차가 들어왔다면 그 절차의 주도권이 사인인 제3채무자의 의사에 의해 좌우되지 않도록 컨트롤할 필요가 있는 것이다.

8. 이것과 비슷한 정책적 고려가 부동산집행에서도 행해지고 있다. 부동산집행

에 있어서 진정하게 목적물이 현금화되는 시기는 매수인이 '매각대금을 납부'하였을 때이고, 이와 같이 현금화의 목적을 달성하게 되면 압류가 소멸하게 되므로 이론적으로 볼 때에 채권자들은 위와 같이 매수인이 매각대금을 납부할 때까지 배당요구를 할 수 있는 것이나, 민사집행법은 절차의 조기 안정을 위하여 그보다 훨씬 이전인 경락 이전에 집행법원으로 하여금 배당요구의 종기를 결정으로 확정짓게 하고 있는 것이다. 이 경우 배당요구의 종기도 이론상의 문제가 아니라 집행절차의 안정을 위한 법정책적인 목적에 의해서 결정되고 있는 것이며, 채권집행에 있어서도 그와 동일한 목적하에 배당요구의 종기를 설정하는 것이므로 결국 위와 같은 반론은 적절하지 않다고 보아야 한다.

9. 한편, 이렇게 배당요구의 종기를 정한다고 하더라도 여기서 간과하지 말아야 할 한 가지 중요한 문제점이 등장하게 된다. 여기서 정하게 되는 것은 그야말로 '배당요구'의 종기라는 점이다. 다시 말해 이와 같이 규정하게 되면 위 시기는 배당요구의 종기에 불과할 뿐이므로 예컨대 채권자가 압류 또는 가압류를 하는 경우 이에 관한 배당가입차단 시기는 정하지 않은 것으로 된다.

그에 따라 채권자가 배당요구의 방법으로 절차에 참가하는 경우에는 추심소송의 소장 송달 시에 배당가입이 차단되지만, 그에 반해 채권자가 압류 또는 가압류의 방법으로 절차에 참가하게 되는 경우 이를 차단할 방법이 없게 된다. 그렇게 될 경우 채권자들은 압류 또는 가압류의 방법으로 계속 집행을 할 수 있게 되고, 이것은 추심소송의 계속 도중에 제3채무자가 새로운(완전) 의무공탁 규정에 따라 압류 등 경합을 이유로 공탁하고 사유신고를 하거나 또는 추심소송에서 공탁판결이 나서 그에 따라 공탁하고 사유신고를 한 경우어야 비로소 압류 또는 가압류 채권자에 대한 배당가입이 차단되게 되는 것이다.

예컨대 민사집행법 제248조에 따라 제3채무자가 공탁하는 경우에는 법이론적으로 피압류채권이 소멸하게 되므로 이에 대한 압류 또는 가압류는 실체적으로 무효로 되고 따라서 그 이후의 압류 또는 가압류를 할 수 없게 되는 것이다. 그러나 추심명령과 관련하여 제3채무자인 피고에게 추심소송의 소장부분이 송달되었을 때에 배당요구의 종기를 설정하는 것은 법이론적으로 그와 같이 되는 것이 아니고, 이는 정책적으로 집행절차의 안정을 위하여 그와 같이 설정한 것이므로 이를 법률규정으로 명백하게 규정하지 않는 한 위 시기는 배당요구의 종기에 해당할 뿐 압류 또는 가압류를 차단하는 효력은 발생하지 않는 것이다.

그런데 만일 위 개정된 규정으로 압류 또는 가압류의 배당가입을 차단할 수 없다면, 위 규정은 거의 필요성이 없는 규정으로 될 수도 있다. 그것은, 집행절차의 진행에 대하여 다른 채권자 등 이해관계인에게 통지 또는 고지가 전혀 행해지지 않는 채권집행의 경우 대부분의 채권자들이 배당요구가 아닌 압류 또는 가압류의 방법으로 집행에 참가하는 것이 현실이기 때문이다. 즉 압류 또는 가압류의 방법으로 집행절차에 참여하는 대부분의 채권자들에게는 위 규정이 전혀 실효성이 없는 규정이 되고 말 것이며, 채권집행절차에서는 대부분의 채권자들이 압류 또는 가압류의 방법으로 절차에 참여하기 때문에 결국 새로이 위 규정을 마련한 의의가 거의 상실되어 버린다는 것이다.

이러한 문제점이 발생하는 이유는 우리 민사집행법 제247조의 규정태도 때문이라고 볼 수 있다. 즉 위 제247조는 일본 민사집행법 제165조와 달리²⁸⁵⁾ 단지 ‘배당요구’란 제목하에 배당요구를 할 수 있는 채권자 및 어느 시기까지 배당요구를 하여야 하는가에 대해서만 규정하고 있다. 따라서 배당요구가 아닌 압류 또는 가압류의 방법으로 집행에 참여하는 채권자의 배당가입 차단시기는 위 규정에 의해 규율될 수가 없게 되는 것이다.

10. 위 문제점을 해결하기 위해서는, 압류 또는 가압류 채권자에 대한 배당가입 차단시기를 따로이 규정할 필요가 있다. 나아가 그 방법론에 있어서 볼 때, ① 현재의 민사집행법 제247조를 일본 민사집행법 제165조와 같이 ‘배당을 받을 채권자’를 규정하는 것으로 전면적으로 바꾸는 방법과 ② 민사집행법 제247조를 그대로 두고 위 규정을 압류 또는 가압류채권자에게 적용할 수 있는 근거조항을 적절한 규정 속에 포함시키는 방법 등을 생각해 볼 수 있다.

생각건대 위 두 가지 방법 중에서는 두 번째의 방법이 보다 적절하다고 본다. 현재의 민사집행법 제247조도 그 나름대로의 존재 이유가 있기 때문에 현재 이를 일본처럼 전면적으로 개정해버리기보다는 위 규정을 두고 적절한 규정에다가 이를 압류 채권자의 배당가입 차단시기로써 원용할 수 있으면 충분하다는 것이다.

이 경우 압류채권자에 대하여 배당가입 차단시기를 둘 수 있는 규정은 민사집행법 제252조가 적절하다고 생각한다.²⁸⁶⁾ 즉 민사집행법 제252조가 배당절차 및 그

285) 일본 민사집행법 제165조는 ‘배당을 받을 채권자의 범위’라는 제목하에 압류, 가압류, 배당요구를 한 채권자를 일괄적으로 규정하고 있다.

286) 물론 다른 적절한 규정도 생각해볼 수 있지만, 필자는 위 제252조가 가장 적절하다고 보는 것이다.

개시되는 시기에 관한 근거규정이므로 제1항은 현재와 같이 그 방법대로 규정하고, 민사집행법 제252조 제2항을 신설하여 “제247조에 규정된 각 시기까지 압류를 한 채권자는 배당절차에 참가할 수 있다.”라고 규정하면 된다. 압류에 관하여 위와 같이 규정하면 민사집행법 제91조가 가압류의 경우 본집행을 준용하도록 하고 있으므로 가압류에 관해서는 문제될 것이 없다.

Ⅲ. 참가명령에 있어서 참가채권자의 범위

민사집행법 제249조 제3항은 이미 본 바와 같이 제3채무자가 소송참가명령을 신청할 수 있는 채권자의 범위를 “집행력 있는 정본을 가진 모든 채권자”라고 규정하고 있다.

위와 같이 집행력 있는 정본을 가진 채권자들은 다시, ① 채무자에 대하여 압류 명령(및 추심명령)을 발령받은 채권자 ② 집행력 있는 정본을 가지고 있으면서 다른 채권자의 압류에 대하여 배당요구를 한 채권자 ③ 집행력 있는 정본을 가지고 있지만 압류 또는 배당요구를 하지 않은 채권자 등으로 분류해 볼 수 있다.

그런데 집행력 있는 정본을 가진 채권자들 중 위 ③에 해당하는 채권자에 대하여는 채권자측이 아닌 제3채무자 측으로부터 볼 때에 제3채무자가 그 존재를 알기 어려운 채권자이다. 단지 집행력 있는 정본을 가지고 있을 뿐 압류명령 또는 배당요구를 신청하지 않으면 제3채무자가 이를 인지할 수 없기 때문이다. 그럼에도 불구하고 위 제249조 제3항이 이러한 채권자들에 대하여까지 제3채무자가 참가명령을 신청할 수 있도록 규정하고 있는 것은 어쩌면 불가능한 것을 “알아서 해봐라.”는 식의 규정이며, 이는 실효성이 없는 무의미한 규정이라고 볼 수 있다.

따라서 위 제249조 제3항의 “제2항의 채권자” 즉 “집행력 있는 정본을 가진 모든 채권자” 부분은 “압류채권자 또는 집행력 있는 정본을 가진 배당요구채권자”로 바꾸어 개정하는 것이 타당할 것이다.

Ⅳ. 추심소송에서 공탁판결의 도입

현행 민사집행법상으로는 추심채권자가 직접 제3채무자로부터 압류된 채권을 추심할 수 있으므로, 추심소송에서도 수소법원은 제3채무자에 대하여 추심채권자에게 직접 추심금을 지급하라는 판결을 할 수 있다.

그러나 앞서 본 바와 같이 민사집행법 제248조 제2항, 제3항의 불완전한 의무 공탁규정은 그 문제점이 많으므로, 이를 완전한 의무공탁규정으로 개정해야 한다. 그리고 이와 같이 개정된다면 압류된 금전채권에 관하여 배당요구나 압류(가압류)의 결합이 있는 경우에 제3채무자는 추심채권자에게 직접 추심금을 지급하지 못하고 공탁을 하여야 하므로, 추심소송에서도 수소법원은 제3채무자로 하여금 추심채권자에게 직접 지급하라는 취지의 판결을 할 수 없고 공탁판결을 하여야 한다. 제3채무자가 추심채권자에게 직접 지급할 의무를 지거나 또는 추심채권자가 제3채무자에 대하여 직접 지급을 청구할 권리가 없기 때문이다.

이러한 개정과 관련하여 실무상의 혼란을 피하기 위하여 제3채무자가 공탁의무를 부담하는 경우에는, 추심소송에서 원고의 청구를 인용하는 때에 추심금을 공탁하라는 판결을 하여야 한다는 취지의 규정을 마련할 필요가 있다. 제3채무자에게 공탁의무를 부과하는 일본 민사집행법도 공탁판결에 관한 규정을 두고 있다. 위 규정은 대체로 “제248조 제2항, 제3항에 따라 공탁의 의무를 부담하는 제3채무자에 대한 추심소송에서 법원이 원고의 청구를 인용하는 때에는 금전의 지급은 공탁의 방법에 의하여야 한다는 취지를 판결 주문에 기재하여야 한다.”는 내용을 담고 있으면 될 것이다.

[4 - 1] 추심명령

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타채 채권추심

채 권 자

채 무 자

제3채무자

주 문

채권자는 채무자의 제3채무자에 대한 별지기재의 압류된 채권을 추심할 수 있다.

이 유

○ ○ 지방법원 20 타채 채권압류사건에 관한 채권자의 이 사건 추심명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사(사법보좌관) ②

- 주의 : 1. 채권자가 채권을 추심한 때에는 집행법원에 서면으로 추심신고를 하여야 합니다. 추심신고를 할 때까지 다른 채권자의 압류, 가압류 또는 배당요구가 없으면 추심신고에 의하여 추심한 채권 전액이 추심채권자에게 확정적으로 귀속됩니다. 그러나 추심 이후라도 추심신고 전까지 다른 채권자로부터 압류, 가압류 또는 배당요구가 있으면 이미 추심한 금액을 공탁하고 다른 채권자들과 채권금액의 비율에 따라 안분하여 배당을 받도록 규정되어 있음을 유의하시기 바랍니다(민사집행법 제236조, 제247조 제1항 제2호).
2. 추심신고서에는 사건번호, 채권자·채무자 및 제3채무자의 표시, 제3채무자로부터 지급받은 금액과 날짜를 적어 주시기 바랍니다.
3. 이 결정에 불복하는 사람은 송달받은 날부터 1주 내에 이 법원에 항고장을 제출하여야 합니다. 민집 제229, 제232, 민집규 제162①

[4 - 2] 채권압류 및 추심명령 신청서

채권압류 및 추심명령 신청		
수 입 인 지	채 권 자	김 ○ ○ ○○시 ○○구 ○○동 ○○ 소송대리인 변호사 손 재 주
	채 무 자	박 ○ ○ ○○시 ○○구 ○○동 ○○
	제3채무자	이 ○ ○ ○○시 ○○구 ○○동 ○○
채무명의의 표시 채권자와 채무자 사이의 서울지방법원 2018. 3. 16. 선고 2018가소101 대여금 사건의 확정판결		
청구채권의 표시 금 2,000만 원(2015. 5. 10.자 대여금)		
압류할 채권의 표시 1. 금 900만 원(채무자가 제3채무자에 대하여 가지고 있는 2018. 7. 7.자 건설기자재 납품계약에 따른 대금채권)		
신 청 취 지 채무자의 제3채무자에 대한 위 채권을 압류한다. 제3채무자는 채무자에 대하여 위 압류된 채권을 지급하여서는 아니된다. 채권자는 위 압류한 채권을 추심할 수 있다. 라는 재판을 구합니다.		
신 청 이 유 1. 채권자는 채무자에 대하여 위 채무명의의 집행력이 있는 정본에 기한 위 청구채권 표시의 채권을 가지고 있고, 채무자는 제3채무자에 대하여 위 압류할 채권 표시의 채권을 가지고 있습니다. 2. 이에 채무자의 제3채무자에 대한 위 채권을 압류하고, 나아가 채권자가 이를 추심할 수 있다는 재판을 구하기 위하여 이 사건 신청을 합니다.		
첨 부 서 류 1. 집행력 있는 판결 정보 1통		

- | | |
|----------|----|
| 1. 송달증명서 | 1통 |
| 1. 위임장 | 1통 |

20 . . .

채권자 소송대리인 변호사 손재주 ㉠

서울중앙지방법원 귀중

[4 - 3] 채권압류 및 추심명령

○ ○ 지 방 법 원
결 정

사 건 20 타채 채권압류 및 추심명령
채 권 자
채 무 자
제 3 채무자

주 문

1. 채무자의 제3채무자에 대한 별지 기재의 채권을 압류한다.
2. 제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 아니 된다.
3. 채무자는 위 채권의 처분과 영수를 하여서는 아니 된다.
4. 위 압류된 채권은 채권자가 추심할 수 있다.

청구금액

금	원(대여금)
금	원(위 대여금에 대한 이자 및 지연손해금)
합계 금	원

이 유

채권자가 위 청구금액을 변제받기 위하여 ○○지방법원 20 가합 대여금 청구사건의 집행력 있는 판결정본에 기초하여 한 이 사건 압류 및 추심명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.

20

판사(사법보좌관)

①

주의 : 1. 채권자가 채권을 추심한 때에는 집행법원에 서면으로 추심신고를 하여야 합니다. 추심신고를 할 때까지 다른 채권자의 압류, 가압류 또는 배당요구가 없으면 추심신고에 의하여 추심한 채권 전액이 추심채권자에게 확정적으로 귀속됩니다. 그러나 추심 이후라도 추심신고 전까지 다른 채권자로부터 압류, 가압류 또는 배당요구가 있으면 이미 추심한 금액을 공탁하고 다른 채권자들과 채권금액의 비율에 따라 안분하여 배당을 받도록 규정되어 있음을 유의하시기 바랍니다.(민사집행법 제236조, 제247조 제1항 제2호).

2. 추심신고서에는 사건번호, 채권자·채무자 및 제3채무자의 표시, 제3채무자로부터 지급받은 금액과 날짜를 적어 주시기 바랍니다.

3. 이 결정에 불복하는 사람은 송달받은 날부터 1주 내에 이 법원에 항고장을 제출하여야 합니다.

민사집행법 제15조, 제223조, 제227조, 제229조, 민집규 162①

[4 - 4] 지시채권의 추심명령신청

지시채권의 추심명령신청

채 권 자 ○ ○ ○

주 소

채 무 자 ○ ○ ○

주 소

제3채무자 ○ ○ ○

주 소

압류할 채권의 표시

별지목록 기재와 같습니다.

신 청 취 지

위 당사자간 ○○지방법원 2018타기000호 지시채권 압류명령사건에 관하여, 채권자는 채무자의 제3채무자에 대한 별지목록 기재의 압류된 채권을 추심할 수 있다.

라는 재판을 구합니다.

신 청 이 유

채권자는 ○○지방법원 2018타기000호 지시채권압류명령결정에 기하여 채무자의 제3채무자에 대한 별지목록 기재의 약속어음에 기한 채권을 압류하였는바, 채권자는 위 압류된 채권을 추심하고자 이진 신청을 합니다.

첨 부 서 류

1. 집행조서등본 1통

1. 납부서 1통

20

위 채권자 ○ ○ ○ ㉠

○ ○지방법원 귀중

[4 - 5] 추심소송의 소장

소 장

원 고 ○ ○ ○
 ○○시 ○○구 ○○동
 소송대리인 변호사 ○ ○ ○
 피 고 ○ ○ ○
 ○○시 ○○구 ○○동 ○○

청 구 취 지

1. 피고는 원고에게 금 9,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 부분이 피고에게 송달된 다음날부터 완제일까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
 3. 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 원고는 소외 이○○에 대한 ○○지방법원 2018가소101 대여금 사건의 집행력이 있는 판결 정본에 기하여 위 ○○○이 피고에 대하여 가지고 있는 9,000,000원의 물품대금채권에 대하여 귀원에 2018. 6. 10. 채권압류 및 추심명령을 신청하였고, 귀원으로부터 같은 달 14. 귀원 2018타기123, 124호로 채권압류 및 추심명령을 받았습니다.

그리고 위 채권압류 및 추심명령은 위 이○○ 및 피고에게 같은 달 18. 각 송달되었습니다.

2. 원고는 위 채권압류 및 추심명령에 기하여 피고에게 압류채권의 지급을 구하였는바, 피고가 그 지급을 거절하므로 이 사건 소를 제기합니다.

입 증 방 법

1. 갑 제1호증(채권압류 및 추심명령 등본)
2. 갑 제2호증(송달통지서)

첨 부 서 류

1. 위 갑호증 1통
1. 위임장 1통

20 . . .

원고 소송대리인 변호사 ○ ○ ○ ㉠

○ ○지방법원 귀중

[4 - 6] 추심명령에 의한 부동산소유권이전등기청구소송 소장

	소	장
수 입 인 지	원 고	이 ○ ○ ○○시 ○○구 ○○동 ○○ 소송대리인 변호사 김 영 담
	피 고	이 ○ ○ ○○시 ○○구 ○○동 ○○
	추심명령에 의한 부동산소유권이전등기청구	
	청 구 취 지 피고는 소외 김서담에게 별지 목록 기재의 부동산에 관하여 소외 박삼성 명의로 2017. 10. 7.자 매매를 원인으로 한 소유권이전등기절차를 이행하라. 는 판결을 구합니다.	
청 구 원 인 1. 원고는 소외 박삼성에 대한 귀원 2018. 1. 12. 선고 2018가합1234 대여금 사건의 집 행력 있는 판결 정본에 기하여 위 박삼성이 피고에 대하여 가지는 별지 목록 기재 부동산 에 관한 부동산소유권이전등기청구권(원인 : 2017. 10. 7.자 매매)을 압류하고(귀원 2018 타기109호), 귀원으로부터 보관인(소외 김서담)선임 및 권리이전명령까지 받았습니다. 2. 그런데 피고는 위 부동산에 관한 소유권이전등기절차를 거부하였습니다. 3. 그래서 원고는 다시 귀원으로부터 위 부동산의 추심명령(귀원 2018타기120호)을 받아 그 이행을 최고하였는바, 피고가 여전히 응하지 아니하므로 청구취지 기재의 판결을 구합니 다.		
입 중 방 법 1. 강제1호증(압류명령 등본) 1. 강제2호증(보관인선임 및 권리이전명령 등본) 1. 강제3호증(추심명령 등본)		
첨 부 서 류(기재 생략) 20 . . . 원고 소송대리인 변호사 ○ ○ ○ ①		
서울중앙지방법원 귀중		

[4 - 9] 채권추심사유신고서

채권추심사유신고서

사 건 2018타기000호(채권압류명령)

채 권 자 ○ ○ ○

채 무 자 ○ ○ ○

제3채무자 ○ ○ ○

위 당사자간 2018타기000호 채권압류명령에 관하여 채권자 김00은 제3채무자로부터 2018. . . . 추심(추심금액 금 1,000,000원)하였으나, 다음과 같이 채권압류가 경합되어 있으므로 추심한 금원을 공탁하고 이에 사유를 신고합니다.

다 음

1. 압류채권자 ○ ○ ○

주 소

압류채권액 금 1,000,000원 대여금

사건 ○○지방법원 2018타기000호

2. 배당요구채권자 ○ ○ ○

배당요구금액 2,000,000원

약속어음금

첨 부 서 류

1. 공탁서 1통

20 . . .

위 채권자 ○ ○ ○ ㉠

○ ○ 지방법원 귀중

[4 - 10] 추심액(압류액)의 제한허가결정

○ ○ 지 방 법 원

결 정

사 건 20 타채 채권추심
채 권 자
채 무 자
제3채무자

주 문

1. 채권자가 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 추심할 한도를 그 청구액인 금 원으로 제한한다.
2. 채무자는 제3채무자에 대하여 가지는 채권 중 위 제한을 초과하는 액에 관하여 그 처분 또는 영수를 할 수 있다.

이 유

이 사건 추심명령에 관하여 채무자로부터 민사집행법 제232조 제1항 단서의 규정에 의한 신청이 있었는바, 그 신청이 이유 있다고 인정하여 주문과 같이 결정한다.

20

판 사 ㉑

민집 232① 단서

[4 - 11] 압류채권추심의 허가신청(채권압류 및 추심명령)

압류채권추심의허가신청

사 건	2018타000호(채권압류 및 추심명령)
신청인(배당요구채권자)	○ ○ ○
채 권 자	○ ○ ○
채 무 자	○ ○ ○
제3채무자	○ ○ ○

위 당사자간 귀 원 2018타000호 채권압류 및 추심명령신청사건에 관하여 다음과 같은 재판을 구합니다.

신 청 취 지

신청인은 채무자가 제3채무자에 대하여 가지고 있는 별지목록 기재의 채권을 추심할 수 있다.

라는 재판을 구합니다.

신 청 이 유

1. 신청인은 위 사건에 간하여 채무자에 대한 ○○지방법원 2018가단000 ○○○청구사건의 집행력 있는 판결정보에 의하여 배당요구의 신청을 하였는바, 채권자는 위 사건에 관하여 추심명령을 받았음에도 불구하고 그 추심 절차를 해태하고 있어서, 신청인은 2018. . . 채권자에 대하여 최고서 송달 받은 다음날부터 10일 내에 추심할 것을 최고하여 2018. . . 에 정히 송달된바 있는데도, 채권자는 이 기간 내에 추심권을 행사하지 아니하고 아무런 이의가 없었으므로 신청취지와 같은 재판을 구하는 것입니다.

첨 부 서 류

1. 최고서 1통.

20 . . .

위 신청인(배당요구채권자) ○ ○ ○ ㉑

○ ○ 지방법원 귀중

[4 - 12] 압류취하 및 추심포기서(채권압류 및 추심명령)

압류취하 및 추심포기서

사 건 2018타000호(채권압류 및 추심명령)

채 권 자 ○ ○ ○

채 무 자 ○ ○ ○

제3채무자 ○ ○ ○

위 당사자간 귀원 2018타000호 채권압류 및 추심명령 신청사건에 관하여, 채권자와 채무자간의 쌍방간 원만한 합의가 성립되었으므로 이 건에 대한 압류해제 및 추심포기를 신청합니다.

20 . . .

채권자 ○ ○ ○ ㉠

○ ○ 지방법원 귀중

[4 - 13] 추심명령신청취하서

추심명령신청취하서

사 건

2018타기000호 채권추심명령

채 권 자

○ ○ ○

채 무 자

○ ○ ○

제3채무자

○ ○ ○

위 당사자간 귀 원 2018타기000호 채권추심명령신청사건에 관하여 채권자는 위 추심명령신청을 취하합니다.

첨 부 서 류

1. 취하서 부분 1통

20 . . .

위 채권자 ○ ○ ○ ㉠

○ ○ 지방법원 귀 중